壹、範圍

一、血親（§967）：直系血親（§967Ⅰ）、旁系血親（§967Ⅱ）

二、姻親（§969）

三、配偶

1. 肯定說（戴）：若不為，則僅係§1123③之附屬家屬≠非基本家屬≠不合理

2. 否定說（林、史）

(1) 天親等可言，僅係親屬關係之來源，非親屬本身≠配偶為0親等，比父母更近不合理

(2) 親屬與配偶於他法中對稱≠配偶非親屬（史）（§1114、1116-1／1138、1144／1131、141Ⅰ、151、416Ⅰ①）

(3) 區分僅於親屬會議中可否為指定會員（§1132①）

(4) JP列入，TW通：父權法不產物≠他法規之於此規定不用而有害

貳、種類

一、血親

(1) 自然血親（SC 41上1151例：無法意定消滅）

A、私通姓氏（SC27：原上117例）

B、全血緣（同父同母）、半血緣（同父異母、異父同母）均屬之（21院735、34院解2989、36院解3762）

C、非婚生子女：生父未認領前，非真血親

D、推定婚生子女：與推定之父於婚生否認之訴確定前仍為法律上血親（§1063Ⅰ、Ⅱ）

(2) 法定血親＝擬制血親

A、養子女與養父母及其血親（25院1442否定養父母血親；29院737、33院2747、34院解2989變更）
≠養子姻得結婚

B、推定婚生子女於婚生否認之訴期間過後（§1063Ⅲ），確定父子女關係≠收養外之法定血親

二、姻親（§969）

① 血之配偶：繼母（SC 28：前上 2400 例）

② 配之血

③ 配之血之配：連襟、妯娌

④ 親家（血之配之血）不屬之（30院2209）

⑤ 繼兄弟姐妹非親屬＝血之配之血

⑥

（丙之血之配之血≠非近親結婚）

小丙與甲間有直系血親亦有姻親（連襟）關係

叁、亲系

一、旧法

1、父系、母系亲属（74 §1131Ⅱ：同亲等父系优先，同系同亲等长者优先）

2、堂表兄弟姐妹未（87§983Ⅰ③：六亲等、八亲等之表兄弟姐妹不受近亲结婚限制）

3、法定监护人（87§1094Ⅰ④：伯父、叔父）

二、现行（仅存直系、旁系 ∋ 男女平等）

1、直系血亲尊亲属：己身所从出（§967Ⅰ）

2、直系血亲卑亲属：从己身所出（§967Ⅰ）

3、旁系：非直系但与己身出於同源之血亲（§967Ⅱ）

4、姻亲（§970）

① 血之配己：从其配己偶之亲系

② 配己之血：从其与配己偶之亲系

③ 配己之血之配己：从其与配己偶之亲系

肆、辈分（§983Ⅰ③、1073-1③、1115、1116、1117Ⅱ、1131Ⅰ①）

伍、亲等（§968、970）

六、身分关係之发生

一、出生（§1063Ⅰ、§1065Ⅱ）

二、认领

1、非婚生子女与生母间关係因出生而发生，与生父须待认领始成立（§1065Ⅰ、1067Ⅰ）

2、附期：认领=亲子关係存在事实之通知∋非亲子关係发生原因

3、通：纵认领前有事实上血缘关係，仍须认领才溯及子女出生时（§1069）∋认领为亲子关係发生原因

三、收养（养子女及养父母及其亲属间）（§1072、1077）

四、结婚（配偶、姻亲）（§969、1064 推定婚生）

柒、身分关係之消灭

一、死亡（§6）

1、因出生而生之自然血亲惟有因死亡而消灭

(1) 24院1341：离婚後订约命一方与子女断绝关係属当然无效

(2) 5C41当上1151决例：血亲关係不得以当事人间同意而终止，纵有协议，不生法律上效力

2、出养子女後，本生父母与其之自然血亲关係不因出养消灭

↳ J28：直系、旁系血亲关係於出养後仍存在

二、收養之撤銷与終止 (§1080~1081)

1、SC 33上5318：收養关係判決終止後，其他相关親屬关係隨之終止

2、34院解3010：收養終止時，若收養者、養子女之子女 同意不隨同離去原家 ⇒ 養祖孫关係不因終止收養而消滅

三、結婚之撤銷与離婚 (§971、1049、1052、1052-1、989~997)

四、婚姻視為消滅

1、§988③但 ⟶ §988-1 I 前婚姻視為消滅

↳ 96年增訂時未修正 §971 ⇒ 立法疏漏 ⇒ 類推 §971

2、74 §971：夫死妻再婚、妻死贅夫再婚視為姻親关係 ⇒ 現行民法与死亡配偶之血親无逕行消滅姻親关係

(1) 陳棋炎：JP §728 II 可參考 ⇒ 理應考慮有权消滅姻親关係，較符合個人民法特色

(2) 戴：姻親係以婚姻為媒介，当一定親屬負生法律上权利义務 ⇒ 一方死亡他方再婚時，宜使後权利义務由新婚配偶之親屬取代

(3) 林：再婚時仍与前配偶之親屬維持姻親关係，將使姻关係複雜化

(4) SC 112台簡抗79裁

A、死亡前 固不得終止，死亡後无合意終止非基於血緣关係而生之关係与憲§22保障人格自由意旨不符 (對比結婚及收養)

B、74年刪除之規定時立法者未考量姻親关係之合意終止 ⇒ 立法疏忽 ⇒ 法律漏洞

↳ 前審金門地院111婦声5裁：非法律漏洞，係立法者权衡倫常及人格自由所作出之取捨，无因社会变遷有檢討修正必要 ⇒ 无須釋憲

C、姻親所生权利义務≠收養 ⇒ 舉重明輕、平等原則，應類推 §1080 I、II 書面合意終止收養 終止姻親关係

D、SC 112台簡抗106裁：合意終止行為是否必由法院介入者係立法者权衡必要性及司法资源有限性 ⇒ 立法者自由形成空間，合憲 (非法律漏洞)

一、舊法

1.古禮：六禮中前四禮=納采→問名→納吉→納徵（後=禮俗成婚仪注=請期、親迎）

2.唐律、明律：以交換婚書或收受聘財為婚約之成立要件

3.大理院4上873：立婚書或承受聘財者，婚約始合法成立

二、性質

1.订立方式无限制，非結婚要件

2.不要式、不要物契約

3.非身分契約，身分契約係發生身分效力之契約

↳身分契約有要式性原則（ex：結婚、兩願離婚、收養、終止收養）

4.非債权契約⇒双方不生債权債務关係

三、法定要件

1.当事人自行訂定（§972）

(1)須双方意思表示一致（SC18上2082例-停）

(2)不得代理，若代理无須解除，自始当然无效（32院2555、23院1174、SC22上1999例）

(3)SC29渝上618例：姓姓親非§1所称之習慣

(4)§1071於此不適用，若当事人追认則认新訂婚約（秀、SC 20上783例-廢、33上1723例、37上8219例）（有权代理得追认生效）

2.違法定訂婚年齡令（§973）

(1)舊法（10§973）：男17岁，女15岁⇒与§980差1岁恰可衔接

(2)新法（§973）：皆17岁⇒男女平等

(3)違反

A.類推§989：当事人或法代得撤銷（戴、楼）

↳林：§989立法目的在避免无效婚之發生，保护婚生子女而為但書之目的⇒訂約无身分法效关係，应无保护婚約之必要

B.林：§973為禁止規定（禁止早婚，攸关公益）⇒§71无效（34院2182，SC32上1098例、史、胡長清、趙鳳喈、邱聰智）

3.未成年人訂婚应得法代同意（§974）（SC 23上3187例）

(1)可黙示表示同意（ex：法代於未成年人訂婚到場无異议）（SC27滬上38例）

(2)无代替同意之法，僅能等待成年，但父母代訂婚雖屬无效然視作同意，違訂婚年齡後承认時无須再同意（36院解3379）

(3)違反

A.效力未定說（曹傑、胡）⇒无明文回歸§79

B.法代有撤銷权說（楼、戴）：非財產上行為，不適用总則⇒類推§981、§990（已刪），品明後承认僅撤銷权消滅

C.无效說（林、宋）：§973无似§989无效⇒§974无似§990无效⇒§71（SC32上2837例：婚約非第三人所得撤銷，因无請求权）

4、非禁婚亲（类推§989）

5、无配偶（类推§989）

6、非作欺胥追 ⇒撤销

(1) 类推§997：6月内向法院请求撤销（数）

(2) §992：僅须意思表示，无须诉讼（林）

7、可附附款（ex：条件、期限）

(1) 逾期未给付聘金为解除条件：✓（大理院8年）

(2) 无违公序良俗或婚约纯洁性（ex：原配偶死亡、与原配偶离婚、钜额违约金）

四、效力

1、結婚之预约⇒不生身分关係

2、民诉§32①、③、301Ⅰ① 未婚配偶 身分之取得⇒民法上仍不生身分关係

3、仍可成立 家属（22院959）

4、双方无同居义务（SC23上937例）

5、订婚後結婚前所生子女仍為非婚生子女（§1064、1065）

6、不得请求强迫履行（§975），拒絕僅有损赔请求权（§978）（23院1135、SC 27渝上695例）

五、无效（僅§979-1明文）

1、林：違反§973、§974

2、效果

(1) 自始无效

(2) §979-1 贈与物返还请求权

(3) 损赔

六、撤销（僅§979-1明文）

1、事由

(1) 类推婚姻撤销之原因（數、模）：§979、975、996、997

(2) 僅作欺胥追悅（林）：§973、974无效非得撤销，§995不能人道与其类推用等§976Ⅰ①重大事由⇒剩作欺胥追

2、方式：非类推§997⇒意思表示即可（§92），无须起诉（史、林）

3、未成年人撤销

(1) 应得法代同意悅（史）

(2) 无须法代同意悅（通）：作欺胥追仍約定其日撤销⇒同意权对未成年人不利⇒应认无须同意

4、效力

(1) 溯及既往 (不同於結婚撤銷之不溯及既往 ∵ 无身分行為特殊性，不影响第三人)

(2) 返还贈与物 (§979-1)

(3) 損賠

七、解除

1. 死亡

2、合意解除：未明文但无不许之理 (合意订婚自得合意解约)

3、法定解除事由 (§976 I) ∋ 6例示 1概括

① 订婚後再与他人订、結婚

(1) 24院1271，30院219：无論效均得撤銷，但不得对他人婚約撤銷

(2) 成立在後之婚約

A. 史：以受作欺為由撤銷 (§93)

B. 模：不得撤銷，惟有作欺則以§976 I ⑦撤銷

C. 林：後婚約之当事人即使非以受作欺為由而以回復单一婚約為由以§976 I ⑦解除亦无不可

② 故遠結婚期約

(1) SC 22上 3025例：一方对婚約時期故意遠背者

(2) 屆期不履行可証无結婚誠意 ∋ 雖不得強迫履行，他方仍得解約

(3) 模：準用§254 須經催告始得解約

(4) 戴：婚約係身分契約，性質上不宜準用債編

③ 生死不明滿一年

(1) 知其仍生存但位置不明不成立

(2) §976 II ∋ 縱1年後音訊已通，他方仍得主張解除权已發生无須為意思表示，而拒絕履行

④ 有重大不治之病

(1) 須經客观医学判斷，疾病种類在所不問

(2) 订婚前已有者，亦可解除，惟他方明知有爭议

A. 否定说 (戴、鳳)：婚約之解除僅生損賠問題，而因有§978 故採否定说

B. 肯定说 (模、史、林、胡)：立法理由－個人幸福，若有故意隱瞞自有被作欺撤銷 ↳ 史：亦得按此款解除

⑤ 婚約訂定後与他人合意性交

(1) 通姦罪離除前亦不成罪，因婚約不生身份关係

(2) 強姦他人无此款適用 ∋ ⑥、⑦ 解除

(3) 订婚前明文无此款適用

⑥ 订婚後受徒刑宣告

(1) 史、林、模：品性有虧 且損及他方名譽

(2) 罰金之宣告 无此款適用，死刑等重明重類推此款

⑦ 有其他重大事由者

(1) 根据法规定当事人背景依一般社会通念判断，认有不可期待其维持婚约而進入婚姻关係之情事者

A、订婚後發徵婚啟事(放蕩)

B、侮辱他方父母

C、非处女不屬之

(2) 不能期待他方之履行者亦有此款適用 (cf：成為禁婚親)

⑧ 舊法：订婚後成為殘廢 (108§976I⑥)、有花柳病或有其他惡疾 (108§976I⑤)

⑨ ①、②、⑤、⑥ 採有責主义；③、④ 採无責主义；⑦為概括规定，无有无责之区分 (林) (戴、模：⑦係无責主义)

⑩ 双方均有解除权时，双方同时解除殊難像 ∵一旦解除後婚约即消滅，他方則无行使之可能

⑪ 戴：⑦雖如时本人有得解约 (林反对：明文僅他方得解除)

⑫ 无§153 適用∵事前同意或事後宥恕均仍得解除∵注意有无濫用解除权 (林、戴、模)

4. 方式

(1) 不要式行為∵无須起诉、書面∵向他方為意思表示即可

(2) 无时效限制

(3) 若已結婚即不得再以有解除事由解除婚约 (SC 29 渝上609例)

(4) 未成年

A、受令負无須但行使須同意说 (戴、模)；§1049 立法意旨

B、无須同意说 (史、林)

(A) 解约自由原則，不应因未成年人異其待遇，且无法阻止他方解约∵有時对未成年人有害而利於他方，有所不公 (史)

(B) §1049但離婚為契约行為，解除婚约為单独行為，難類推 (林)

(C) 有法定離婚原因未成年人即得单独诉請離婚，无須法代同意 (家事§2②、14II)，解除婚约应適用之

(D) §976II：无須為意思表示∵得為解除時起不受婚约拘束∵生死不明滿一人、心神喪失人有爭议

a、向法代為意思表示说 (戴、模) ∵不適用§976II

b、直接不受拘束说 (林)：解除权具一身專屬性不得由法代代為受理意思表示∵適用§976II

八、損賠

1、无效：不得依違反婚约請求損賠 (SC33上6127例)

(1) 否定说：如有貝當与財物，自有§179-1，应无財產上損害 (戴)

(2) 肯定 类推§247 (史)：对非因过失信賴婚约為有效致受損害他方負損賠責任

(3)肯定類推§977：須相對人有過失，請求权人无過失

(4)肯定類推§997（林、通、模）：婚約非債权契約，且§999包含財產上及非財產上損害，更能保护被害人

2、撤銷（通：肯定说）

(1)肯定類推§977：須相對人有過失，請求权人无過失（戴東雄）

(2)肯定類推§997（林、通、模、戴）：婚約非債权契約，且§999包含財產上及非財產上損害，更能保护被害人→非財產上損賠為一身專屬

(3)肯定類推§1174Ⅱ（史）

A、通：§1173、1174Ⅱ為贅文，有架空其他請求权之虞（ex：§184、245-1、179、767）

B、損賠範圍此條解釋上亦不含精神上損賠→若使用此條对婚姻上之主要非財產上損害不得求償，对当事人不利

3、合意解除：除負損賠金條件外无§978適用（SC 57台上428例）

4、法定解除

(1)請求权人未必為解除婚約者（ex：A重大过失，B出軌，B訴請離婚，僅A得向B請求）

(2)双方均有過失、皆无過失則皆不得求償（林、郭振恭、模）（§977Ⅰ）

A、林：§999Ⅰ、1056Ⅰ皆不以請求权人无過失為限，但§977不採，於立法論上不当

B、史：若為同一重大事由双方均有過失有§217

↳林：立法論上可行，解釋論上不要

(3)過失非注意义務之違反，而是对解除原因之發生有无過失

(4)範圍：限積極損害（ex：飯店訂金→預期禮金不屬之）

(5)§979-2：2年时效

(6)具一身專屬性，例外可由契約承担或已起訴請求之（§977Ⅲ）

(7)未成年

A、法代无責说（林）：非侵权or債務不履行→法代无連帶責任（77.4.5(77)廳民一0458号函）

B、法代有責说（史）：法代未同意則婚約无效，同意後自有§221 —通用→§187負連帶損賠責任

5、違反（§978）

(1)§979-2：2年时效

(2)具一身專屬性，例外可由契約承担或已起訴請求之（§977Ⅱ）

(3)§978以未解除為限→若已解除則按§976、977

(4)損賠後之解除

A、模：損賠後婚約終了，无再履行之問題→請求§978時即含有解除之意思表示

B、林：应廢除§978、979，若有一方不履行則按§976Ⅰ⑦解除即可

九、贈与物返還（§979-1）

1.舊法（74年）：无此條→{SC 47台上1469例 SC 47台上917例}（廢）：聘金係附負担之贈与；以婚約解除或違反為解除條件之贈与

2、违反婚约则即终止→类推§1079-1

3、死亡时无适用(21院838)

(1) 婚约具一身专属性→死亡解消→不用返还赠与物

(2) 依从前律例(大清律例)有不追财礼之明文

(3) 订婚约无须聘财,纵事实上有惟僅依一种赠与,不得因一方死亡而请求返还赠与物

4、§1079-2:2年时效

壹、結婚

一、形式要件

1. 立法例

(1) JP§739 申報婚主義

(2) Ger§1310~1312 登記婚+儀式婚主義

2. 舊法

(1) 19~72年§982：公開儀式+2人以上証人

A. 公開儀式：沿襲舊制，尊重礼俗

(A) 儀式形式不拘(通)：

↳ SC 30上452例：結婚屬要式行為，必經習慣上一定之儀式

(B) 行定式之礼儀，使一般不特定之人均可共見共聞认识其為結婚者，即為公開儀式 (22院859、SC51上551例-廢)

↳ ex：置酒席而情狀上一般人業已认係結婚儀式 雖主觀以為舉行婚礼，仍非公開儀式
官署內舉行，雖長官及証婚人兩人以上在場，若除使一般不特定之人可知悉之表徵而得見者，仍非公開儀式 (26院1701)

B. 2人以上証人

(A) 証人之身分 不限于親朋好友、介紹人均可

(B) 无須載明於結婚証書，但須在場親見，並願負証明責任之人 (22院859)
→ 須有行為能力

↳ 未在場親見，雖委托他人於証書內簽章，仍非証人 (26院1701)

(C) 楼：証人在排除主婚人及当事人，因均与婚姻之合法成立有密切关联

↳ 22院955、林：儀式及証人身分 均不限，排除当事人即可

(2) 74年~96年：增訂§982II：依戶籍法為結婚之登記者，推定已結婚

A. 修正前由主張有積極事实方負举証責任，因通常時過境遷，举証極難；修法後主張无婚姻者須举反証推翻耕，較公平

B. 此仍採儀式婚主义，僅具武于登記之推定力 与非結婚形式要件，僅程序上举証責任移転之特別規定

↳ 不溯及既施行後(不溯及既往)限制 与修正前登記者有§982II 適用 (楼、林、SC79台上2219例-廢：程序從新原則)

(3) 儀式婚之缺失

A. 易重婚 (19~74重婚非无效而係得撤銷→未撤銷則重婚合法)，身分証書已偶棚僅供參考

B. 公開儀式无标準，认定寬嚴不一

C. 婚姻之成立取決於証人之証言，且事過境遷，証人難說明是否為公開儀式 (楼、林)

D. 推定之婚姻非終局確定，若反証成功特溯及登記時无效 与婚姻長期不確定，不妥

E. 此推定易使不諳法律之人侵认孫登記、儀式双軌並行制度

F. 民诉§574II (已刪) 原有規定，§982II 无要剝奪法院得審証据之取权

G. 結婚、离婚條件不一致

3、現行法（96修，97施行）（親屬施§4-1）

(1) 書面為之：得不由本人親自書寫，但須親自簽章（§3Ⅰ、Ⅱ）

(2) 2人以上於書面上簽名

A、証人得為任何人，結婚之效力不因人別而有影响

B、簽名不限作成証書時為之，惟必須親見或親聞双方当事人有結婚之真意（SC 28 渝上353例、68台上3792例、高院10家上212）

C、簽名須親自為之，不得以蓋章代替之，蓋章不可確认人是否係本人為之

D、年齡在18岁（於現行法下无事執必要，皆為18岁）

(A) SC 51台上551例：一般：須有行為能力（20岁）

(B) 林：解釋上不宜要求过嚴，具備了解婚姻之意义即可，又証婚非結婚对本人在利害关係，无須法代同意，当達法定結婚年齡之即可（18岁）

(3) 双方当事人向戶政机关為結婚登記

A、結婚登記有公示效果

B、舊戶籍法§35：当事人一方申請即可（現戶籍法§33Ⅰ但），僅具報告意义，对婚姻效力不生影响，由現行為創設登記

C、修正前登記但无效之婚姻，不可因新法改採登記婚役而補正成為有效

D、登記行為有行政程序行為之性質：行程§22Ⅰ⑤限制行為能力人因身分行為不可代理而可认其理結婚登記時有行政程序上之行為能力

二、実質要件

人舊法

(1) 封建社会：父母之命，媒妁之言，无須过問当事人間意思

(2) 大理院2私訴上2：应由祖父母、父母主婚，但无者從父親主婚。是婚姻不備此要件者，当然在可以撤銷之列

(3) 大理院8上236：父母為子女主婚，若尚有直系尊親属在堂，应秉承其同意

(4) 大理院7上298：祖父母、父母但在又係同居者，自应由父母主婚，惟依家政統於一尊之义，亦应得祖父母同意，否則祖父母得予撤銷婚約

(5) 大理院9上776：主婚之权应由父母行使，祖父母之主婚父母不知者，自得撤銷其婚約

(6) 4民律親属編草案§24Ⅰ：結婚須由父母允许

(7) 14民律草案親属編§24：家属為婚姻須得家長同意、§5Ⅰ：未滿30岁者尚須父母之同意，父母双方亡故或事实上不能表示意思者，須經祖父母允许

(8) 17親属法草案§16Ⅰ：結婚由男女当事人自由決定，男未滿25岁，女未滿21岁者須父或母同意，父母死亡或不能表示意思時，須得監护人同意

2、現行法

(1) 憲法§22 保障婚姻自由（其他自由及权利），但非无須任何要件，民法為求公益或保护当事人利益，仍有限制

(2) 結婚合意

A、身分行為不以完全行為能力為必要，以有意思能力為已足

B、結婚意思能力：当事人能理解結婚之意义及效果之能力（林、戴）

(A) 31院2372：7岁以上，有結婚之意思，由法代主持婚礼，並具§982之方式，自应生婚姻效力

(B) 模、戴、戴炎辉：非以年龄全为准，实质上婚姻意思能力因人而异⇒应为7岁以上+有结婚能力+有结婚意思

C、受监护宣告之人

(A) 通：回复正常状态时有结婚能力；§984反面解释：受监护之人得与监护人外之他人结婚（林）

(B) 回复时须经法代同意？〈肯定说（戴、林、模）：保护受监护人⇒类推§10-6
否定说（林、戴）：未明文，政策说则无撤销规定，且应尊重有结婚能力之人+§1006於§16删除

D、欠缺

(A) §987通谋虚伪无效

(B) 史：若其後实行婚姻及同生活，则其无效已被治愈，成为有效

E、当事人合错误（重大客体错误）、他方同一性错误（ex：甲与乙欲结，误与对自赠而结）

(A) JP §742①：无效

(B) 史：适用民总为得撤销之原因，因无明文为无效

(C) 模、戴、林、洪遜欣：无效，§88为保护表意人静之利益，交易的动之安全及法益生活之实效性，此处无关交易安全，而係当事人人格权§88

F、§996：有结婚能力之人於无意识或精神错乱中所为者，非§75无效而係得撤销

(3) 非作欺或被胁迫（§997得撤销）

A、诈欺行使他方陷於错误而与之结婚，即属作欺结婚，作欺方若无结婚意思⇒欠缺结婚意思，婚姻无效

B、错误事项须主观上重大，客观上相当重要，以社会通念判断之（通）

↳ex：正直、亲切、勤勉、性格、嗜好等，当事人本身难以预测⇒非撤销原因

C、不限积极行为，故意隐瞒之消极不作为亦属之（SC 75年上2176、69台上641）

↳SC 21上2961例：不得离婚，仅得撤销 / SC 70年上880例：隐瞒婚前痼疾（精神病），难谓非作欺

D、第三人作欺（媒妁之言传达⇒使一方陷於错误）

(A) 比照§92 I但说（罗鼎、胡长清、戴、模）

(B) 限缩§92 I但说（史）：以他方恶意为限，等同与第三人共谋，无保护必要，若为善意则非作欺，应以单纯错误撤销

(C) 均得撤销说（曹杰、郭振恭、林）：(A)过苛+§997係特别规定，不适用民总，扩张解释为含第三人作欺

E、胁迫：均得撤销，无论本人或第三人为之

(4) 违法定结婚年龄令（~112：男18，女16；112~：男女18）（§980）

(5) 旧法：未成年须法代同意（§981），是否有行为能力，再所不问，仅考虑有无20岁。§99-1但之除斥期间事指§981⇒适反§980时无适用（SC 29渝上555）

A、同意权属亲权，须父母共同行使之（§1089 I），为重大事项，意思不一致则得请求法院决定

B、同意非要式⇒刊登喜事、发喜帖、筹备婚礼等均属之

C、无正当理由拒绝

(A) 法院裁判代同意：亲权之行使应以未成年子女最佳利益为优先考量（戴、胡长清、模）

(B) 亲属会议决定（罗鼎）

(c) 同意权为法代权利，亲属会议不在越俎代庖，亦无僭裁判（纵论漠清、36院解3379）

(D) 同意权滥用可以§1014撤销可由法院驳回其诉（振、林）

(6) 非近亲婚亲（§983禁婚亲）

A、直系血亲（§983I①）

↳直系法定血亲拟制关系终止后未同（§981III+981I①）

B、旁系血亲6亲等以内者（§983I②本文）（25院1842与民法矛盾，应予废止）

↳旁系法定血亲4、6等不在此限（§983I②但）（SC32上2346与现行§983I③但相违，应不再援用）

↳74§983I③：辈分同，於8亲等内他表兄弟姐妹不在此限

↳87§983I③：辈分同，於8亲等内他6、8亲等之表兄弟姐妹不在此限

C、终止收养后旁系可结婚（J12、32於现行法不实益想像，无存在必要）

D、直系姻亲：消灭後仍受限制（§983III、983I①）

E、旁系姻亲5亲等内且辈分不同（§983I③），87§983II消灭後仍有适用

(7) 无监护关係（§984）

A、§984但通常无适用之余地（未成年人之监护多因父母不能行使亲权而生）（戴）

B、父母亦得以遗嘱指定监护人同时同意结婚（林、模史、胡振清、罗鼎）

C、同意权非基於亲权，而係父母资格当无亲权时仍有同意权（林、史）（ex：§1055-2）

D、行使同意权不一致当类推§1089II请求法院最佳子女利益酌定之

E、养父母死亡後之同意权行使

(A) 本生父母无同意权说（林、戴）：收养中，本生父母与子女之权利义务关係处於停止状态（§1073II）

(B) 本生父母行使说（史）

F、委託监护（§1092）：无适用此条必要（通），结婚仍须法代同意（少权；罗鼎）

G、先订婚，後成为监护人当父母已同意婚约，无再对结婚有反对之理，可视为已同意（罗鼎、胡振清、林），同意係禁止之免除，非效力之补充（史）

↳模、戴：婚约与结婚效力不同，应贯彻§981、984立法意旨，宜解为辞去後必得结婚，受监护人仍得後任监护人同意

(8) 非重婚或同时结婚

A、J554：通姦告诉↔J791：通姦罪（刑§239）违宪

B、刑§237重婚罪

C、订婚而与他人结婚者非重婚（SC29渝上737例）

D、死亡宣告後一方恶意仍构成重婚（家事§163）

E、同时结婚：无前後婚之分当一人与二人以上同时结婚

(9) 非不能人道：无法为性行为（ex：无阴、石女）

↳22院839：依§995请求撤销，不适用§1052②

贰、无效

一、无效与不成立：(102民诉§368) 现行家事§52Ⅰ 明文婚姻存在不存在之诉 (成立不成立之诉)

1. 不区分说 (戴、林)：注张方法、效力皆同，无区别实益，且自始无婚姻存在即无效

2. 区分说 (史振、林、SC、台中地院101家诉330)：不成立=无治愈可能，不因追认、同居而变为有效；法律行为不成立係未备成立要件，无效则已齐备但欠缺生效要件

二、事由 (§988)

① 不具備§982之方式 (§73)，§988①形同注意规定

② 違反§981禁婚親 (§71)，§988③形同注意规定

③ 違反§985重婚

1. J362 (83.5.27)：善意重婚後婚姻效力应予维持

2. J552 (91.12.13)：须後婚姻双方皆善意无过失才可维持，此前之重婚人有过失而相对人善意无过失之重婚仍為有效

3. 96§988③增訂当但限信赖两願離婚登记或離婚確定判決，信赖死亡宣告有家事§163Ⅰ但 (舊民诉§41)
↳ 類推§988-1 or 解釋論

4. 院§4-1Ⅱ 溯及J362公布後之重婚当然無効J552部分見解

④ 其他事由

1. 限制说 (舊学说、黃石昌、昔傑、李姐琛、胡振清)：除非万不得已否則不得為无效，影响極鉅 (陳顧遠) ⇒不適用总則，僅適用親屬法 (羅鼎)
=列举说

2. 非限制说 (新学说：史、戴、模、林)：仍有§71、72、73、86等，尤其附解除條件之婚姻 (§72)、代理之婚姻、通謀虛偽
=例示说

三、效力

1. 有確认利益者即可诉請確认无效

2. 无須經判決即為当然无效，而判決对第三人亦生效力 (家事§51Ⅰ) (通)

3. J362 (步)：重婚於判決前為有效，須經判決後始无效 (宣告无效说，非自始无效说) (林反对)

叁、撤销

一、事由為法條例举

1. 未達法定年齡者 (§989)

(1) 撤销权人：当事人 or 法代 (§989本文)

A. 已得同意不影响撤销权 (SC 22上1083例、29渝上555例)

B. 行使撤销权无須法代同意 (林、戴、史、模)

(2) 消滅原因 (§989但)

A. 当事人達法定年齡者

(A) 27院1783、32院2468：双方均須達法定結婚年齡方能不受拘束

(B) SC 32上6006例：指提起請求撤销之诉時而言

(C) 32院2087、SC 32上3477例：诉訟繫屬中始達法定年齡者，撤销权不受影响 ⇒結婚年齡之以起诉時為準

B. 已怀胎者

(A) 目的：保护胎儿利益

(B) 已怀胎：起诉前已怀胎，无论婚前婚後、已怀胎或已分娩

(C) 起诉後始知怀胎 ⇒ 法院驳回其诉；起诉後始怀胎则不影响撤销权 (SC 31、6.16決议)

2. 未成年未得法代同意 (已删1990)

3. 监护人与受监护人於监护关係中结婚 (§999)

(1) 撤销权人 (§991本文)

A. 受监护人

(A) 未成年人：因结婚有完全行為能力 (舊§13III) ⇒ 有程序能力，起诉无须法代同意 (現家事§14II直接有程序能力)

(B) 受监护宣告之人：应证明有意思能力才有程序能力 (家事§14III)，惟须选任程序监理人 (家事§15II)

B. 受监护人之最近親属

(A) 无论血、姻親、親系，採親等最近说 (胡、盧、黃石、林、楔)；修法後親属会议已非监护监督机关 (批评：素未往來者有撤销权甚不合理)
↳ 仍保护弱者規定，不应过度限缩

(B) 具親属会议资格者说 (舊、戴、史)：親属会议係保护受监护人及监督监护人之组织 ⇒ 僅限血親
↳ 戴：撤销权人以一人為限，順序由§1131定之，若有权人则一人请求即為已足

(2) 消滅原因 (§991但)：結婚逾1年 ⇒ 除斥期間 (形成权)

4. 結婚時不能人道 (§995)：他方得撤销；除斥期間 (SC 21上1616修1)：3年 (§995但)

5. 无意识或精神错乱中結婚 (§996)

(1) 除斥期間：常態回復後6月

(2) 楔：无意识、精神错乱均屬欠缺意思能力 ⇒ 宜作為无效事由

(3) 戴：Ger舊婚姻法§18I值得參考，若无效則使保护婚生子处之目的丧失，得不溯及，惟仍应尊重当事人有无继续婚姻之意

6. 被作欺或胁迫 (§997)

(1) 除斥期間：發現作欺或胁迫終止後6月

(2) §997為§93特别規定 ⇒ 不受§93但10年之限制

二、效力

1. 須以诉为之

2. 判決確定後始生撤销效力

3. 避免法律关係後续複化 ⇒ 不溯及既往，僅向後失效 (§998)

4. 舊法24院1382：未達法定年齡者，未撤销前有完全行為能力
↳ 戴：已達法定年齡之未成年人不因撤销丧失行為能力 (24院1382)
↳ 林、史、楔：撤销不溯及既往 ⇒ 取得行為能力後不再回復限制行為能力 (舊§13III应限縮解釋為已達結婚年齡之未成年人)

肆、損害賠償 (§999)

一、財產上損賠 (§999 I)

1. 得向有過失他方請求，已方不問有無過失 (§999 I)

2. 過失非侵权行為上過失，而係对造成婚姻无效或得撤銷有相当因果关係而言

3. 損害須与婚姻无效或被撤銷有相当因果关係

4. 請求权人不限原告方，被告亦得求償 (ex:他方配偶、法代、最近親屬起訴) (史、戴、林)

二、非財產上損賠 (§999 II)

1. 須己方无過失，他方有過失；双方皆无過失、有過失均不得請求

2. §999 III：一身專屬

伍、離婚相关規定準用 (§999-1)

一、結婚无效 (§999-1 I 準用→§1057 贍養費、1058 剩余財產分配) (无§1055~1055-2 監护权 因自始无效)

1. 子女无法受婚姻推定，若因終止事实上夫妻关係而无法共同生活；对子女有§1069-1

2. 欠缺婚姻意思 无效；无共同生活事实；无§1057、1058 之準用 (林、楊)

二、結婚經撤銷 (§999-1 II 適用→§1055~1055-2、1057、1058)；§999 已明訂損賠，故无§1056 之準用

陸、重婚例外有效之处理

一、前婚姻視為消滅 (§988-1 I)：前婚姻消滅時点 {善意再婚時消滅说 (戴、梁、雄)：避免一方濫用死亡宣告解消婚姻；死亡宣告時消滅说}

二、準用離婚效力相关規定 (§988-1 II 本文)，準用範圍：同§999-1 II

1. 法律另有規定＝§988-1 II 但、III~VI

2. 剩餘財產分配請求权 (§988-1 II 但)：§988③但~後婚姻成立時

(1) 贊同主法说 (林)：无共同生活事实，对婚姻无共同貢獻；不得另行主張 (§988-1 II 但主法理由)

(2) 有§1058 適用说 (戴)：仍得主張分配，以補償前配偶犧牲其婚姻之代价

3. 剩餘財產分配請求权时效 (§988-1 III)

4. 損賠 (§988-1 IV~VI)

柒、748施行法

一、禁婚親 (§5)：同民法，但条条禁婚親範圍較小

二、不創造姻親关係 (748施§5立法说明)；本條之姻親係指曩性婚姻下之姻親关係 (748施未準用§983)

捌、普通效力

一、称姓

1. 舊法 (87§1000)：冠夫姓、贅夫冠妻姓

2. 現行 (§1000)：各保有本姓，書面約定可冠姓，冠姓可回复本姓，以1次為限

(1) 有書面約定但无登记，不生效

(2) 回復本姓時，无須書面約定，且僅冠姓方一人向户政机关单独申请即可

(3) 離婚

A、Ger§1355、Swizz§119、JP§767：准许恢冠姓

B、林：称性质婚姻普通效力→離婚使婚姻消滅→无称姓問題→户政应主动辦理

C、林：配偶死亡，无义務回復本姓，若冠姓一方再婚，登记时户政应去除其原冠姓，以免姓氏紊雜化→应明文规定以杜爭议

二、同居义務

1、互負同居义務（§1001本文）

(1) 於婚姻成立時發生，原則於婚姻消滅前繼續存在

(2) SC23上937例：僅订婚未結婚无同居义務

(3) SC25渝上2469例、29渝上916例、32上1411例：婚姻撤銷前仍有同居义務

(4) 同居：夫妻共同生活，非場所上之意义→同住一屋分別生活不合

(5) J452：住所：僅決定法律效力之中心地，非履行同居之唯一处所，履行地亦不限住所

(6) 得請求法院裁定命其履行（家事§3V③成類、家事§74、家事審理細則§95I③、§96）→不得強制（家事§126II 準用→強執§128II）→調解先行主义（家事§23）

(7) J18：裁定生效後仍不履行→§1052I⑤惡意遺棄得作請離婚之原因

2、不能同居之正当理由（§1001但）（SC95台上676：依双方背景判斷）

(1) ex：未設居所，无從同居，自无同居义務，反而得請求設定住居所；与他方不堪同居；不宜同居如就医；取业上需要 J452

(2) 依法令不能同居：入獄、服兵役（吳、林）

(3) SC18上2641例、29上254例：妻受夫家屬虐待，不願与其家屬同居，願与夫同居，有甚酌餘地

(4) 21院770、SC23上1061例、J147：夫納妾屬正当理由

(5) 夫惡疾（SC29上916例）、妻攜財產回娘家（33上6344例）、宗教（28院1878）皆非正当理由

(6) 双方均不得以家屬地位請求由家分離→无§1127（林、戴、SC29渝上527例）

(7) SC91台上921例：別居時妻不得請求生活費，但未納妻未經事同意，可請求別居与生活費用

(8) 抗辯 or 起訴

A、積極請求救济（楔、戴、作淯林、SC20上1659例、21院770、舊家務）

(A) 不請離婚係因日後尚有和好希望→可請求先別居待事由消滅，与人倫秩序无違→得作請之（楔）

(B) 仍存疑婚姻之程度：離婚＞別居→举重明輕 应允起訴

(C) 破綻主义為立法趨勢，除非仍拒採為離婚原因，否則承认別居制度係遲早，无明文則应先肯认之，可以一般程序处理（作淯林）

(D) 戴：準用关於同居之訴程序

(E) 楔：同居之訴係結付之訴，別居性質与離婚類似→準用離婚程序

B、消極抗辯权说（巫、史、J147、SC70台上1904；例外财产上抗辯权，观民诉§568Ⅰ、572Ⅰ僅有同居之诉和无别居之诉自明、林）

(A) §1001但僅暫时免除同居义務，雖得為抗辯理由，仍不得請求之（羅）

(B) 欲把诉时可提確认其有无拒絕同居权之诉，僅有確认之诉，与别居之形成判決不同→法院不得令定期或无限期别居（史）

(C) 无最長期間規定→一次别居終生别居，且别居判決特因事由消失而失去正当性（林）

(9) 約定免除同居义務：有效（通案）；否定说（林）：違反强制規定无效，且同居屬共同要素

A、史、林：一時别居有時反而達和平，故无害婚姻即可认有正当理由得使免除义務不履行責任，应认有效（通）

B、SC 17上28例：有不堪同居之事实，双方同意分居非法所不许

三、住所之決定（§1002）

1、舊法：74§1002 妻以夫之住所為住所，贅夫以妻之住所為住所；87§1002 增设約定但書（J452 當然通案）→現法

2、夫妻戶籍各異時，未明改，須回歸总則认定住所（林）

3、林：法院不应過度干涉，有立法上疑慮

四、日常家務之代理（§1003）

意思通知（傳达）　觀念通知（依個别通知）　情感表達（當然）

1、互為代理人（§1003Ⅰ），且非連負名代理，可代理法律行為、準法律行為、事实行為

2、日常家務：日常用品之購置、親友饋贈、報紙雜誌訂購，範圍依夫妻共同生活背景有所不同（林史）、收受文書（SC95台抗65裁）

3、SC 36上5356例、38穗上281例：处分不动產通常非日常家務，惟支付家庭生活費之必要為屬之

分居則无代理收受之权限（SC 99台上7056刑）

4、SC 44台上1026例：和解非日常家務、保全財產之作為行為、公司事務亦非日常家務

5、代理係法定代理，无傷本人一一授权（通；曹傑＝意定代理）

6、適用对象

A、及第三人说（戴、模）：家務由子女事实上之妻或妻封存者有§1003Ⅰ適用

B、限夫妻说（林）：对第三人无適用

7、无效時自始无婚姻关係，亦无日常家務代理权

8、濫用代理权时他方得限制之，但不得对抗善意第三人（§1003Ⅱ）

9、限制方式：法无明文，对第三人以意思表示為之（史、林），但不知則不得以限制对抗之

10、别居

(1) 代理停止说（戴、模、许淑林）：代理权停止，為保护第三人，应視作表見代理

(2) 代理繼續说（林）

A、§1089 惟意定代理有其適用（SC 79台上2012）

B、SC 92台簡上9：§1003与一般代理有所不同→逾越即无权代理，无§1003之適用→有无表見代理，应就有无表見事实决之

C、别居第三人未必得知

11、死亡

A、代理延長說（羅、曹、戴）：死亡有時不能及時知悉（ex:死於異地）⇒為保護此類人，有延長之必要

B、代理停止說（林）：對本人直接發生效力（§1031），本人已死，權力能力業已消失（§6）⇒無法直接歸屬本人

12、林：§1003-1可取代§1003，廢§1003，且遺囑負代理原則

五、家庭生活費用負担（SC 64台上1398：事實上夫妻得類推夫妻身分上及財產上法律關係之規定）

1、舊法：§1026、1037、1047、1048⇒夫負第一次之責任，妻負補充責任

2、現行：§1003-1Ⅱ 列家庭勞動為家庭生活費用分担方法之一，即肯定家事勞動之價值

3、家庭生活費：包含一切家計需要（ex:租賃、修繕、庭園、衣物、日用品、雜誌、報紙、裝修、僕役、醫療、車輛之維持）（SC 98台上432）

4、從事家務少者得負担較多費用，反之亦然，若夫妻間有約定，自應尊重之

5、林：依法律無踐可循，戴稱留作未來判決規定，且共同財產制下，變為公同共有（§1031），無法再有此條個別負担

六、家事債務清償責任

1、舊法：§1023③、1046③：決負清償之責 ⇒ 現行：§1003-1Ⅱ 連帶責任

2、子女衣食住行費用雖於婚姻存續中，子女之扶養費被吸收至家庭費用中，惟若單出子女扶養費用特以婚姻存在為前提不妥（林）

↳父母子女間扶養義務則與交易安全無關，非由父母負連帶責任

七、貞操義務

1、法無明文⇒通、實肯认：婚姻本質之解釋＋重婚及通姦為請求離婚之原因，間接承认貞操義務（§1052Ⅰ①、②）

2、SC 55台上2053判例：侵害他方權利、J147：夫妻內妻違背貞操義務

3、J791（通姦除罪化）後通姦之侵权行為

(1)肯定說（通、實、SC 55台上2053例）⇒§184Ⅰ、185Ⅰ前、§195Ⅰ、Ⅲ

(2)否定說（少数家務）

八、扶養義務（§1116-1）

1、生活保持義務（高度）：夫妻、父母对未成年子女

↳生活扶助義務（低度）：兄弟姐妹

2、不履行夫妻間扶養義務係惡意遺棄（§1052Ⅰ⑤離婚原因）

3、扶養義務亦有解釋认為延續至婚姻終了後之贍養費（§1057）

壹、沿革

一、清末民律草案仿 JP舊§802 ⇒ 大理院 2 上 33、2上708、7上665 ⇒ 北民律第二次草案

二、19 改 JP to Swiss ⇒通常及非常法定財產制

貳、通常法定財產制 =修正的分別財產制

一、所有權歸屬

1、19~74§1017

(1) 妻原有財產：婚前+婚中因受取得之財產 (ex：繼承)

(2) 夫妻不所得：妻之特有財產 (§1013④) ⇒非聯合財產(§1016)

(3) 妻如不能證明為特有或原有則為聯合財產歸夫所有 (SC 55台抗161裁一廢、57台上2271裁一廢)

2、74~91§1017

(1) 夫妻只有聯合財產，且妻婚中購置之original即妻之原有財產

(2) §1017Ⅱ：不能證明推定為夫妻共有之原有財產

3、85.7.26~施§6-1 (J410 要求制定) (SC 106台上2801：對過永人亦有適用，且無類推之餘地，限有明文者)

(1) 應解為妻自85.7.27起取得不動產所有權 (林、SC 88台上2816)

(2) SC 87台上2316、林：1年之緩衝期結束前夫之債權人聲請強執者應無新法適用

4、91~§1017、施§6-2

(1) 廢聯合財產，刪§1016

(2) 改原有、特有為婚前、婚後 ⇒ §1030-1Ⅰ、1017Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

(3) 施§6-2 無溯及性

A、無效說：僅為條修改，本質不變，無溯及 (戴、林)

B、溯及說：J620 原有財產不區分婚前、婚後，均為剩餘(§1030-1)財產分配請求權所及 (楊)

↳林：J620 本質上應休對舊§1030-1Ⅰ之原有財產行修釋，否定施§6-2有溯及力

二、管理、使用、收益及處分權 (§1017~1021刪)

1、19~91§1016：聯合財產⇒夫管理、管理費由夫負擔(19~§1018)／夫原則，有約定從其約定(74~1018)／各自管理、使用處分收益 (91~§1019)

2、~74§1017Ⅲ：妻財產所生孳息，所有權歸夫，74~§1017Ⅲ刪，74~91§1019：對妻原有財產有使用管理收益權，孳息於支付夫同生活費後有剩餘歸妻 (91~§1019刪)

3、~91§1020Ⅰ：夫對妻原有財產處分應得妻同意，但管理上必要者，不在此限 ⇒§1020、1021皆刪

三、債務清償責任 (§1023) ⇒舊法複雜難操作

四、財產報告義務 (§1022)：舊法⇒聯合財產制下，夫因妻之請求有即時報告之義務

五、剩餘財產分配請求權 (SC 104台上773：與過永權不同，無混同問題)

1、74~91§1030-1 增訂，91~修正文字

2、發生原因

(1) 離婚、撤銷、改用其他財產制

(2) 死亡限繼承法於生存配偶之權利義務未予適當評價前不得已之解釋 ⇒ §1030-1Ⅲ 一身專屬

(3) 无效限有关同生活存在，避免 §979 準用 §1058 造成无效但有剩餘財產分配

(4) 依法婚姻視為消滅 (§988-1Ⅱ、兩岸條例§64Ⅱ 準用 §41 適用 民法)

3、範圍 (SC 105台上1750：除有代物清償§317意外，他人无從請求特定財產)

(1) §1030-1Ⅰ：婚後財產扣除債務、无償取得、慰撫金有剩餘者 (SC 106台上2424：父母之扶養費係身分上債務，非財產上債務 ⇒ 不應列入婚後債務)

(2) §1030-2Ⅰ：婚後清償婚前、婚前清償婚後皆應計入 ⇒ Ⅱ：§1030-1Ⅰ但 清償者準用 §1030-2Ⅰ

(3) §1017Ⅲ：改法定財產制前取得視為婚前財產 ⇒ 改用前債務，應視為婚前債務

(4) 適用 74.6.4 修正前？

A. 肯定說 (許振荼、陳惠馨、SC90判671行、Ⅰ620) ↳不真正溯及既往

B. 否定說 (戴東雄、許澍林、SC81台上2315、SC行訴3.26庭長決定～95年)

4、追加計算 (§1030-3)

(1) §1030-1：消滅前五年內处分婚後財產應追加計算視為婚後財產

↳但：履行道德上义務所為 (ex：父母生日送生日礼物) 与故意減少分配額有差

(2) 处分含无償及有償行為，有償時應扣除处分所得後之部分

(3) 法不溯及既往 ⇒ §1030-3 限發生施行後，始有適用餘地 (SC 93台上1162) ↳§1020-1：准用

(4) §1030-3Ⅱ：向第三人請求，限无償或惡意不合对价；§1030-3Ⅲ：消滅時效 ⇒ 2年/5年 (SC 106台上2959：客观上足认一相知他方剩餘較多始足当之)

(5) 林：未免第三人受不測損害，應限主觀有使分配額減少及客觀上五年內

(6) 夫妻間贈與 ⇒ 无償取得說 (通)：宜由法條形式文义观察，无區分必要，保对弱勢一方有利 / 家事勞務對价說

5、計算時點

(1) 法定財產关係消滅 時為準 (§1030-4Ⅰ本文)

(2) 判決離婚：起訴時為準 (§1030-4Ⅰ但)

(3) 追加計算部分：处分時為準 (§1030-4Ⅱ)

(4) 撤銷婚姻：同為 法定財產 ⇒ 類推§1030Ⅰ但 起訴時為準 (楳)

(5) 調解和解離婚

A. SC 106台上1223：調解成立時
SC 106台上2345、103法律座談會：移送調解以起訴時為準 / SC 106台上 307、105台上254、103座談会：和解起訴時為準

B. 林：和解調解应屬兩願離婚 (家事§30Ⅰ、45Ⅰ) 非裁判離婚 ⇒ 应類推§1030-4Ⅰ本文 消滅時為準

(6) 无效：類推§1030-4Ⅰ但 起訴時為準 (SC 106台上2653)

6、顯失公平 (§1030-1Ⅱ)：依民事訴訟主張之 ⇒ 非依非訟程序主張之 (楊建華、楳、林) (SC 107台上1049)

7、消滅時效：2年/5年 (§1030-1Ⅲ) ⇒ 特別規定 (§988-1Ⅲ)，戴：§788-1Ⅲ 係除斥期間

六、保全（引增订§1020-1、1020-2）

1、有偿行为之撤销权⇒客观上有损剩余财产分配请求权且主观须恶意与受益人受益时亦属恶意为必要（§1020-1Ⅱ）

2、此保护者应係未发生之债权⇒期待权之保护，除斥期間 6月/1年（§1020-2）

七、自由处分金（引增订§1018-1）

1、夫妻協议定之⇒提案；请求→協议⇒主法者定位此條為注意规定⇒協议不成不得请求酌定

2、属§1008-1之其他約定⇒準用§1007.1008⇒須以書面為之，非經登记不得对抗第三人

3、非无偿贈与⇒若為贈与則不得此條規定，且不僅法定財產制可適用，主法理由亦肯认之（林；戴：无偿贈与；戴东雄：婚後有偿取得之財產）

4、非婚後收入、有偿取得，主法理由认应属剩余財產之提前給付⇒剩餘財產分配之額应扣除自由处分金，自由处分金以書為之，证明上无困難（林）

參、非常法定財產制（§1010Ⅰ）

一、舊法

1、当然法定財產制＝法律特別規定⇒刪§1009、1011

2、宣告法定財產制＝裁判特別規定

① 依法应給付家庭費用而不給付時（SC 58台上2632例）：限有給付义務⇒約定由夫承担，夫不支付時妻亦不得用分別財產制

② 夫或妻之財產不足清償其債務：实用性不大，改用分別財產制後对剩餘較多之他方而言未必有利

③ 应得夫妻之一方之同意所為之財產处分，夫妻之一方无正当理由拒絕同意時：指§1033而言，採法定財產制之妻，自行管理、使用、收益及处分自己之財產不適用

④ 有管理权之一方对共同財產显有不当，经他方请求改善而不改善：僅適用共同財產制⇒一方管理（§1032Ⅰ），有管理权一方有情形，他方自得请求

⑤ 不当減少其婚後財產，对他方剩餘財產分配请求权侵害之虞時：引增订⇒对纯從事劳动之配偶於改用分別財產制，恐丧失其剩餘財產分配之权利，可能不到

⑥ 其他重大事由

1、夫妻一方将自己財產移転於他人所有或任意浪費

2、財產移転之大陸，致对配偶或子女权益受有影响

3、夫妻总財產不足清償总債務或夫妻難维持共同生活，不同居已逾6月以上時（§1010Ⅱ）

↳SC 101台上 613：已明文，有責一方亦得请求

肆、約定財產制

一、夫妻財產制之訂立時期

1、婚前、婚後皆可（§1004）

2、婚姻契約為主契約⇒財產制契約為從契約⇒須婚姻成立後始生效力

二、改用与廢止

1、得以契約廢止其財產契約或改用其他財產制（§1012）

2、廢止契約後即回復適常法定財產制（§1005）

三、訂約之方式：書面為之（§1007），違反无效（§73）

四、登記

1.為對抗要件 (§1008I)，第三人不論善惡意

2.登記不影響依其他法律所為之財產權登記之效力 (§1008II) (ex:登記前已設定抵押權者不受影響)

3.程序 (非公§101~107)

五、契約性質：本質上係財產契約，但不明係債權或物權契約 (林)

六、訂約能力

1.限夫妻或將成為夫妻之人，但本質上屬財產契約→不因訂約人身分異其性質

2.~9I§1006：未成年+禁制產→應得其法代同意→經法代同意，禁治產人可為之，未成年結婚取得行為能力但仍須法代同意，後刪除

3.婚前訂約應有法代允許 (§77)，本可事後承認於結婚後生效，結婚後已有完全行為能力者自得自行承認婚前契約 (§81)

4.變更、廢止須婚後→以有完全行為能力無須同意

5.受監護人→由法代為之→法代為意則§1098II選任特別代理人代為之

七、其他約定：自由處分金 §1018-1、共同財產管理人 §1032I但、共同財產分配比例 §1041II、1040II 準用§1007、1008 (§1008-1)→書面登記不得對抗第三人

八、共同財產制

1.一般共同財產制

(1)所有權歸屬

A.夫妻公同共有 (§1031)

B.特有財產 (§1031-1)

I①專供夫或妻個人使用之物：限動產 (ex:衣帽、飾品、化妝品、個人圖書、榮譽、運動器具、印章、書本、禁)

I②取世上所需之物：永當Sutra§191II→解釋上應同其兼及營业所需之物 (林、史、楊)

I③受贈之物經贈與人書面聲明為其特有財產

(A)聲明日後結婚日贈與之物為其特有財產→日後結婚後有效 (SC 73上5號例)

(B)以受贈之特有財產之金錢購買不動產→僅受贈當物狀態變更，該不動產仍為特有財產 (SC 75年上1840號例)

II適用分別財產制 (§1031-1II)→各自保有其財產所有權，各自管理、使用、收益及處分 (§1044)

(2)管理：得約定由一方管理 (§1032I)，管理費由共同財產負担 (§1032II)，使用沒有明文，應為共同使用，收益屬共同財產為公同共有

(3)處分：公同共有之權利義務依所由規定之法律或契約定之 (§828I)→§1033I：處分應得他方同意 (含事实上及法律上處分)→未同意屬無權處分
§1033II：保存行為安全→同意之欠缺不得以對抗善意無過失第三人

(4)清償責任：債務(不論婚前、婚後)應由共同財產並各就其特有財產負清償責任 (§1034)→債權人得自由選擇以對公同或特有財產請求清償

(5)補償請求權：債務由共有財產清償者不生補償請求權 (§1037I)，以特有財產清償、特有債務以共同財產清償者有 (§1038II)，婚後仍得請求

↳~9I§1036夫妻特有債務已刪→§1038II後似無適用餘地 (林)

(6)消滅

II阻卻

ex: 共同 300萬 §1041II 抽回 -100萬 抽回 100萬

A.因夫妻一方死亡：共同財產之半數歸屬己份，半數歸繼承人 (§1039I)，另有約定從其約定 (§1039II)，有§1145I之情形不得為繼承者，僅得請求一半 (§1039III)

B.改用其他財產制：夫妻各取回訂立契約時之財產 (§1040I)；有結餘中之共同財產一人一半 (§1040II本文)

↳林：法律另有規定→§1039、1038，修法前之§1040準符合公同共有法理

2. 勞力所得共同制 (§1041 I)

(1) 勞力所得：於婚姻存續中所得之薪資、工資、紅利、獎金及其他勞力所得有關之財產收入、孳息及代替利益 (§1041 II)，不分勞力、勞心所得

(2) 勞力所得見賽彩券之所得，屬勞力所得

(3) 不能証明勞力所得或以外者，推定為勞力所得 (§1041 III)

(4) 勞力所得外之財產適用分別財產制 (§1041 IV) (ex：无償取得之財產慰撫金)

(5) §1041 V $\xrightarrow{準用}$ §1034、1035、1040

(6) 林：§1040 I 夫妻在能取回其存續中无償取得之財產 ⇒ §1041 I 解釋上應於此无準用餘地

3. 分別財產制

(1) 非準法定財產制 (§1010)、約定財產制 (§1044) ⇒ 各保有其財產所有权，各自管理、使用、收益、处分

(2) 債務清償責任 (§1046 適用§1023)

壹、婚姻解消

一、死亡(通)

1. 法无明文⇒家事§39Ⅱ、50Ⅱ、59

2. 效果限夫妻间权利义务(不解消§971,仍与他方互相负扶养义务)⇒身分解消,契约不解消(林)

二、离婚

三、撤销(§989、990、991、995~997)

贰、两愿离婚

一、旧法

1. 唐律、元史刑法志、明清律:和离、两愿离

2. 大清民律草案§43、45、4草案、14草案:两愿离婚须呈报户吏始生效力

3. 17亲属法草案§26Ⅰ:两愿离婚无证人或证书不生效力

4. 19~74§1049、1050:两愿离婚,书面+2人以上证人签名⇒移户籍登记,採自由放任態度

5. 74~§1050增列:应向户政机关为离婚登记

6. 98.4~§1052-1:调解/和解离婚=特殊两愿离婚

7. ~112.1.1§1049但:未成年须法代同意⇒法代无同意,户籍人员受理:(内政部106.3.10户秘字第1060427075:未成年无须法代同意得径自申请登记)
   ↳应认有行政程序能力(行程§22Ⅰ⑤)

   (1)有效说:JP普§801、811(楼)

   (2)无效说:25院1543:§971认无效/SC27上1064例:无似§990之除文⇒无效(史、罗、林)

   (3)撤销说:§979不生效力,非无效,§1但应类推§990(趙、戴)

二、实质要件

1. 当事人离婚意思合致

   (1)形式意思说(振、许淑林):不问实质意思

   A. 要徵登记公信力,保护第三人

   B. 林:无保护必要,观J552、§988③须後婚双方均善意无过失,後婚始为有效⇒可观点採实质说

   C. 离婚後仍一起生活者亦在所多有

   (2)实质意思说(通、SC54台上3157、58台上129):须有消灭婚姻之效果意思,若无则离婚无效

2. 当事人自行为之

   (1)係身分契约,他人不得代理(SC29渝上1904例)

   (2)SC29渝上1606:肯定使者离婚,以他人为表示机关而已

   ↳林:无行为能力人亦得为使者不当⇒均不得代理或使者为之

三、形式要件(§1050)

1、書面為之；可蓋章(§3)

2、二人以上证人之签名

(1)目的：确保当事人真意，防止被迫离婚（戴、楼、林）

(2)签名不得以章代之（通；反对：SC 42台上100例）

(3) SC 28渝上353例：证人无须与当事人熟识

(4)签名不限於作成离婚时为之，本不限协议时须在场，未亲见亲闻离婚真意者不得为证人（SC 68台上3792例）

(5)他方於签名时尚未同意，证人自属不知离婚真意，当场签名，视法定要件而不生效力（SC 69第10次民庭决议(二)）

3、向户政机关为离登记

(1) SC 50台上60：户籍法雖有公法性質，惟其僅為户籍管理上要求，得请求登记，属私法上请求，得為标的

(2) SC 79.9、戴、楼、林：有書面及签名他方拒不登记，无合法离婚事实，无请求之诉之法律依据

(3)若载明願登记，一方反悔时视為预约，类推§75（林、戴秉雄）；買微登记為缓衝期間之立法意旨，他方不可诉请

(4) 97.5.22前仪式婚结婚之离婚程序

A、先结婚登记说：应有登记或提出已结婚之证明（戴）+登记

B、无须登记说：以舊法，有二人以上证人之签名，則不問登记，均应认有效力（楼）

C、离婚登记说：施行前仍有户籍法，若違反規定但可免為离婚登记不妥，買微公益性之立法目的（75.3.10(75)林、廳民一字1405号函）

4、不備时均以§73无效

四、撤销、无效（通）：法定事由，类推婚姻无效或撤销

參、調解/和解離婚

一、舊法

1、77.10.11(77)院台廳一字07035号函：離婚起诉前应经法院調解，不得成立离婚之調解

2、77.8.23(77)院台廳一字06029号函：法院於辦理请求離婚事件時，不得為诉讼上和解離婚

3、77.10.4(77)院台廳一字06865号函：法院对送核定之乡鎮市區調解委員会之同意離婚調解書，不应予核定

二、現行法(98§1052-1)

1、家事§30Ⅰ：調解须当事人意思合致，Ⅱ：調解成立与確定裁判有同一效力

2、本質与兩願无不同，兩願係当事人合致，惟調解則以調解委員之介入或法官之介入使本无離婚意思之一方生離婚意思

3、家事§45Ⅰ：诉讼上和解须当事人表明合意，Ⅱ：作成和解筆录与確定判決有同一效力

4、林：对調解及和解有疑慮，法官於处理时，依职权調查後，若认不宜進行和解者，应為不同请求

5、具形成力→不以登记為生效要件

肆、裁判離婚

一、舊法

1. 自古七出、父母兩願，七出：无子、淫逸、不事舅姑、口舌、竊盜、嫉妒、惡疾

2. 大清民律草案：保留兩願，另從 JP 引入裁判離婚（列舉理由）

3. 民4、14、17草案：列舉理由

4. 大理院 6統 576 ⇒ 父母一詞轉為訴請離婚事由（戴炎輝、林）

5. 19~76 § 1052：列舉原因，不問婚姻有无破綻

6. 74 § 1052 II：概況括規定 ⇒ 兼採抽象的破綻主義

7. 96~ § 1052 I：微幅修正

二、列舉事由（§1052 I）

① 重婚

1. 无論國內外、善惡意，不以構成重婚罪（刑§237）為要件

2. 通常構成舊法之通姦，亦不以此為要件，无須証明有通姦事實

3. 妻非西乙偶，於內妾不構成重婚，但構成通姦（20院467）

② 与西乙偶以外之人合意性交

1. J534：忠誠義務

2. 舊法（~96）：与人通姦者

3. 性交：刑§10 V，含同性間性行為

4. 以双方合意為必要，若強制則僅⑩or II 有適用

5. 夫妻同居構成§1052 I ②（SC 22再5例），以此為由請求離婚不以有通姦罪為要件 ⇒ 妻不告而請求自无不可（SC 28滿上2477例）

6. 訂婚後結婚前為之僅有§976 I ⑦，不得以結婚後請求離婚（SC 33上294例）

③ 不堪同居之虐待：給予身体或精神上不可忍受之痛苦致不堪同居者

1. 須客觀達此程度，不得依主觀見解任意請求（SC 34上3768例），此客觀應斟酌當事人背景定之（SC 32上1906例）

2. 不堪同居之虐待：危及婚姻关係為基礎，逾越通常能忍受程度、侵害人格尊嚴与人身安全（J372）

2. 身体上之虐待

(1) 慣行毆打，不重視其受傷程度（SC 19上1128例、20上371例、27上2111例）

(2) 偶然毆打＋受傷較重（SC 29上955例、31上2737例），受傷輕減主（SC 20上2341例、32上1906例）

3. 精神上之虐待：对他方重大侮辱

(1) 夫迫妻為娼（SC 21上834例）、夫姦淫生女（SC 63台上1444例）、強命下跪，頭頂盆鍋（SC 69台上669例）

(2) 逼親他人通姦（SC 23上678例、40台上1276例）、謀害（SC 32上1701例）、竊盜（SC 46台上1719例）致他方身陷囹圄

(3) 叛国附敌

A. 肯定说(34院2837、SC37上7545例、45当上1433例):叛正前对归此所受精神上痛苦,实较受不堪同居之虐待过无不及⇒类推

B. 否定说(37院解4-66):共党活跃各地,不甘附逆,与否款不符

C. 林:精神上痛苦上程高度痛苦⇒属上加属解释维增推⇒直接适用即可,无须类推

4. SC23上4554例:行为不检,他方一时激愤致过当行为时不该当⇒应就该行为判断有无侵害他方人格尊严及人身安全而危及婚姻之维繫

④ 直系亲属之虐待或受虐待(3次修正)

1. SC31上1949例:虐待含身体及精神上虐待

2. SC44当上26例:须客观达不堪继续生活之程度

3. SC49当上199例:直系以外亲属无适用余地

4. 直系亲属

(1) 广义说(史、SC33上4279例;总4):含直系姻亲

(2) 狭义说(戴、褚、林):不合时代思想、立法理由参考昔JP§813①、③,而JP之直系等亲属解为不含姻亲(德民亲属通说),由比较法可得採狭义说

⑤ 恶意遗弃:客观遗弃事实+主观遗弃(SC40当上91例)

1. 主观要件:须主观有恶意,恶意非民法上之知情与否,而係故意或害意,故意含刺探故意(林、戴、史)

2. 客观要件

(1) 不履行同居义务(§1001)

A. 否定说(21院750)

B. 肯定说(通、SC29上258例、40当上91例、49当上90-1例、49当上1233例、J18)

(2) 不履行家庭生活费用负担义务(§1003-1)

1. SC22上9220例、39当上2135:无正当理由不为支付致他方不能维持生活

2. SC39当上415例:无支付能力即无义务违反,自不该当

3. SC49当上1251例:一方犯罪逃亡在外,本与有资力无正当理由不为给付有别⇒不该当

(3) 不履行扶养义务(§1116-1):他方无维持生活能力,未尽扶养义务者,即属之

(4) 逐出行为:逐出家门使其不得不离住家並拒绝再返家⇒客观上有同居义务违反+主观上有拒绝同居意思

3. 於继续状态中(林:客观要件):解释应有相当时间,一时之离去,虽有遗弃事实,他方尚不能作请离婚(通、SC33上948例)

⑥ 意图杀害他方

1. 意图:与刑法不同,指近於故意⇒证明故意,概预备、未遂、教唆、不能犯均该当(通)

2. 知悉他人欲杀配偶而不告知

(1) §1052Ⅰ③精神虐待(史)

(2) 类推§1052Ⅰ⑥(褚)、另有人以有无暗中扶持作判准(孙、褚)

(3) §1052Ⅰ⑥(林):不告知即有意图,无须类推

⑦不治之惡疾 (立法目的：恐危害家庭健康，故於目的主義下，犧牲某上惡疾之不幸一方)

1、惡疾：於人身体机能及健康有所障碍者，而為常情厭惡之疾病 (通)，ex：梅毒 (SC 31上3110例)

↳ 双目失明 (SC27上2724例)、蹄人自擊 (SC 30上1798例)、強姦 (SC 33上6681例)、不孕症 (39院解2945) 均非惡疾

2、不能人道

(1) 否定说 (22院839、SC29渝上1913例)：僅有§995，无§1052⑦

(2) 肯定说 (通)：74前僅列婷ヨ应從寬解釋，不僅由种族得生，应由婚姻目的观察

↳ 新法 (通、SC 83.4.19第4次民庭決议)：以§1052Ⅱ诉請即可，因不能人道可能形成難以維持婚姻之重大事由

3、結婚前發生

(1) 否定说：除合於撤銷外，无据以離婚之餘地 (SC 22上422例)

(2) 肯定说 (通)：此屬人之性質的要求ヨ不告知屬詐欺ヨ§997，但6月限制ヨ不足保护ヨ目的解釋应肯认

4、不治：不以絕对不能治癒為伊要，而以医學上於預見之期間內不能期待其治癒者為已足 (史、模、林)，是否須一定時間应視惡疾態様不同判断

⑧重大不治之精神病

1、精神病：精神得生法施细§2Ⅱ ヨ 24院1355：聾、盲、啞非精神病

2、須達重大不治程度ヨ重大：婚姻关同生活已至不能忍受程度；不治：同⑦

3、判断不治之程度須经相当時間治療及观察，於此期間內，无從患者有失当行為，不能认他方受不堪同居之虐待 (SC 33上5635例)

4、基於目的主义而规定ヨ不問發生原因 (SC 33上5777例)

5、監护宣告不影响他方之離婚請求权

⑨生死不明已逾3年

1、生死不明：離家後杳无音讯，无從確知其生死而言 (SC 62台上85) ヨ戰事交通阻隔，一時无從探悉行址不該当 (SC 47台上53例)

2、離婚判決確定時不確知死亡ヨ視為诉訟終結 (家事§51前/舊民诉§580)，同時丧失離婚請求权

3、生死不明一方於言词辩論終結前已返家時，法院仍不得据以判決離婚 (SC 22上1116例)

4、3年起算点：自证明生存或可使推定生存之最後事实之時起算，亦即自最後音讯到達時起算

⑩因故意犯罪判处有期徒刑逾6月確定

1、舊法：一方被处三年以上徒刑或犯不名誉之罪者，他方得請求離婚

↳ 不名誉之罪不明確，犯罪本即不名誉，又3年过長，故改6月

2、限故意犯，过失犯不屬之，且应认无期徒刑亦有適用 (林：应刪有期)

3、竞合 (①、⑧、⑩)

(1) 排斥⑩说 (史、模)

(2) 自由選擇说 (戴、林)：除重婚外尚有不堪同居之虐待及意图殺害他方ヨ離婚原因各自独立存在ヨ有权自由選擇適用⑩或合併主張

民國 111 年地方法院離婚終結事件(共2532件)

離婚原因1052	①重婚	②與他人合意性交	③不堪同居之虐待	④與方系親屬相互虐待	⑤惡意遺棄	⑥意圖殺害他方	⑦不治之惡疾	⑧重大不治之精神病	⑨生死不明已逾三年	⑩因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。	難以維持婚姻之其他重大事由
件數 2924	0	10	41	1	229	1	2	2	3	24	2219
百分比%	0	0.4	1.6	0	9.0	0	0.1	0.1	0.1	0.9	87.6(漸增)

三、抽象之离婚原因（§1052Ⅲ）

1、破綻主义之採用（未完全採破綻主义⇒消極破綻主义）（SC 106号上602：应以客观标準判断是否任何人均将丧失持续婚姻之意欲）

(1) 不以破綻发生可归责於一方为必要（模、戴、林）

(2) 无一定标準⇒增加法官调查之负担，亦侵害個人隱私，徒增当時人困擾（林：外國立法例多以別居为破綻证明，值參考）

2、§1052Ⅰ排斥§1052Ⅲ⇒主張§1052Ⅰ.Ⅱ時，应先审查Ⅰ，若皆无再以Ⅱ判斷（SC 86.34民庭決议）

3、有责配偶離婚请求之否定（§1052但）⇒双方均有责时（自己清白法理=潔手原則=clean hands）

(1) 事实者有请求权说（模、SC 95.4.4第5次民庭決议的号上26訂、60号上2677）：有责程度相同者，双方均得请求離婚（Swiss 1907§142Ⅱ、JP SC 昭和30.11.24（1955））

(2) 双方均有请求权说（林）：Swiss已修法，且前说係破綻主义之自我否定，而兼具有责主义之缺点⇒立法既有不当，应限縮文义範圍

4、ex：与異性交往过密但无法证明通姦、虐待未達不堪同居、不能人道、甚淫无度、受对方直系姻親虐待、性格極端不一致、一定時間以上別居

四、不得请求之情形

1、事前同意：与真操义務相关者⇒§1052Ⅰ①.② （SC 26上794例：无effect事同意亦同）

2、事後宥恕

(1) 事前同意属意思，事後宥恕属感情表示（準法律行為）⇒同意乃防止離婚诉权发生之原因，针对構成離婚之行為为之；宥恕乃消滅離婚诉权之原因，针对離婚原因之自身为之（胡長清、林）

(2) 认识事实发生而听任之，不足為宥恕，須有於婚姻生活上宽容之積極行為（史、模、林、SC 91号上352）

(3) 不追究刑责、撤回告诉≠宥恕（模、74廳民(一)字050号函）、SC 28渝上2477例、林）

3、除斥期間（§1053 6月/2年 、§1054 1年/5年）

(1) 起算：知悉時起算（SC 28渝上2477例），連续通姦以数现知悉最後通姦時起算（SC 29渝上172例），客观上以最後发生時起算（SC 32上5726例）

(2) 属形成权⇒除斥期間非消滅時效（通、SC 33上4886例；反对：黃右昌）

4、请求权拋棄

(1) 離属身分上权利，非不能拋棄，无違公序良俗即可

(2) 須权利人知有请求权存在而将权利拋棄，始生失权之效果⇒属法律行為（史、模、林）

↳宥恕无須知悉权利存在為必要，只要表示原谅不究其责即法律上当然发生失权效果，属準法律行為

5、夫妻一方之死亡

(1) 離婚一方於诉讼前死亡⇒被告適格者已不存在⇒他方已无從请求離婚

(2) 家事§51：於判決確定前夫妻死亡時，该離婚诉讼视為終结

6、民法以外之限制

↳家事§7前：有关婚姻关係之诉讼，经判決確定後，当事人不得再援引前诉之合併、变更、追加或反请求所得主張之事实，提起新立之诉

↳基於该诉讼中未曾主張之原因之離婚请求权，亦歸於消滅（史、林）

五、112憲判4：§1052但部分違憲（原則|合憲）⇒僅不许唯一有责之配偶一方请求裁判離婚且須有期間限，非一但有责即終生不得请求

↳修法建议：分居条款入、特殊狀況排除裁判離婚（ex：未成年子女利益）、須有配套措施（ex：无责配偶補償、未成年子女生活保障）

↳行政院114.2.20草案：分居條款+总则公平條款

肆、效力

一、身分上效力

1. 身分關係消滅

(1) §971：姻親關係、夫妻身分、夫妻間權利義務、改冠姓

(2) §1001~1046、1116-1、1138、1144 均消滅 ⇒ §1114①、1116-2、1138① 仍繼續存在

2. 未成年子女

(1) 舊法

A. ~85 §1051：兩願離婚由夫任之，有約定者從其約定

B. ~85 §1055：判決離婚準用 §1051，但法院得為子女之利益酌定監護人

C. 85~ 刪 §1051，修 §1055，增 §1055-1、1055-2

總計	父	母	父母共同	三親等內親屬	社會福利主管機關
1318	321	835	154	6	2

Q. 為何母親較多？判決實證顯示「幼兒從母」+子女意願

(2) 現法

A. 父母約定 (§1055 I 前：協議由父母一方或雙方共同為之)

B. 法院酌定 (§1055 I 後：得為約定或利害關係人或依職權酌定之) (SC 114台抗503裁 ⇒ 共同監護之酌定)

↳ 主管機關：兒少保障法 §6 所稱之⇒中央衛福部，地方縣市政府/福利機構：兒少保障法第五章 (模、林)

C. 親權人之改定 (§1055 IV、III)

(A) 舊法：~85 無規定，但 通、SC 81台上418、82台上1888 均肯定

(B) 負担權利一方未盡保護教養或對其有不利情事，利害關係人得請求法院改定之 (§1055 III)

(C) 未成年子女本可請求 (家事§141 II) ⇒ 7歲以上有程序能力 ⇒ §1055 IV 之未成年子女係指7歲以上者

D. 法院酌定權利義務行使負担之內容與方法 (§1055 III)：徒成具文 因親權係法定法院不得創造或酌定 (林、李玲玲)

E. 會面交往 (§1055 V) (SC 105台抗66裁)

(A) 未立法前，宜肯定 (參考外國立法例及兒童權利公約)

(B) 性質：基於親子關係所生之自然權，不待規定即存在，係父母、子女皆有之權利

(C) 會面權主体：未任親權人一方及子女

a. <7歲：任親權一方得本於法代身分，為子女利益向法院請求酌定方式及期間

b. ≥7歲：對改定具非訟能力，自得自行請求方式、期間 (如拜訪、電話、旅遊、住宿)

c. 法院无監督權 ⇒ 當事人无請求无法發動非訟程序，无法依職權變更現狀

F. 酌定時之應注意事項 (§1055-1)，參考 刑§57 ⇒ BIDC、幼兒從母 (主要照顧者原則)、子女意願 (家事細§65 III)、照顧繼續性 (=安定性原則)、善意父母條款 (§1055-1⑥)、手足不分離原則

(A) 家事§106、17、18 已有§1055-1 II 之規定 ⇒ 重複不必要

(B) 注意事項 ⇒ 審理時本於職權審酌一切情狀而定，酌酌事項不受§1055-1 拘束

(C) SC 105台簡抗6裁：子女意願非子女最佳利益之唯一依據，仍應審酌一切情狀定之

↳ note：J111.8

BIDC (Best Interest of Child)

3、监护人之选定（§1055-2）

(1) 林：应限父母均七或不能行使亲权为限，仅规定不适合时得改算入，恐造亲权与监护制度

(2) 林：父母均不适合行使权利 ⇒ 不确定法律把关意 ⇒ 流于主观

(3) 无监用即可依§1055-2排除§179 实有疑问

(4) 不适合行使权利之事由消灭后，亲权未经法院宣告停止，无须按民187请求撤销宣告 ⇒ 亲权是否当然回复实有疑问，若非则回复方式尚待明（李琼瑛、林）

二、财产上效力

1、损害（§1056）

(1) 离婚损害（§1056）：因判决离婚造成之损害，无关离婚原因

(2) 离因损害（§184）：造成离婚原因同时构成侵权行为

(3) 不同之请求权基础，可分别请求（SC 103台上225）

(4) §1052 I ②③⑤⑥ 採有责主义，本可能同时构成侵权

(5) TB不同：离婚损害无须符合侵权之TB，离因损害限故意，过失不构成离婚原因自无损害发生

(6) §1052 I ④、⑩ 对他方无侵权存在，无离因损害，但若有过失则仍有离婚损害（过失非财产法上过失，係指对原因之发生有责任）

(7) 时效
- 离因损害：婚姻关係存续中即可请求
- 离婚损害：离婚判决确定後始得请求（SC 39台上920例）

(8) 时效
- 离因损害：§197，自知悉有损害时起算
- 离婚损害：§125 15年，自离婚判决确定时起算

2、离婚损害－财产上损害（§1056 I）

(1) 他方面配偶有过失 ⇒ 请求人有无过失在所不问

(2) 因判决离婚：两愿离婚若未协议者不得请求（史、戴、模）

(3) 有损害：可请求之范围极狭（SC 45台上885例：窜客费 / SC 50台上331例：聘金係赠与，主要为附条件之赠与而为§179，非§1056之离婚损害）

A、受虐待受遗弃之损害係离因损害

B、家庭生活费负担义务随离婚消灭，并无损害可言

C、受扶养之一方有§1057赡养费，本无须以§1056救济

D、林：勉强言之，偏限请求离婚律师费而已

3、离婚损害－非财产上损害（§1056 II、III）

(1) 请求人无过失，一身专属性

(2) 林：两愿离本可能因有过失一方而造成精神上痛苦 ⇒ 不理解为何限裁判离婚 ⇒ 主张论应准§1056（Swiss§151 2012删）

4、赡养费（§1057）

(1) 因判决离婚陷於困难

A、排除两愿离婚（SC 28渝上487例、104台簡抗10裁）

B、陷於生活困难：因健康或年龄关离婚期待从事职业 ⇒ 赡养费係扶养义务之延长 ⇒ 依先於其他亲属 ⇒ 不问权利人之其他亲属有无扶养能力（通）

C、林：请求权人存在有扶养能力之直系血亲尊亲属，法院於酌定时应予以考量

(2) 請求權人無過失 (林：非賠償請求權，與過失相當理論上不妥)

(3) 被請求人有支付能力：扶養义務之延長，應以被請求人有能力為必要，不得陷於困難則無從給付之

A、SC 91台上1798：§1118 得照此有同解釋

B、數額按§1119定之 (SC 19上36例)

(4) SC 33上4912例：承认納妾契約合法，數人贍養費請求權係基於妻契約之當然解釋，須可歸責夫或終止後生活陷於困難，判決中隱含見損害賠償

↳史、戴：點燃縱無過失，亦應給付，惟若須無過失，惟祝融失僅得為甚斟酌权衡之因素

(5) 林：剩餘財產分配請求权之增仗便贍養費功能大幅萎縮，成為敗，應重新定位贍養費之意义 SC96台上269
§1030-1

↳社会國家制下，不應由前配偶負担扶養义務，應由社会、國家承担責任⇒新学说；衡諸性別分工生活型態不所造成一方就業場上所得下降

(7) 計算方式：权利人生活需要，义務人之經濟能及身分，參考§1119⇒ 每人每月消費支出(主計处)、低收入戶最低生活費
所得稅法扶養親屬免稅額、健保最低月額

(8) 給付方式与期間 (法无明文)

A、可定期亦可一次給付 (一次給付⇒部.吋司法四期研究会35期；定期⇒学说)

B、永久性：給付至权利人死亡為止 (高院96家上更(一)9)、第三再婚或子女成年為止

C、暫生性：X年為期安定其生活 (高院96家上易24)、酌定一定金額

5、財產之取回 (§1058)

(1) 分別財產制，採法定財產制於為自管理為自財產不適用本條，法定財產之剩餘按§1030-1⇒§1058前无從適用

(2) 共同財產制直接有§1040、1031⇒§1058後

(3) 林：立法倫上宜刪除

三、生效時点

1、兩願離婚：登记時

2、調解和解離婚 (具形成力，与判決有同一效力⇒報告登记；法院取权通知戶政登记)

3、裁判離婚：判決确定

壹、婚生子女

一、要件 (§1061、1063Ⅰ)

1. 生父、生母須有婚姻关係

2. 子女係妻分娩所生 (SC 28渝上1445例) ⇒ 若證明他人子女為自己子女且足分娩事实者非婚生子女

3. 於婚姻中受胎 (受胎期間：§1062) (35 院解3321、SC 19上 750例、21上3000例) (SC 91.06.21第七次民庭会议：受胎自子女出生日起算)

4. 通：婚生子女須為其母之夫之血統 (史、鄧、林宜珠、戴、模) ⇒ 須有生父血統

   ↳ 林：倘实中无法推得，故僅須具備前三要件 ⇒ 於否认之诉確定前仍推定為婚生子女

二、婚生推定 (§1063Ⅰ)

1. 未同JP§772Ⅰ明文生父推定，惟解釋上仍应认可推定為父之子女 ⇒ 有婚生及父性推定之双重功能 (林)

2. 妻所生子女无法受婚生推定 (SC 29 渝上2046例)

3. 同居事实

   (1) 必要说 (曾、胡)

   (2) 非必要说：保护子女 (林、戴、史、模、25院1426、33院2773)

4. 87册§§987、994再婚待婚限制 ⇒ 重複推定 (cx：¾ 甲2離，¾ 甲內結，¼出生 ⇒ 再婚181日後，離婚302日內)

   (1) Ger§1593：先推定後夫，於後夫否认之诉確定後推定与前夫親子关係

   (2) TW法无明文 ⇒ 家事§65 <（再)婚與前夫互為被告；子女、生母以现夫及前夫為共同被告，提起子女確定其父之诉

三、婚生否认 (§1063Ⅱ、Ⅲ)

1. 否认子女之诉 (家事§63Ⅰ)

   (1) 原告適格

      A. 夫

         (A) 未成年人因結婚具行為能力(舊法) ⇒ 有诉讼能力 (但诉§45)

         (B) 夫受監护宣告 ⇒ 監护人代理，但妻代诉讼行為難期待 ⇒ 依利害关係人声請或职权選任程序監理人 (家事§15)

      B. 妻

         (A) ~74：不得提起 / JP、Swiss 不承认妻之否认权 / FR 限準正為目的始肯定

         (B) 林：擴大婚生否认人範圍对子女不利 ⇒ 妻行使否认权以損害子女為主要目的 ⇒ 法院应以濫用否认权為由，駁回其诉

      C. 繼承权受侵害之人 (家事§64)：夫妻一方於法定期間前或內死亡者，繼承权受侵害之人得提起之 (SC 106 當上72)

   (2) 被告適格 (家事§63)

      A. 未提诉之夫、妻与子女為共同被告 (家事§63Ⅰ)

      B. 应為被告之人均死亡 ⇒ 檢察官為被告 (家事§63Ⅲ後)

2. 否认推定生父之诉

(1) 原告適格

A、子女 (SC 23上1073例、75上2771例 反对/JS87→96司法、SC96台上2278)

(A) 7岁以上按家事§14II 即有程序能力

(B) 依民訴§96II準用§85I or 家事§15II 法院得取权選任程序監理人

B、繼承权受侵害之人 (家事§64)

(2) 被告適格

A、家事§63II：以推定之生父為被告

B、家事§63III：推定之生父死亡者以檢察官為被告

3、诉之性質：形成之訴 (家事§48I)

4、不確认親子关係之訴 (家事§67) vs 婚生否认之訴

(1) 否定说：前者具補充性質，須与既有之訴以類型无特殊缺陷得提起 (林、魏大曉)

(2) 肯定说：使身分明確 → 有确认利益，应做实体上审查 (沈冠伶、SC105台上700)

(3) 准受家事64之除斥期間限制 (學說、SC105台上700)

四、否认原因：能证明子女非婚生子女 (§1063II)｜子女各情況，妻與夫非於婚姻中受胎、无能為性行為、人种(性狀)、公佈的懷、DNA

五、時效性質：形成权 → 除斥期間 (JS87通)

六、起訴期間

1、~96：1年 /96~§1063III本文：2年

2、成年後子女2年內 (§1063III但)

3、繼承权受侵害之人：死者死亡後1年 (家事§64II)

貳、任意认領

一、§1065II：視為婚生，无須认領

二、§1065I：經生父认領，視為婚生。經生父撤销者，視為认領

三、性質

1、观念通知说 (事实上通知)：向对方通知自己业已认识其与非婚生子女有血緣关係而已，通知後所發生之各种法律效果，乃為民法概括所規定(楊)

2、特別意思表示说：身分行為之意思表示 (戴)

3、单独行為说 (通)：屬意思表示，但无須被认領人同意 → 生父对非婚生子女承认其為父子

4、无区分实益说 (林)：依和加用語观之，似认係意思表示 → 均以事实上父子女关係存在為前提 → 区別实益不大

四、形成权，但行使无須以訴為之 (SC 63台上1796例)

五、通：不要式行為，戶籍法雖有登記 → 僅為证明方式，非认領形式要件

六、属身分行为 ⇒基於身分关係安定性，不得附條件或期限 (通)

七、史、林、戴、振、琛：舊戶籍法有遺囑认领⇒允许遺囑认领 / 林：§1199 遺囑係人死亡生效⇒違反不得附款原則，且戶籍法因民法无規定已刪除此條⇒应认此种认领已不要式，就於遺囑書上亦可生效而已

八、抚育：不限於教养，亦不問生母是否曾与生父同居 (23院1125)

1. 史、戴、楊、輝：主观主义⇒生父须有以後子女為自己子女之意思為抚育，始得視為认领

2. 林：客观主义⇒有抚育事实即应推定為业已通知对於有親子关係，可认作流默之不作认或宣言，不問內心意思 (林)

九、抚育費得預付⇒若預付則可认有认领 (SC 89台上1167例)

十、曾作為家屬受家長即胎兒之生父扶养時，表面上系受扶养，实質上胎兒亦受扶养⇒可认同生父抚育者 (21院735)

十一、要件 (§1065I)

1. 被认领人須為非婚生子女 (SC 96台上2811)

(1) 胎兒可认领 (§7) (实、通)

(2) 已死亡之非婚生子女

A. 否定说：民法未明文，死者无人格，流弊甚大 (胡、最、戴、高鳳仙、許3對林)

B. 肯定说：法无禁止、单独行為且保障血親之利益，礙响总遺承⇒若濫用可认无效 (史、趙、楼、林)

(3) 乱倫子：不能準正，得认领 (36院解3329)

(4) 推看羽推定可由生父认领 (37院解4082、SC 98台上704，反对：SC 29上1832例一廂)

2. 认领人為生父：有血系，认领係身分行為，不得由他人代理，只須有意思能力為已足，不以行為能力為必要

十二、无效 (舊民係§58I / 家事§67)

1. 无意思能力之认领

2. 认领人非被认领人之生父 (SC 86台上1908例)

3. 他人代理之认领

4. 被认领人係婚生子女 (33院解2773)⇒生父、生母结婚視為婚生後无須认领 (§1064)

5. 違背遺囑方式 (楼、史) / 林：认领应不要式⇒虽无效仍对已生效之认领无影响

十三、撤销 (§110不得撤销)

1. 不得任意撤销说 (最、明、李宜琛、趙)：受作欺、脅迫仍可行使撤销权

2. 若有血統，絕对不得撤销说：如有血系作欺，不妨提起认领无效主張认领无效 (戴、史、楼)

3. 林：§110排除总則，若无血緣自屬无效，无須撤销⇒96~§110但得增適用上困擾 (通)

4. 戴、少数说：肯定§110但

十四、否认 (§1066)

1. 举证肯定说：須证明有反对事实 (戴)，第三人則不得否定 (批評：无否认认领之訴，且課予母及子舉证責任)

2. 无須举证说 (楼、史)：否认屬形成权，无須举证 (林)⇒否认後应由父提起确认親子或扶养关係存在之訴，並負举证責任 (家事§67I)

肆、強制认領 (§1067I)

一、认領之訴 (家事§66) 之性質

1. 給付訴訟說：认領屬意思表示引以為意思表示請求給付 (姚瑞光、楊建華)

2. 確认訴訟說：认領屬事实通知或观念通知，僅重血統事实，不在乎有无认領，对应认領而不认領之生父得以判決代替认領 (林、戴)

3. 形成訴訟說：創设父子女关係，有对世效 (史、陳付男、林、振)

4. 林：96修正前宜採給付訴訟說，96後因得向繼承人或扶養主張 (§1067II)，应為給付之訴 (SC 98台上94)

二、原告

1. 非婚生子女：7岁以上有程序能力，得独立起訴 (家事§14II)

2. 生母与其他法代

(1) 法定代理說：身分行為不許意定代理但許法定代理引代非婚生子女提出 (戴炎輝、戴東雄)

(2) 固有权利說 (林、戴)：舊民訴§76I但解釋，生母或法代有扶養义務引认領可減輕引有訴之利益，本於固有权利為之

(3) 折衷說 (史、胡)：生母請求保固有权利之行使，法代代表生母為之 (胡)；法代代表子女 (史)

三、被告：生父

1. 舊法：限生存之生父 (23院1125)

2. 96~：家事§66

四、不負抗辯 (~96§1068)

五、請求权 消滅

1. ~96§1067II：子女成年後2年、生母及其他法代子女出生後7年，現已刪除，无日落效

2. 拋棄

(1) 肯定說：子女、生母得足夠利益則不妨认為无效 (林)

(2) 否定說 (林、李宜琛)：无判決、主法条解釋，且有关§1115I 扶養义務順序

六、原因

1. 大清民律草案親屬§72、北民律草案親屬§1161、17親屬法草案§42I 不列举原因採概括主义

2. 19~96§1067I：列举事由 $\xrightarrow[\text{法}]{\text{修}}$ 96~§1067I：客观主义 (概括主义)

肆、效力

一、發生時点

1. 溯及出生時 (§1069本文)

2. 繼承权

(1) 不取得說 (史、戴炎輝、林、台北地院98重家訴21、100重訴312、高院99重家上7、SC103台上2519)

(2) 折衷說：目的性限縮§1069但
- 嗣後發現說 (SC 100台上452)
- 对外債权說 (高院100重家上更(一)3)

(3) 林：取得，否則架空死後认領
- 遺產分割說 (高院101重家上50)
- 遺產分割說+嗣後發現說 (SC 103台上618、台中地院104家訴136、桃園地院106重家訴16)

3、胎儿

(1) 溯及出生时，但以非死产者为限 (史、模、胡)

(2) 林：遗腹子女与对生父若採前说则无从发生血亲关係与应採认领时生效说

二、第三人既得权之保护：不得作请撤销婚姻 (胡、林)

三、亲子关係之发生

1、双方均获得继承权 (§1138)，互负扶养义务 (§1114①)

2、生母、後顺位扶养之人因溯及效可对生父依§1乙请求已支付之扶养费 (史、戴、模)

3、行使权利义务準用雛婚 (§1069-1 →準用 §1055～1055-2)

伍、準正 (§1064)

一、要件

1、受準正者係非婚生子女

(1) 广义说 (不限子女出生前結婚) (曾、史、林)：不因认领、準正修文而有不同与婚姻不及181日雖不受婚生推定，但仍受準正

(2) 狭义说 (限子女出生前結婚) (胡、戴、模)

2、生父与生母結婚

(1) 非生父应为繼父，无法準正

(2) 无效则无準正可能与禁婚親 (5C和瑜上457判例)

(3) 撤销因无溯及效 (§998)与準正效力不受影响

二、生效时点

1、父母結婚时说

2、溯及子女出生时说 (通)；準正应同认领→类推§1069

壹、定义 (§1072) ⇒ 父母本位(旧法)⟶养子女本位

└收养为孙子女 ─┬肯定说(史、戴煇、邱)
　　　　　　└否定说(胡、曹、模、戴、林)

贰、实质要件

一、收养合意 (认定时点:契约订立时)(SC 104简抗1裁)

1. 仅有养育事实无成立亲子关系之意时非收养 (SC 23上特23例),通谋虚伪本无效 (J91:收养子女係为与婚生子女结婚者,仍可结婚,非收养)

2. 收养契约属身分契约

(1) 不得代为收养 (SC 26上4811例、33上6441例、33上5102例)

(2) 不得遗嘱委托他人死後代为收养 (SC 32永上2814例)

(3) 配偶仍得自行收养 (22院例)

3. 法代同意 (身分行为不得代理之例外规定)

(1) §1076-2正:7岁以上应得法代同意

(2) §1076-2正:<7岁法代代受並代为意思表示

(3) 无法代则应先订监护人

4. 受监护之人於正常状态中收养或被收养

(1) 肯定说-须法代同意说 (戴)

(2) 肯定说-无须法代同意说 (模)

(3) 肯定说-未满18岁须法代同意说 (史、振)

(4) 否定说:违背养子女利益,法院应不予认可 (戴東雄)

(5) 实体审酌说:无否认收养能力之必要,为保护子女利益,法院应具体审酌 (林) { 收养成年人 ✓ / 受监护宣告之人有配偶得共同收养 ✓ / 无配偶:有违 BIOC X

二、一定年龄之差距 (JP:长1天以上即可)

1. ~96§1073:相差20岁 ⇒ 夫妻共同收养或收养他方子女所受限制 ⇒ 对子女不利

2. J502:§1073 符合伦常,合宪,但於前情形应设有弹性规定

3. 96~§1073正:20岁个/正但:共同收养一方20岁,他方16岁个/正:收养他方子女,16岁个

三、非近亲 (§1073-1)

⓪ 旧法无明文 ⇒ SC特上1927例 类推§983近亲结婚 ⇒ 74~明文

① 直系血亲

1. 生母收养自己之非婚生子女

(1) 肯定说(史、模):保护非婚生污名,保全名誉,收养通为有利

(2) 否定说(胡、林):举正条件已足,§1072明文应收养他人子女,且有§1065五,不得认领即生直系血亲关係

2. 经准正或经生父认领 ⇒ 不得收养

3、未受认领或追正之非婚生子女生父收养

(1)肯定说(史、模、林):以收养解决社会事目为不妨作其收养→纵认无效,亦有§112转换为有效之认领→实质上两说特致相似结果(司法院81.2.27(八-1)厅民一02696号函不予表意见)

(2)否定说(胡、戴):与法条文义违背(§972)(通)

② 直系姻亲,但夫妻收养他方子女不在此限

↳不收养他方子女而欲收养他方子女之配偶:文义解释×→目的性扩张但使合立法意旨

↳不得再收养他方子女→使夫妻成为手足不合立法意旨

③ 旁系血6亲等内、旁系姻5亲等内,辈分不相当→指差一辈→兄姊不得收养弟媳、叔公不得收养侄孙

四、夫妻共同收养(§1074本文)

① 夫妻一方收养他方子女→有§1073-1①故僅一方即可

② 一方不能为意思表示或生死不明逾3年

③ 性质

1、個別收养说(通、模、宋林):不因夫妻离婚受影响,各别成立收养契约

2、一体收养说(少、史):僅成立1契约→任何一方有无效或得撤销原因时亦得对他方主张

④ 事实上夫妻不得类推§1074(SC105台簡抗11裁)

⑤ 同性伴侶不得类推§1074(SC106台簡抗129裁、107台簡抗97裁)

⑥ 一方终止不及方与他方之收养(SC 85台上298)

五、一人不得同时为2人之养子女(§1075)→僅许为一对夫妻或一人收养(35院解3120)

↳离婚不影响收养,养父母与他人再婚後其後夫/妻依本條不得再收养(§1076本文)

六、夫妻一方受收养应得他方同意(§1076本文)

1、夫妻一方受收养而有共同生活事实按§1041②他方配偶对收养人有扶养义務

2、但:他方不能为意思表示或生死不明逾3年不在此限

3、一方被收养→配偶、收养人成立直系姻亲,不得收养(§1073-1③)

4、夫妻共同被收养

(1)否定说:夫妻为手足→禁婚親(鲁、胡、戴、林)

(2)肯定说:可保和平仍承香火→婚养子合法(鼎、趙、模)

七、子女受收养应得父母同意(§1076-1本文)

1、与法代同意出养权不同,应指本生父母之固有同意权(非親权)

2、子女不限未成年,且但②之事实上不能为意思表示应指父母不保、死亡、失踪、无同意能力,非停止親权等法律上不能之情形

3、Ⅱ:同意应作成書面並公证,得以訴向法院表示並记明筆錄代之;Ⅲ:同意权之行使不得附條件或期限→身分行为之安定性

4、若父母=法代→§1076-2Ⅲ不必再行使§1076-1同意权

參、形式要件

一、作成書面 (§1079Ⅰ)

二、向法院聲請認可 (§1079Ⅰ) (性質：非訟事件之裁定)

1. 審酌標準 (§1079-1)：BIOC (似与§1083-1 準用→§1055-1 重疊) ⇒ 應依指導條款

(1) 近親(骨血6、姻5、輩份相当)、繼親 (夫妻一方收養他方子女) 收養外，應委託收出養媒合服務者代覓收養人 (兒少§16Ⅰ)

(2) 訪視調查，完成評估報告 (兒少§16Ⅱ)

(3) 評估報告係審酌之必要文件 (兒少§17Ⅰ、家事§115Ⅲ⑤)

(4) 得為試行收養 (兒少§17Ⅱ②、家事§116)，嗣後法院認可溯及開始共同生活時發生效力 (兒少§19Ⅰ後)

2. 不予認可之情形 (§1079-2、1079Ⅱ)

(1) 收養有無效、得撤銷原因或違反其他法律 (§1079Ⅱ)

(2) J712：舊兩岸人民§65① 違反憲§22 收養自由、§23比例原則 無其效力

(3) 成年收養有脫法行為 (§1079-2)

① 意圖以收養剝除法定義務：免除對本生父母之扶養義務致其生活困難

② 足認收養對本生父母不利：雖本生父母足夠財產維持生活，但有孤苦無依、殘廢、長期臥病等情事

③ 其他重大事由足認違反 收養目的 〈ex：逃漏國家稅負武(戴)
林：上例為無收養合意，自屬無效，本款所謂之收養目的為何不得而知

三、舊法：~74 ⇒ 應以書面為之，但自幼扶養子女者，不在此限 (SC108台上大門判裁)

1. 但僅為方式之例外，仍須本生父母同意

2. 未成年若有法代且後法代事實上得為意思表示者，應有§1076-2 之方式 始成立收養關係

肆、無效 (§1079-4 準用)

一、§1073 未達法定年齡之間隔：74 修正前 非當然無效，僅得撤銷 (SC 32上886例、J87、35院解3120)

二、§1073-1 近親及輩分不相当：74修正前 認違反公序良俗無效 (通、SC49台上1927例)

三、§1075 一人同時為二人之養子女

1. 74修正前 認無效 (通)

2. 同時受非夫妻兩人收養 (ex：法院誤為夫妻而認可) ⇒ 兩關係均為無效

3. 先後被收養 ⇒ 後收養無效，前收養有效

四、§1076-1 缺生父母同意、同意未作成書面、未公証 或 同意附條件或期限

五、§1076-2Ⅰ 未滿7歲未由法代代為及代受意思表示

六、§1079Ⅰ 缺書面或法院認可：74修正前 SC29上817例 認得無效

七、不限此條：欠缺收養意思、附條件或期限之收養、代理他

八、收養認可非 效力規定 ⇒ 不應予以認可而認可效力仍依民法判斷 (ex：§1079Ⅱ若得撤銷但認可⇒仍為得撤銷，否則§79-5 淪為贅文)

九、无效之主张

1、不得判决当然自始无效，若有争执自得提起收养关係不存在之诉(家事§31甲類事件)

2、收养关係不存在之诉属确认之诉→无形成效力，有利害关係之人均得提起

3、有无效原因而法院未经查明予以认可

(1)无效说：纵经认可，仍违强制规定无效，裁定可抗告(家事§92I)，无收养无效之诉，既称确认自无法解释成有形成力(杨与鲁仝、林)

(2)有效说：於确认无效之诉或取权撤销前，因法院认可有公信力，应认裁判[F 撤此无效→同§1080普通利害关係人、新诉仅撤销] →经法院裁定无效後始溯及收养行為时无效(戴)

4、被告适格(家事§39I,II)：当事人一方起诉→他方被告 / 第三人起诉者→双方当事人被告

5、SC 96第1次民庭决议 (SC 104第4次民庭决议廢止)：养父母已死亡不得再收养子女為被告起诉 ↔ 通：得僅以未死亡一方為被告

伍、撤销(§1079-5)

一、~74：适反§1074、1076 (30院2771、SC31上2973例)

二、§1074 夫妻一方单独收养(§1079-5I前)

1、限一方单独声请法院认可而被认可→一方冒用他方名义声请法院认可而被认可？

(1)嚴格解释说(否定)

(2)寬鬆解释说(肯定)

A、模：撤销权人不行使时可认默示认共同收养，撤销时双方之收养均被撤销

B、林：身分行為本即无法代他人為之，故被冒用方自无收養，並得以§1079-5I行使撤销权

2、时效：6月/1年(§1079-5I但)→除斥期間→经过後即可单独收养

三、§1076 夫妻一方被收养时未得他方同意(§1079-5II本文)：被诈欺者，应先§92.93撤销同意再§1079-5II撤销收养

四、§1076-2 七岁个被收养时未得其法代同意

五、方式

1、撤销收养之诉(家事§69)→以诉為之

2、被告适格同无效(家事§39)

六、效力：不溯及既往、一方陷於生活困難得请求相当金額、回復本姓及与原親屬間权利义務，第三人已取得之权利不受影响(§1079-5III 準用→§1082,1083 立委版)
(ex：繼承权)

陆、效力

一、发生时点

1、舊法：~96未明文；現法：96~§1079-3溯及收养契約成立时

2、兒少§79I前、中後：成立書面契約；无契約以向法院声请时；试行收养以开始共同生活时
兒少§II

3、兒少§79II：收养人於声请认可後、裁定前死亡→若对养子女有利，仍可為认可裁定→仍有§1079-3但適用

4、林：有可能使子女皆无法取得双方财產，且§187之责任有爭议

二、親屬关係发生(§1077)

1、养父母及子女皆同时皆生子女 (§1077 I)

2、与本生父母之天然血亲关係仍存在 (J28)

3、法律另有规定⇒§1078 维持原姓氏 (§1078 III $\xrightarrow{\text{準用}}$ §1059 II~V)

4、收养成立⇒发生直系血亲关係⇒互负扶养义务 (§1114①)、互有继承权存在 (§1138①、②)，子女未成年由养父母行使亲权 (比20上2305例)

5、养祖孙关係

(1) 养子女於收养认可时已有直系卑亲，收养效力仅及於未成年之直系卑 (§1077 II 本文)

(2) 已成年之直系卑亲发生祖孙关係应表示同意 (§1077 II 但)⇒同意应书面同意经公证並不得附条件或期限 (§1077 V $\xrightarrow{\text{準用}}$ §1076-1、1076-2)

三、与本生父母及其亲属间权利关係

1、於收养关係中停止之 (§1077 II 本文)；继亲收养不受影响 (§1077 II 但)

2、收养後，收养者与养子女之本生父母结婚时，回复与本生父或母及其亲属间之权利义务，但第三人已取得权利不受影响 (§1077 III)

3、回复无溯及效力，§1077 III 但仅止於注意规定

柒、终止

一、合意终止 (§1080)

1、实质要件

(1) 双方终止收养合意

A、身分契约⇒须以当事人有终止收养之合致⇒通谋虚伪之终止无效

B、~96：同意 → 96~：合意

(2) §1080 V、VI：养父母双方代理 (§106)⇒例外规定应得终止後为其法代之人同意 (V：7岁) 或由其代为之 (V：7岁)

A、本生父母仍生存：本生父母 / 一方死亡：生存之他人 / 均死亡：终止後监护人

B、养父母已离婚或婚：与非行使权利一方⇒他方为法代可同意 / 与行使权利义务一方解除⇒他方代为同意

C、养父母於收养後之一方死亡⇒终止後仍与死亡方有收养关係⇒开始监护⇒终止後监护人

(3) §1080 VI⇒事实收养契约於法不合 (自己代理)

(4) 夫妻原则共同终止 (§1080 VII) (通)；单独终止时效力不及他方 (§1080 VIII)

A、未终止之一方不能为意思表示或生死不明逾三年⇒开始监护 (§1091)

B、§1081 I ④：与不能为意思表示或生死不明逾三年之养父母终止 (其他重大事由)

C、§1080-1 I：与死亡之一方终止

D、限共同收养时有其适用 (单独收养无须他方配偶同意)

↳ ex：收养时无配偶而後结婚、违反 §1074 未撤销、未得他方配偶同意而未经撤销

2、形式要件 (§1080 II)

(1) 书面为之 (§1080 II 前)⇒户籍§8 II 虽规定须登记，惟此属报告之登记，非要件

(2) 养子女未成年应向法院声请认可 (96~§1080 II 後)

二、宣告終止（裁判終止）

1. 声請人：〈養子女＋兒少福利主管機關／未生父母
養父母＋老人福利機關
（96~§1081（參考兒少§70））

2. 訴种：非訟事件（SC 110台簡抗32裁）

(1) 未成年：非訟（无爭议）（§1081Ⅱ＋家事§3Ⅴ⑬、74）

(2) 成年

A. 非訟說（家事§3⑬、家事審細§108④）（实通：SC 101台抗962、102台簡抗45.577、103台簡抗185.104台簡抗132.210
105台簡抗70.204、106台簡抗136.157、107台簡抗11.66.115、108台簡抗208裁）

B. 訴訟說（家事§3Ⅲ④、45.46.47、69Ⅲ、舊民訴§583）（SC 101台簡抗263裁）

3. 原因（§1081Ⅰ）

① 对他虐待或重大侮辱：虐待：身体上、精神上受不堪痛苦之積極或消極行為；侮辱：毀損名譽之行為但限情節重大（林、鼎）

↳ ex：无故將養母鎖在門內1日（SC 29滿上207例）、肆意辱罵（SC 30台上88例）、逼養女為娼（SC 20上2020例、通）

② 遺棄他方：溥指扶養义務不履行（与§1052Ⅰ⑤不同）（SC 33上5296例）

↳ SC 41台上744例：離婚約定一方行使負担权利义務時，不得以棄置為由請求另一方終止

③ 故意2年个緩緩刑宣告：舊法~96 可限养父母提起

④ 其他重大事由：重大須以社会通念及当事人個别具体判斷之

(1) 侵吞他方（SC 28滿上843例、33上3977例）、吸食毒品（SC 31上1369例）、誘使養子女賠操淫业（SC 48台上1669例）

(2) SC 57台上359例：行使親权並經证明无效果前，難认不服監护已成重大事由

(3) 浪費財產、生死不明逾3年（~96 ④⑤/96~④）

(4) 審酌原則：未成年人应以 BIOC（§1081Ⅱ、1083-1）

三、死後終止（§1080-1）

1. 沿革：J58：類推§1081⑥重大事由/74~96§1080Ⅴ：養子女无繼生能力/96~§1080-1Ⅰ法院许可

2. 要件

(1) 养父母死亡

A. 父母俱亡亡父（棋）

B. 勒死亡说（林、SC75台抗決议、JP通）：§1080-1Ⅱ參考JP§811Ⅱ，一方死亡应由他方以法代身分代為声請或養子女自行声請

(2) 声請法院许可：§1080-1Ⅱ：7歲以終止後之法代向法院声請
§1080-1Ⅲ：未成年 应得終止後之法代同意

(3) §1080-1Ⅲ：未經实公平（ex：禁民收養成年子女案）

(4) 非訟事件（家事§3Ⅲ⑦ J類非訟）

四、終止收養之无效（§1080-2）：違反§1080Ⅱ以書面為之、Ⅴ<7歲未由終止後法代声請、§1080-1Ⅱ養子女未成年未经法院认可終止

五、終止之撤銷（§1080-3）：違反§1080Ⅱ、1080-1Ⅲ7歲未得終止後法代同意、Ⅲ未與同終止（除斥期間：6月/1年）

六、終止生效時点：〈合意：裁定確定（未成年）/合意作成書面時（成年）
死後宣告：裁判確定

七、效力

1、对养方效力

(1) 身分上效力(§1083)

A、权利义务均消减

B、养子女於收养期间所生之子女，与养方之关係随终止而消减(戴、林、最、SC33上5318例)

↳ 史棋、3年院解3010 沈栎部门法律1030150850 认若养子女之子女有意思能力，经同意原留养家例外不消减 ⇒ 9/6修正§1083应无法再相同解释 院解3010应停止适用(林)

(2) 财产上效力(§1082)

A、旧法：经判决十天过失

B、因终止生活困难得请求相当金额，请求逾失公平得减免之(ex：有虐待情事可认对养父母而谓逾失公平)

C、SC33上6077例：养子女终止未成年时由本生父母负扶养义务 ⇒ 非因终止困难之情形

2、对本生方效力(§1083)

(1) 养子女及收养效力所及之直血卑与本生父母及其亲属间权利义务应予回复，若收养时仍维持本姓，无回复必要

(2) J28：收养不影响子女与其本生父母及亲属关係 ⇒ 回复係权利义务

(3) §1083但 第三人权利不受影响

A、养父母已对养子女终结婚已为同意，本生父母不得再主张未经同意而撤销(史棋)

B、已经继承遗产，不因终止受影响(史棋)

C、戴：民法僅欲解决而置规定 ⇒ 係注意规定，因本生不溯及既往即无影响第三人权利可能

捌、死亡消滅

一、黄诗淳：亲子关係不消滅

二、林、戴：身分关係消滅(§6：人之权力始於出生终於死亡)，但收养契约仍存在

三、胡：死亡不因死亡消滅且因死亡发生特殊作用(祭祀、有限、血统连续之拟制)

四、史：养子女死亡解消，但养父母死亡不完全解消(养父母死亡仍称养父母之姓，亦不得再被他人收养)

壹、稱姓

一、婚生子女稱姓(限父或母姓) §1059 I ⇒變更

1.取得:19~§1059 I:子女從父姓,招贅婚從母姓,約定從其約定/74~增訂但:因現況/96~書面約定/戶籍§49 I前 99~§1059 I:約定不成抽籤
↳男女比(1:3~1:4)

2、變更

(1) 未成年前父母書面約定變更(§1059 II):非親權內容,約從被停止有約定變更之權利

(2) 子女已成年得變更(§1059 III) ⇒ 96~99 §1059 III 經父母書面同意

(3) §1059 III:§1059 II、III 以1次為限

(4) 法院裁判(§1059 V) ⇒修法理由:§1059 V④含修法前之曾有或現有未盡扶養義務

二、非婚生子女之稱姓

1.取得:從母姓(§1059-1 I前),出生登記前已經認領則§1059 I 書面約定之
↳~96舊法無明文⇒33判2773:認領前從母姓,認領後依~96§1059 I 從父之姓

2、變更

(1) 經生父認領(§1059-1 I後 適用→ §1059 II~III) (林:未登記生父即書面約定或自行更改從父姓之效力有疑問)

(2) 法院裁判(§1059-1 II) (note:準正後應適用§1059)

三、養子女之稱姓

1.舊法:19~96 §1078 從收養者之姓,夫妻收養適用§1059

2、取得:§1078 II 收養登記前,書面約定從父、母或原姓,單獨收養由收養者決定
↳無法決定時無§1059 I 之準用⇒無法抽籤⇒別無他法

3.變更(§1078 III 準用→ §1059 II~V)

(1) 單獨收養者無準用可能,亦不得變更為原姓氏

(2) 25判1602:不得兼用本姓,本姓主加入只能認係名之一部,非複姓

四、裁判變更之注意事項(§1083-1):依§1059 V、1059-1 I、II、1078 III 裁判時準用§1055-1⇒BIOC及§1055-1 7款事由

貳、親權

一、親子法沿革:家本位→母本位→子女本位

1.性質:親權有權利常為義務⇒不可拋棄(SC 28滿上1749例、38台上1111例)

2、保護、教養之權利:對外關係,有權要求第三人不妨害(ex:子女返還請求權)

3.保護、教養之義務:對內關係 ⇒具體如同意權、懲戒權、法代權⇒親權之濫用實質上為教養及保護義務之違反(黃宗樂、林)

4.§1084 I:子女應孝敬父母

(1) 此條應為道德上訓示規定,子女不問成年與否⇒僅具教育性作用,意義不大

(2) SC 74台上1870例將§1084 I與§1145 I ⑤失教規定巧妙結合,具減子§1084 I法律上意義(林)

二、行親權之人

1、父母：原則本生父母，出養後轉由養父母親權人 (SC 70上2305例)

2、父母一方死亡、被停止親權時，由他方行之，即使再婚，仍為親權人 (SC 22上1123例、23抗711例)

↳再婚之母未與其未成年子女同居，具怀得行使親權 (SC 32永上3044例)

3、非婚生子女：經認領 (§1069-1 準用→ §1055~1055-2)

4、舊法：未婚之未成年，無完全行為能力，為法律行為需須法代同意，無法對子女行使親權，依§1091應置監护人

三、服親權之人

1、限未成年子女

2、舊法：未成年已結婚取得財產上能力，財產行為上不妙服親權，但身分行為上仍須服親權 (舊§981.1089但、1076-2Ⅱ、1080Ⅲ)

四、內容

1、居住所指定權 (§1060)

(1) 通：§1060与§21所謂之住所涵义有所不同，应指居住所指定权 (立法倫：应置於§1089後)

(2) 父母不得提起请求子女同居之诉 (SC 52台上3346例) ⇒通：行使懲戒权，本不妨停止支付教养费用，使子女遵從 ⇒指定权薄弱，稍强制性

2、子女交还请求权 (通)：父母得本於親权人身分向扣留子女之人请求交还子女

(1) 无明文，但通说皆肯认之，SC 50台上103例 肯认

(2) 家事§104Ⅰ⑤、107Ⅰ、194：交付子女事件為親屬非訟事件

3、懲戒权 (§1085)

(1) 应為实施保护教养所必要，程度应按智識、性别、年齡、过失輕重、健康 (通)

(2) 成年之懲戒

A、否定说 (史、鼎、曹、李祖琛、楼、通)：保护教养权限未成年 ⇒懲戒权限未成年

B、肯定说 (胡)：文义解釋，惟无保护教养权，无实益

C、折衷说 (戴炎輝、戴修瓚)：应与§1085子女应為相同解釋 ⇒实質倫上，仍同以滿20岁之子女，对父母之懲戒得行使正当防衛，有适当道之立法意旨

↳民法特旧愛昧其词 即立法者有意使裁判者有弹性空間

4、法定代理权 (§1086Ⅰ) (ex：§974、981、1089但、1076-2Ⅱ、77、79、85、76、1671、1063Ⅱ、民訴§47、家事§65)

(1) 舊法：利益衝突未明文 (SC 70上954例-肯：可定监护人)

(2) 立法理由：廣义解釋 ⇒含§106自己、双方代理

(3) 立法理由：民訴§51依声请特别代理人之程序规定，与§1086Ⅱ实体规定不同

↳ex：法院已依§1086Ⅱ ⇒该特别代理人即就该事件為法代 ⇒无民訴§51，须无先§1086Ⅱ才有民訴§51

(4) §1086Ⅱ不受声请人声请限制，得依职权為之 (ex：遺產分割事件) (高院得应该会民事1)

5、子女特有財產之管理 (§1088)

(1) 特有財產 (§1087)：未成年子女因繼承、贈與或其他無償取得之財產

(2) 有償取得之歸屬 (法有明文，因立法時工商世不普遍，取得之財產除法定方式外不多)

A、父母說 (舊學說：黃、胡、黃右昌、李宜琛)

B、子女說 (新學說：林、戴、楊、振、鍾、史)：子女勞力所得須保障以貫徹人格獨立原則

(3) §1088Ⅰ：父母共同管理 ⇒ 含 權利及義務

A、對內為義務 ⇒ 保存、利用、改良子女財產 (對父母無益)

B、對外為 權利：父母得以自有人身分向侵奪子女財產之第三人請求交還 (SC 37上8467例) (林：對外主張權利即對內履行管理義務)

6、對子女特有財產收益權 (§1088Ⅱ本文)

(1) 此條文務成分 ⇒ 違反 BIOC (林：應依外國立法例，否定父母收益權，否則保子女利益)

(2) 司親屬法草案§53Ⅱ但：父母得為子女利益使用、收益或處分之 ⇒ 反面解釋：非為子女利益父母無收益權

7、對子女特有財產處分權 (§1088Ⅱ但)：應符比例原則

(1) 胡、林：廣義解釋 ⇒ 法律上處分、事實上處分 (法律上行為含物權、債權行為)
↳ ex：吃子女之屋漏，對外生問題，僅對內有§176 or §184 (SC 110台上1902：含買賣、保証、簽發票據、贈與 即負擔行為)

(2) 代理 (SC 53台上1456例、53第1次民刑庭決議(二)、32上1876例)：應以子女名義為之 (顯名代理主義)

A、SC 53台上3747、58台上230例、59台上1898：法有明文，代理權不限制

B、SC 8台上1224：未成年子女自為處分，同意應以3+，代理則受§1088Ⅱ但限制

C、SC 86台上744、戴瑞如、黃清溪、SC 93台上2282、98台上1236：同意及代理均須考量 BIOC

D、林：僅處分有§1088Ⅱ但 適用

(3) SC 51台上240號例：子女利益應斟酌當時一切情事，ex：清償子女債務處分子女繼承遺產
↳ SC 42台上126例：非為子女利益以特有財產擔保，應不許之

(4) 保証非處分 ⇒ 代子女為保証主效力

A、有效說 (SC 53台上2611例-磨)：財產上行為法代均得代理之；保护交易安全 (戴、楊)

B、無效說 (SC 110台上1902、113台上417、103台上2650)：係處分，按§1088Ⅱ但無效
(林、李珍玫)：非處分，但保証僅對保証人有害無利 ⇒ 法代權以損害子女為主要目的 ⇒ §148Ⅰ ⇒ 違反行為於子女成年承认前不生效力

(5) 違反之效力

A、無效說 (戴東雄、戴、SC 113台上417、110台上1902、69台上1309、57台上1898、58台上230、57台上3314、1237、58台上2929、994、53台上3747、48台上1407、44台上826)：§1088Ⅱ但係禁止規定

B、有效說 (戴瑞輝、振、楊、許澍林)：父母依委任規定向子女負損賠責任

C、無權代理說 (史、高鳳仙)

D、無權處分說 (陳計男)

E、無償行為無效，有償行為有效說 (鍾)

F、債權行為有效，物權行為無權處分並有善意取得適用說 (李珍玫、林)：對外應回歸財產法，惡意第三人須待其成年後追认才確定

(6) 林：立法論上應刪除，因有違 BIOC

五、行使 (§1089)

1、舊法 (~85)：J365 从意思不一致由父行使通案

2、§1089I前：以父母共同行使為原則

(1) SC 75台上1244、史、模、林：須生父与生母有婚姻或尚在同居才有適用

(2) 離婚後除有約定否則僅得由一方行使 (林)

3、§1089I中：父母一方不能行使权利，由他方行使之；§1089I後：不能共同負担時，由有能力者負担之

↳ 不能：兼指事实与法律上不能，行使困難不屬之 (SC 62台上415例)
(生病、重病、失踪) (路途遠、上班忙)

4、§1089II：对重大事項意思不一致，法院依BIOC酌定之

(1) 重大事項 (須為特定事件)：就业、就学、留学、服役、婚姻、營业許可

(2) 酌定：法院參考父母之意見，何者有利則採何者，非逕為決定取代父母之意思⇒法院不代行親权 (模、林)

(3) §1089II：裁判前应听取未成年子女、主管机关或社福机构等之意見

5、96~增§1089-1本文：父母分居達6月个 —準用→ §1055~1055-2離婚

(1) 即事实上別居

(2) 但：法律另有規定 指§1055§1313II③.⑥、§1090 →2次暫时親权行使及負担之人
↳停止親权6法律上不能

林：但書之有正当理由排除原因不明，分居6月仍有定親权人必要⇒但書立法论上应予刪除

6、成年人共同監护人規定无漏洞，无須準用§1089 (SC 103台上2073、103台抗622裁)

六、停止 (§1090)

1、舊法 ~96：濫用親权由最近尊親屬或親屬会议糾正之。糾正无效时得請求法院停止其权利之全部或一部

2、声請人：他方、未成年子女、主管机关、社福机構、其他利害关係人

3、濫用：惡戒过当、濫用法代权為保証、对特有財產管理失当、非為子女利益处分特有財產、暫子女拋棄繼承

↳得宣告停止一部或对子女权人中一人之親权 (史、模、羅、林)

4、双方均被停止親权⇒§1094应置監护人

5、效果

(1) 血緣关係、扶養义務 (§1114①)仍繼存

(2) 停止全部时，得類推§1055V酌定会面方式 (林)

6、程序

(1) 舊民作§592.593：受判決後，撤銷停止親权之訴，原告和解成立应以受停止人、未成年子女及利害关係人任之，以現行親权人或監护人為被告

(2) 新家事§104I③、74.3V⑩：成類非公事件：撤銷時受停止人、未成年子女、其他利害关係人得為声請人，現行親权人或監护人為相对人

7、撤銷：宣告停止之原因消滅後，得声請撤銷之

壹、沿革

一、~97：未成年監护、禁治產人監护

二、98修法前：由私的親屬監护朝向公的国家監护→引入公取監护与社团監护

三、98~：禁治產→監护、輔助 (施914-3)

四、108~：成年人意定監护

貳、未成年人之監护

一、开始監护之原因

1. §1091：父母或均无法行使、負担未成年子女权利义務

(1) 体親权之延伸

(2) 舊法：§1091但 已結婚者无須監护人 ＜ 注意規定說 / 仍有意义說

2. 父母委任=委任監护 (§1092)

(1) 書面為之：違反§73无效

(2) 就特定事項委任

A. 特定事項：限事实上之保护教養之具体事項及附隨之居住所指定权、懲戒权

B. 身分行為同意权、被收養代理权、財產行為之代理权、同意权均不得委任 (戴、楔、高鳳仙、許澍林、林)

(3) 限於一定期限內

A. 未明訂期限=永久委任=親权拋棄→无效

B. 无法成為法代 (无完整親权) (戴、楔、吳林、SC 28 渝上346例)

C. 委任監护屬委任契約→隨時得終止 (SC 28上1718例)

二、監护人

1. 指定 (§1093)

(1) 親权之延長→应以指定人有親权存在必要 (通) (已修法明文)

(2) SC 23上1703例：先死一方不得遺囑排除他方親权 (已修法明文)→先死亡一方遺囑此部分无效

(3) 同時死亡遺囑皆有效，行共同監护

(4) 一方停止他方得指定；尚存活但死時停止指定无效

(5) 後死亡无遺囑对前死亡遺囑之影响

A. 有效說 (吳)

B. 无效說 (高鳳仙、林、SC 62台上1198、97第3次民庭決议)；§1094明文

(6) 須遺囑為之→遺囑形式不合无效 (26院1650)

(7) 遺囑指定嬰兒有效 (限生母，因生父不可能為有效方) (林、高鳳仙、吳)

(8) 高史：附條件應於成就時生效（林：反對指定監護非財產行為附條件）

(9) §1093Ⅱ前：知悉15日內，願意者應陳報法院

(10) §1093Ⅲ：期限未陳報視為拒絕就職

2. 法定（§1094Ⅰ）：均不能行使或死亡無指定、指定拒絕就職

①与未成年人同居之祖父母（SC 27滿上69例：父系、母系不論⇒2人以上共用監護）

②与未成年人同居之兄姊：无論全血緣、半血緣⇒仍有§1096① 未成年不得任監護人

③不与未成年人同居之祖父母（SC 28上117判例：父系、母系不論）

④ §1094Ⅱ：知悉15日內陳報法院，未陳報監護人身分不受影響

3. 選定（§1094Ⅲ）

(1) ~89：親屬會议決之（24院1277）

(2) 89~§1094：法院選定⇒97~增行四等親內亦得聲請法院選定

(3) 声請人：未成年子女、四親等內親屬、檢察官、主管机关、其他利害关係人

(4) 受指定人：三親等旁血亲、主管机关、社福机構、其它適当之人（見少§6、身障§2）

(5) §1094Ⅴ：確定前由当地社福主管机关為監護人

4. 另行選定（§1106）：死亡Ⅰ①、經許可辭任Ⅰ②、受輔助或監護宣告§1096②、破產宣告§1096③未復权，得依前述声請权人声請另行選定

5. 改定（§1106-1）：事实足认監護人不符BIOC 依前述声請权人声請改定

(1) 具有不適任：個案審酌（ex：年老、長期滯留國外不履行职務、見少§7Ⅱ之情形）

(2) 依BIOC⇒§1094-1作审酌參考、見少§48 ⟶ 47Ⅱ、家暴§35前 ⟶ 31Ⅰ

6. 登記（戶籍§1、21、§1109-1）：法院取权囑任該管戶政机关登記

7. 辭任（§1095）：正当理由+法院許可（ex：重病、殘廢、年老体衰、出使國外、事故過多不能 遍顧（林、史））⇒§1106Ⅰ②

8. 消極資格（§1096）：①未成年人、②受監護或輔助宣告、③受破產宣告未復权

9. 职務⇒違反者屬无权代理

(1) 期间行使時，重大事項不一致⇒§1097Ⅱ、Ⅲ 裁判前听取監護人、受監護人、主管机关、社福机構之意見，酌定監護人中一人行使之

(2) 法定代理（§1098Ⅰ）

A. 含身分行為之代理⇒被收养時应得其同意（§1076-2），亦得替非婚生子女提起认領子女之訴（§1067Ⅰ）

B. 依法不得代理、利益相反⇒因声請或取权選任特別代理人（§1098Ⅱ）

(3) 對監護（§1097Ⅰ）⇒有保護及教养之权利义務、居所指定权、子女交还請求权⇒史林：含子女对手继父之同意

(4) 財產上監護

A. 開具財產清冊（§1099、1099-1）

(A) §1093Ⅱ、1094Ⅱ：監護人/法代指定時行政府指派人員会同开具財產清冊

(B) §1094Ⅲ：法院指定時，同時指定会同开具財產清冊之人

(C) §1091-I、II：2個月陳報，過於複雜得請延長

(D) §1091-1：陳報前對受監護人財產僅能為必要處分 ⇒ 違反屬無權代理

B、管理

(A) §1103-I：執行職務之必要費用由受監護人財產負担

(B) 財產

a、特有財產說(戴、林)：親權之延長⇒權限不超過父母⇒受§1088-I限制

b、所有財產說(李宜琛、黃右昌、胡、高鳳仙)

(C) §1103-II：得命監護人提出報告、財產清冊、結算書

C、受監護人財產之使用、代為或同意處分之限制(§1101-I)：須為受監護人利益⇒無償參加，孳息應歸屬於受監護人

D、應經法院許可之行為(§1101-II①、③)：代理購置、處分不動產、供其居住之建築或基地 (實務：①、②比較⇒處分指不動產所有權得喪⇒遺產分割仍處分)

E、投資行為之限制(§1101-III)：例外之有價証券因政府或金融機構發行或担保，安全性與存放於金融機構無異

F、受让財產之禁止(§1102)：无論有償、無償行為 ⇒ 違反？

(A) 特別代理人說(戴)：得依声請選任特別代理人

(B) 无权代理說(林、史、高鳳仙)：本條非注意規定

(5) 報酬州請求权(§1104)(SC 100台簡抗108號：監護人為被監護人之女得請求)

(6) 注意义務：善良管理人(§1100)(舊法：具体輕過失)

(7) 損害賠(§1109-I)：II監護關係消滅5年，有新監護人以其就職日起算

10、終止

(1) 絕對終止：其後不再有新監護關係

A、未成年人已成年

B、受監護人有行便親权之人(ex：停止親权宣告撤銷、監護宣告父母受撤銷監護、未成年子女受生父认領、被收养)

C、受監護人死亡

(2) 相對終止(§1094-I、1106-1-I)

(3) 終止後監護人义務

A、財產移交

(A) §1107-II：交還受監護人；受監護人死亡交還其繼承人(絕對終止)

↳林：若尚有親权人⇒應交還予親权人為妥

(B) §1107-I：移交財產於新監護人(相對終止)(ex：指定→法定/前順位→後順位/另行選定/收定)

(C) §1108：監護人死亡移交由其繼承人為之(相對終止)

B、結算(§1107-III：作成結算書送交親权人、新監護人、本人、繼承人/§1108：監護人死亡移交由其繼承人為之无繼承人或不明，由新監護人陳報法院)

(A) 林：應先由監護人之遺產管理人將受監護人財產移交於新監護人較妥

(B) §1107-II：新監護人、受監護人或其繼承人对結算書有承认权⇒未承认前原監護人不得免其責任

參、成年人監護

一、舊法：禁治產人之監護 <（專指成年人說（黃右昌）；未成年亦得宣告說（通））⇒§1109-2 20180改

二、開始監護原因：§14-1⇒§15⇒§76⇒§1110

三、監護人選定

1. 舊法：法定監護人順序＋徵求親屬會議意見

2. §1111-1：法院依職權定配偶、四等親內親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社福機構、其他適當之人中數人，並定會同開具財產清冊之人

3. §1111-2：指定前法院得命主管機關或社福機構進行訪視，聲請人或利害關係人亦得提出相關證據

4. 數人為監護人，法院得指定共同或分別執行職務範圍（§1112-1前）⇒未指定依§1088本文，共同為之

5. 指定職務範圍後仍得因聲請撤銷或變更指定（§1112-1後）

6. 數人行使不一致⇒準用§1097-2

7. 選定時審酌應以被監護人最佳利益（§1111-1 注意事項）

8. 另行選定、改定（§1113 準用→§1106、1106-1）

四、監護人消極資格、辭任（§1113 準用→§1095、1096）

五、利益衝突之保護與限制（§1111-2）

六、囑託登記（§1112-2）：宣告或變更時依職權囑託該管戶政機關登記（目的：保護交易安全）

七、監護人職務

1. §1113 準用→§1097~1109

2. §1112-1：尊重受監護之人之意思（包括選定前已表明之意思）（護養：看護個案／療治：對受監護人身心予以醫療）（梁、胡、林）

八、終止

1. 原因消滅（§14-2）：依§14-1聲請人聲請撤銷其宣告

2. §14-3得變更為輔助宣告

3. 受監護人死亡、辭任、受監護或輔助宣告、破產未復權、失蹤⇒另行選定（§1113 準用→§1106、1106-1）

4. 終止後義務（§1113 準用→§1107~1108）

肆、輔助

一、開始輔助原因：§15-1-1、§14-3、§14-3⇒§1113-1-1：置輔助人

二、同意權：受輔助人為§15-2-1各款行為時，應經輔助同意

三、輔助人（§1113-1-2準用）⇒排除§1098-1，因輔助人非法代

四、終止（§15-1-2、3）⇒死亡、另行選定、改定皆為原因

伍、成年人之意定監護

一、定義

1. §1113-2 I：本人与受任人約定於受監宣時受任人就為監護人之契約

2. 非一般委任契約 ⇒ 称委任人為本人＋本人須已成年

3. 可為数人，有約定分別執行取務者自応遵守其約定，无約定則共同執行取務 (§1113-2 II)

4. 受任人得為法人，其資格仍受 §1113-10 準用→ §1111-1、1111-2 限制

二、契約之要件

1. 応經公証 (§1113-3 I前、II)

2. §1113-3 I後：公証人作成公証書後 7日内書面通知本人住所地法院 (僅為訓示規定，違反契約仍有效)

三、生效時点 (§1113-3 III)：本人受監宣時

四、選定

1. §1113-4 I前：契約上之受任人，並指定会同現財產清冊之人

2. §1113-4 I後：已指定会同現財產清冊者，法院応依契約所載指定之，但未載明或顯不利本人利益者，法院得依取权定之

3. §1113-4 II後：有事実足认不利本人或品負不適任，法院得依取权就 §1111 I 所定之人為監護人 (品負不適任 or：意圖作害本人有重大嫌疑、長期於海外、年老)

五、另行選定、改定

1. 部分人有 §1106 I 情形，无須另行選定，由他監護人執行取務 (§1113-6 III)

2. 部分人有 §1106-1 I 情形，得依 §14 I 所定声請权人声請或依取权解任之，由他監護人執行取務 (§1113-6 III)

3. 全体有 §1106 I、1106-1 I，得依 §14 I 所定声請权人声請或依取权就 §1111 I 所列之人另行選定或改定 (§1113-6 I)

4. 執行同一取務之全体有 §1106 I、§1106-1 I 得依 §1113-6 I 就另行選定或改定，但執行其他取務之監護人无不適任情形，応優先選定或改定之 (§1113-6 II)

六、撤回 (§1113-5 I：得隨時撤回之 ⇒ 委任契約特質)

1. §1113-5 II後：一部撤回視為全部撤回 (一部撤回：含委任事務之一部撤回或对数人中部分人之撤回) ⇒ 一人对数人僅成立一委任契約，撤回无須通知全体 (意定撤回)

2. §1113-5 II前：書面十公証，§1113-5 II中同 §1113-3 I 後

3. 法定撤回 (§1113-8)：前後契約牴触，前契約視為私撤回 (主法理由：牴触指受任人之増減或監護内容之変動)

4. 終止

(1) §549 委任双方任意終止＋家事§165 回後意思能力時有程序能力之原則，本人得声請法院許可終止契約，但須有正当理由 (§1113-5 III前)

(2) 許可終止後応另行選定 (§1113-5 III)；受任人有正当理由亦得声請法院許可其辞任 (§1113-5 III後)

七、報酬別主約定 (§1113-7) (准：§1113-7後屋注意規定，已有 §1113-10 準用→ §1104)

八、排除代為処分之約定 (§1113-9)：可約定排除 §1101 II、III 限制

九、準用成年人監護 (§1113-10 準用→ 成年人監護 §1113 準用→ 未成年人監護)

壹、發生要件

一、親屬、家屬、配偶關係（§1114）

1 直系血親相互間

1. 不論自然、法定血親，无親等限制（上至高祖以上，下至玄孫以下）（史、林）

2. 父母对未成年子女之扶養义務之法源

(1) 史：§1084 / SC 113台簡抗大246裁、109台抗130裁：§1084Ⅱ⇒生活保持义務

(2) TW通、JP通：§1114①/JP§844⇒§1114① 不論成年或未成年（SC 56台上795例：保护原教養义務与扶養义務有別，後者不限未成年）⇒生活扶助义務

3. §1116-2：父母对未成年子女之扶養义務不因結婚經撤銷或離婚影响 ⇒ §988-Ⅰ女婚姻視為消滅類推§1116-2

② 夫妻一方与他方父母同居者其相互間：无同居即无扶養义務（SC 31上579例）

③ 兄弟姊妹相互間：法論半血、全血緣，同祖父母屬生親等需血，非本款所指

④ 家長与家屬相互間

1. 家長对妻应負扶養义務（SC 20上1143例、21上2238例）

2. 由家分離⇒家屬身份消滅（SC 28渝上1514例）⇒无扶養义務（SC 32上1725例）

3. 家屬相互間无夫妻、①~③之关係时，相互間无扶養义務（SC 27渝上1412例）

⑤ 74~§1116-1：夫妻相互間（舊法僅限於§972夫妻請求扶養之訴，SC 43台上787例、49台上534例、63.12.3第6次民庭決议(二)肯认之）（林）

↳ 戴東雄：§1003-1⇒家庭生活費殊難想像不含扶養費用 ⇒ SC 92台上6門 生活保持义務⇒不受§1117Ⅰ限制

二、須有受扶養必要（§1117）

1. 不能維持生活而无謀生能力者為限（SC 56台上795例：有工作能力不能具待遇工作、已盡相當能事而不能獲取业者，有受教利之在學生）（§1117Ⅰ）

2. §1117Ⅱ：无謀生能力限制对直血尊不適用之⇒仍受不能生活限制（SC 62.07.16第2次民庭決议(四)）

3. 夫妻間

(1) 妻无須考慮其謀生能力，夫須考量其无謀生能力而不能維持生活（林、戴）

↳ 对扶養妻係生活保持义務，妻養夫為生活扶助义務

(2) 不考慮说（SC 79台上2627例、101台上177、107台上2183、107台上1805、106台上1666、92台上2430、87台上2727、高义地院84婚122
高院103上927、台橋分院99家上23、台南地院100訴957、新北地院99家訴200、新竹地院98重國1、苗栗地院96訴183、88國1）

↳ 观§1117Ⅱ、1116-1可知夫妻应比照直血尊

(3) 考慮说（SC 43台上787例、司法院(33)院民(二)字16977號、林、SC 108第1291裁、7台上2202、SC 行94判1882行政、高院加重訴3）

↳ 文义解釋⇒夫妻非直血尊，且§1117Ⅱ立法目的係因考道

4. 判斷标时点及标準（SC 109台上670、108台上653）：以言辭終結時之狀況及日後可能發生之情事，推认請求時点是否合理

三、有扶養能力（§1118）：扶養而不能維持自己生活者，免除义務；但直血尊或配偶減輕义務

1. 戴、楼：§1118但即生活保持义務規定（林：若张個則尊親屬应刪除）

2. SC 102台上584、91台上1798例：§1118指有扶養能力者，无能力自无此條適用餘地

四、扶养义务之减免(§1118-1)

1、对负扶养义务者、其配偶或直血亲故意虐待、重大侮辱或其他身体、精神上之不法侵害 (§1118-1 I ①)

2、对负扶养义务者无正当理由未尽扶养义务 (§1118-1②)

3、§1118-1 II：情节重大，得免除义务 (cf：刑§271 II、276、221、224、286)

4、§1118-1 III：对未成年直血卑不适用§1118-1 I、II

5、§1118-1之减免应请求法院为之，非减免，裁判僅向後生效，不溯及既往 (刑§94-1立法理由)

6、§1118-1 体形成权，非抗辩权，无须待他人请求履行扶养义务

贰、顺序

一、扶养义务人 (§1115-1 I)

①直血卑 + 配偶 (§1116-1)

②直血尊 →③家長 →④兄弟姊妹 →⑤家屬 ⟶ ⑥子媳、女婿 ⟶ ⑦夫妻之父母

③ SC 21上709判例：有先順序人，後順序人无須履行扶养义务

④ §1115 II：親疏远近原則 ⇒同為直血尊、卑以親等近者為先

⑤ §1115 III：親等同一，应各依其经濟能力酌為扶养之

二、受扶养权利人 (§1116 I)

①直血尊 + 配偶 (§1116-1)

②直血卑 →③家屬 →④兄弟姊妹 →⑤家長 ⟶ ⑥夫妻之父母 ⟶ ⑦子媳、女婿

③有先順序人，後順序人无須履行扶养义务

④ §1116 II：親疏远近原則 ⇒同為直血尊、卑以親等近者為先

⑤ §1116 III：親等同一，应各依其经濟能力酌為扶养之

叁、扶养义务之二类型 (中川善之助)

一、生活保持义务(高度)：夫妻親子相互間，身分关係本質上不可缺之要素，保持对方生活即保持自己生活，又称共生义务 (云林地院87家抗13、SC 79判上2629判例)

二、生活扶助义务(低度)：一方力生活，他方有餘力始生扶养义务，係親屬关係補充要素之一

肆、程度 (§1119)

一、按受扶养者之需要与负扶养义务者之經濟能力及身分定之 (SC 18上957判例、30渝上360判例)

二、需要：不限日常生活费用，包括医療费用 (SC 29渝上1121判例)

伍、方法 (§1120)

一、当事人協议定之 (§1120前)，協议不成由親屬会议定之 (§1120中)

↳不服親屬会议决议時始得依§1137向法院声明不服 ⇒不得就協议逕向法院请求裁判 (SC 26抗上40判例)

二、親屬会议不為、不能决议或召开⇒由有利害关係人声请法院处理之 (§1132 II) (SC 45抗上396判例；实務上关於此类判例及学说，应解為法院予以裁判)

三、§6~§1120但：扶养费不能协议由法院定之

1、模、林：僅為注意規定，應修此條

2、SC 101号简抗50款：已协议由扶养金给付而对数额或支付方式有争议时有§1120但→声请案事非讼程序裁定之

3、SC 107号简抗140款：是否以扶养金给付有争议时，无§1120但适用

四、程度与方法之变更（§1121情事变更）

1、SC 19上2385例、18上985例：应证明社会上经济状况发生重大变动，日常生活费急遽增加致以前判定数额显失足

2、当事人（请求权人）：受扶养权利人、扶养义务人

3、方法之变更（SC 26渝上259例）：仍须依§1120先协议，不能协议应召集亲属会议请求变更，召开或决议不能、有困难始得请求法院变更

五、SC 113号简抗大246款 {
- 肯定说：SC 110号简抗298、113号简抗(大)246
- 否定说：SC 112号简抗70、98上1795

↳不问以§1084Ⅱ、§1114①请求，皆不受§1120限制→考量BIOC、§1170过当，能反映BIOC，法院有职权（家事§70）不受当事人声明、具公益性质

陆、消灭

一、当事人死亡：一身专属权（SC 49号上625例）

二、当事人身分关係消灭

三、扶养要件消灭

壹、沿革及單位

一、大清民律草案第二章家制、民國4年民律親屬編草案、民國14年民律草案親屬編均有規定

二、民國17親屬法草案刪除、主純個人主義

三、19~22參考草規定家制

四、重家長父權輕其權利(權利僅§1128 1條)主与古代之家有天壤之別(戴、林)

五、立法理由依Swiss採家質主義,但TW過於簡陋主无發揮空間,依空中樓閣,无切實基礎(楊、林、胡)

↳林、胡:瑞士家制之餘毒、我國家制之殘骸主家之存在可能无必要性

貳、定義

一、立法主義

1、JP:形式主義主戶籍同一即屬之

2、Swiss:實質主義主不問戶籍,為經營永久共同生活之親屬團体謂之家(TW主§1122)

二、要件:永久同居一家主通:永久同居之意思及事實缺一不可

三、出生之嬰兒主无意思能力,无同居意思但仍為家之構成員

四、22院848:兄弟出已分家,雖同門居住仍非一家

五、同居不以共財為必要

六、家基多家庭成員較優,民法較狹

參、家長(§1123I家置家長)

一、§1125本文家務由家長管理

二、推定(§1124前):非法律之擬制,係由家之成員共同推選,可依選舉或契約

1、史趨:非親屬人員无推選及被推選之資格

2、戴、楊、林、許濟林:§1123III雖有非親屬以永久共同生活為目的同居一家,視為家屬,自有推舉及被推舉權

3、35院解3160、史、林:受推定人不倫輩分、年齡、性別、婚生、意生

4、行為能力

(1)有意思能力即可說(楊、高鳳仙):推定後尚可指定家長

(2)完全行為能力說(戴、史、林):管理家務涉財產之管理、使用、收益、处分

三、法定:无推定或无法推定主§1124中、後:最尊輩;輩分同以年長者為之

↳最尊輩无完全行為能力主次尊輩自有行為能力最年長者(夫妻、兄弟以年長者任之)(胡、史、楊、林)

四、指定:法定家長不願或不能管理家務主指定家屬一人代理之(§1124末)

1、代理:非一般代理主非以法定家長為义管理,亦不受其指揮、約束,不因其死亡喪失权限

2、另推他人、另指定他人為家長,則指定家長免其職務(戴、史、楊、林)

肆、家属(§1123Ⅱ、Ⅲ)

一、§1123Ⅱ：除家长外，均为家属

二、§1123Ⅲ：非亲属以永久共同生活为目的同居一家，视为家属

三、夫妻非亲属，但休以永久共同生活为目的同居一家，视为家属

四、妻非亲属，但休以永久共同生活为目的同居一家，视为家属 (21院735)

五、父死承继任 家长，父之妻仍属家属 (SC 21上2238例)

六、父母与子业已未婚配偶共同生活，亦为家属(22院959、SC 23上3096例)

七、长工、佣人、学徒应视时间判断是否休家属

伍、家务之管理

一、§1125本文 家务由家长管理 ⇒家财之管理属家长 (ex：父死因清偿之必要，得就遗产设定负担) (SC 33上576例、1196例)

二、对内义务重於权利

三、处分家属私有财产，应得其同意

四、§1126：家长管理家务应注意家属全体利益 ⇒注意程度：

1、具体轻过失说(史高周仙、鼎、胡)：Sw註釋§332Ⅲ、舊§1100

2、抽象轻过失说(模戴、许涛林、林)：Sw註釋学说、新§1110

陆、分家析产

一、基於家属请求 (§1127)

1、无完全行为能力无请求权 (SC 32上5876例、31上1494例)

2、妻有同居义务，不得请求分析 (SC 29渝上527例)

3、妻无同居义务，得请求分析 (28院1935、SC 20上1437例、33上5119例)

4、休形成权，非请求权 ⇒无须同意(戴、林、模、史、高周仙；反对：鼎)

二、基於家长命令 (§1128)

1、§1128但：以有正当理由为限 ⇒防止家长滥用权力 (20院560)

2、正当理由：具体定之，不可一概而论 (ex：行为不检、有辱家声、多端为恶、遗害门楣) (SC 29渝上2085例、26上544例、广东地院103家声件裁)

3、家长依§1128令分析无给付一定财产之必要 (SC 33上464例)

↳亲属身份仍不消失 ⇒仍有扶养请求权 (SC 21上2160例)

壹、沿革：親族会

一、大理院牛上715、5上719、6上614、7上386、8上315、10上440、11上384

二、大理院解釋6統623

三、17親屬法草案

四、§74增訂§1132Ⅱ

五、林：親屬会议即將從民法中消失

貳、召集（§1129）

一、权限：法律明文者為限；非常设組织，係為处理法律事項而臨時組成

1、~96：慶注承认（B以父母濫用親权之纠正、宣告停止親权之请求）；96~刪除此权限

2、~97：監护之監督机关；97~法院取代；僅剩§1120中

3、§1149、1177、1179Ⅱ、1180、1197、1211、1213、1218（總承尚慶法）

二、召集权人（§1129）

1、当事人：仅是事項之本人

(1) 扶养权利人义務人（明文在類推§1131）、總承人、遺產管理人受遺贈人、遺囑執行人

(2) 通、5022上2246例、48台上1532例：遺產酌給权利人非当事人，係利害关係人

2、法代：当事人非完全行為能力人時

3、其他利害关係人：无人總承時之遺產債权債務人、親屬会议会員

參、組成

一、§1130：5人組成之

二、§1131Ⅰ順序：①直系尊 ②三親等內旁血尊 ③四親等內同輩血

三、§1131Ⅱ：順位→親等近→同居→年長者

四、§1131Ⅲ：裏推出席或不能出席；次順序親屬亮任之

五、收养关係（收公中无行為能力又无生父母之未成年之养子女，親生親子关係（收公中无行為能力又无生母之未成年子女，均屬§1131Ⅰ所订之未成年人（舊法）

↳家事§62 关於养父母及子女間断绝亲属会议之取得；无未成年人召开之必要

六、親屬会议已无監护之監督取得，已被法院取代；受監护人已无存在必要，家事§181Ⅰ准在為贊文

七、§1120中；扶养义務人及权利人均得類推§1131Ⅰ召集

肆、消極資格（§1133）

一、未成年（舊法已結婚）、監护人、受監护人不得為員

二、林：舊法因利益衝突監护人；修法後在屬多餘

三、通：仍能監护人常立於相反之地位

伍、辭任 (§1134)

一、須有正當理由 (ex 重病、遠隔異地、年老体衰)

二、依法在為親屬會议 会員之人

1. 含§1132 法院之指定會議：職務輕鬆，不過会议而已，指定強要為之並不為过 (胡、鼎、史)

2. 不含§1132 法院之指定會議：血親範圍較普例大，姻親範圍較外國立法例大，縱使指定会員負担义務有过酌之嫌 (模、戴、林)

3. 家事§183 準用 → §122 明文指定会員辭任之事由：未成年、身障或疾病不能執行職務、住居所与法院所在地隔離、其他重大事由

陸、開会

一、§1135前：3人个出席即可开会

二、會應自行出席，无法 使他人代理 (SC 31年 617例)

柒、決议

一、§1135段：非有過半数同意，不得為決议

二、親自出席与无法以書面表決

三、表決可否同数时不得為決议 (過半数)与重行召集会议 (戴、模、林)

四、§1136 迴避：對所议事件有個人利害关係者不得加入決议 与但仍可开会並表意見，仍以出席人数 (史、戴、模、林、劉、仏)

五、§1132 会议召开或決议有违反应由有召集权人声请法院处理之 (SC 109年簡抗168裁：未合法送達与会议不能或難以召开有異)

捌、声诉不服

一、§1137：总计§1123 所定有召集权人於3日内向法院声诉不服

二、通：決议人員均可声诉不服；漢右書：不得再異议，徒滋紛紜

↳後會不服时，应以其會員仍有親屬会议权為被告 (史、林)

三、以诉的方式為之，法院以判决 审理 (SC 29抗10例)

四、声诉不服須以決议有效為前提 (就內容实質不当而異议) 与決议之效力应 提确认決议无效之诉 与有确认利益即可起诉，无期限 (通)

↳无效之情形：組织不合法 (違反§1130、1131、1135前) (SC 18上2577例)、決议方法不合法 (違反§1135段)、內容違反強行規定

五、紛爭一次解決与声明不服者 撤銷決议及變更 決议內容 (ex 遺產酌給請求权人对酌給決议不服，法院仍可斟酌情形行以核定) (SC 98当上1532例)

壹、繼承之根據

一、學說

1. 人性公益說（郁崇）
2. 社會安全共同需要說（李宜琛）
3. 維持社會安全說（劉志鵬）
4. 意思說（胡）
5. 遺意與親屬共同需要說（施啟揚）
6. 無主財產說（戴）
7. 繼承人生活保障與社會交易安全保護說（林）
8. 綜合說（史、林）

二、繼承制度之根據

1. 避免無主財產之產生
2. 貫徹遺囑自由
3. 保護交易安全

三、繼承權之根據

1. 對遺產貢獻之評價
2. 繼承人生活之保障
3. 被繼承人意思之推測

貳、沿革

一、19～74

1. 廢止宗祧（嗣）繼承（男子繼承）
2. 貫徹男女平等
3. 法定繼承自物留分限制遺囑處分自由
4. 當然繼承主義

二、74～96

1. 刪§1142 養子女與婚生子女差別待遇
2. 廢除指定繼承人制度（刪§1071、1143）
3. 縮短 遺產分割禁 止期間（§1165Ⅱ 20年→10年）
4. 刪§1167 統一 遺產分割效力為共同共有
5. 修正拋棄繼承之方式（§1174Ⅱ：向法院為之）

6、明文拋棄繼承效力 (§1176 → 1176 I ~ III)

7、增訂拋棄繼承權人對遺產之管理責任 (§1176-1)

8、增訂親屬會議 選定遺產管理人之權限

9、增列利害關係人及檢察官得聲請指定遺產管理人

10、加強對遺產之保存

11、增列口授錄音 遺囑

12、開視程序 (§ 1213)

13、遺囑之撤銷修正為撤回

三、96.12.14 修正，97.1.2 施行

1、增訂 §1148 II 保證契約債務之限定繼承

2、增訂 §1153 II 明文無限制行為能力人 限定繼承

3、§1154 II 明定同為 限定繼承之例外事由

4、§1156 限定繼承期間及程序之修正

5、§1163 ④ 增訂期限內未提出遺產清冊不得主張限定繼承

6、修正 §1174 II 拋棄繼承之法定 期間

7、明定通知義務為例示規定 (§1174 II 後 ——→ §1174 III)

8、增訂 施§1-1 I：修正施行前未逾限定或拋棄繼承之法定期間 自修正施行日起 適用修正後規定

9、施§1-1 II ——→ §1153 II、施§1-2 ——→ §1148 II 得溯及適用

四、98.5.22

1、刪第二節，合併 1.2 節為概括繼承有限責任

2、增訂 §1148-1 死亡前2年贈与

3、刪§1155，修§1156.1156-1、增§1162-1、1162-2、1159 II、III、1161 III

4、文字修正：§1153 I、1157 I、1161 I、1163、1174 III、施§1-1 I

5、新舊法適用：施§1-3

6、修§1138、1210

五、103：修§1212

六、104：修§1183、增§1211-1

七、115：刪予足特留分

壹、資格

一、同時性原則：繼承開始時存活為限（須有權利能力）

1. SC 79渝上454例：被繼承人死亡後不久子女隨即夭折仍可繼承

2. 胎兒可繼承（§7：胎兒視為既已出生）

3. §11同時死亡→不得繼承

二、§1138→法人不得為繼承人

1. Gov. Swiss 國庫為最後繼承人

2. TW §1185 非以國庫為繼承人

三、外國人→總則施§2（法令限制內有權利能力）

└note：土地§18 外國人地權平等互惠原則→非地權平等互惠國（36國左右），無法繼承土地（ex：越南、印尼）

四、中國人→兩岸條例§67 不得過50萬，並配偶不限

貳、種類

一、血親繼承人：有§1138之順序 ↔ 無限親屬繼承主義

二、配偶繼承人：不在法定順序內，有特別之地位

參、順序

一、血親（§1138）

① 直血卑

1. §1139：親等近者優先

2. §1065 非婚生子女經生父認領後生父之直血卑

3. 20院50、647、21院747、SC41總上518例：女子得繼承／SC 32永上1199例：出嫁為民有繼承權

4. SC 70第22次民庭決議：祭祀公業條例 施行前，祭祀公業之繼承依習慣→男子、奉祀本家女子及從母姓子孫有派下權→民法於此不能為全部適用

5. 37院解3791：不限同姓氏、不限有無親權

6. 含擬制血親，但不當然繼承遺產之權利義務

7. 22院895：遺產非養子女所應繼承，惟有血卑時共同要有人承認其身份看在認養子女得輪值時，始得輪值

8. 養子女與本生父母間權利義務於收養期間暫停（§1083）→無繼承權

9. 繼子女為直姻卑，不得繼承

② 父母

1. 含養父母，但出養之本生父母不得繼承

2. 37院3779：祖贊男或出嫁女皆有繼承權

3. SC 32上1067例：不因再婚受影響

4. §1065 生母对非婚生子女有继承权(视为婚生) (20院585、SC22上1727例)

5. 后妻对前妻子女为直系姻亲 ⇒ 无继承权 (SC26渝上608例)

③ 兄弟姐妹

1. 含半血缘 (21院735、22院898、36院解3762)

2. 养子女、亲生子女 ⇒ 拟制等血,有继承权 (32院2580、SC32上3491例)

④ 祖父母

1. 22院898:含外祖父母

2. 34院2824:祖父改嫁不影响对孙之继承权

3. 32院2580:养子女与养父母之父母亲生祖孙关系 ⇒ 有继承权

4. 养子女被收养前所生之子女与养父母间本有继承权 (戴、模、林)

二、配偶

1. §1144:相互间有当然继承权

2. 续继承开始时有合法婚姻,若继承前离婚或撤销自无继承权

3. 继承后再嫁、再娶对即得继承权无影响 (21院180、22院851、SC29渝上702例、30上2114例)

4. 亲属施行 §1 → §988③ 前后婚姻同时存在 ⇒ 前后婚姻之配偶均有继承权

5. ~74.6.4前 重婚使后婚姻得撤销 ⇒ 前妻於夫死后始起诉撤销 (§992.但书§956II),回撤销无溯及既往 (§998) ⇒ 后妻继承权不受影响 (林)

↳实:后婚姻撤销视为夫死亡时已解消 ⇒ 前妻得回复其继承权

壹、指定應繼分

一、法無明文，通說實務均肯认（許地院94家訴112）

二、§1138：須以遺囑為之，且不得違反特留分之規定

三、受益人須為繼承人

四、須得分割才能確定权的物由何人取得

五、受益人得單独執行理指定应繼分之登记（土登規則§70適用於法定及指定）

六、不罹於消滅時效（遺贈為5年）（29院1985、36院解3762、5628上631例、史、戴、林、振、李宜琛）

七、受益繼承人先死亡時，代位繼承人可繼承指定应繼分

貳、法定应繼分

一、配偶（§1144）

①与所有直血卑平均

1、林：規定不合理⇒JP§900①配偶占½

2、JP神戶裁判所平成6.6.25 认以TW民為本國法之實体实有不当，依JP法例（國際私法），TW民此部分違反JP公序良俗，排除適用

②与父母、兄弟姊妹繼承為½

③与祖父母繼承時⅔

④无血親繼承人時為全部

⑤重婚未撤銷或有§362、55情形

1、通、实：平均分配配偶应繼分说

2、模：与第一順位人期繼承採前後妻同時比平均总数，与後順位繼承人則為½

二、血親繼承人

1、§1141本文：同一順序，按人数平均繼承

2、§1141但：法律另有規定者，如：§1139、1144

3、代位繼承人僅得繼承被代位人之应繼分，不得算入总人数

4、§1142養子女应繼分為婚生子女之½⇒違反平等原則⇒已刪

壹、性質

一、代位权说（21院754、胡）：被代位人生前以须有继承权存在为必要

二、固有权说（北32上1992例、87台上1556、通、23院1501）：採前说特有论理上矛盾+立法意旨

貳、要件

一、继承开始前被代位人死亡或丧失继承权（§1140）

1、§1176 ⇒ 拋棄則无法代位

2、继承後死亡屬再転继承，非代位继承

3、被代位人与继承人同時死亡

(1) 同時存在原則（§11）⇒ 互不為继承人

(2) 北32上1992例、林：代位继承，係保护代位人之期待利益 ⇒ 仍可代位继承

4、继承开始後始生丧失之事由 ⇒ 宜认溯及继承开始時即生效力（史、胡、模、劉信章）

5、親等較近之直血卑全数死亡

(1) 本位继承说：有§1139、1140 ⇒ 以孩子女平均继承（戴、史、高院93度事8号、彰化地院106家訴43、基隆地院106重家訴1）→ §1140 反面解釋（一人或数人）于继承开始前应继分本即浮动不定

(2) 代位 继承说：孫輩之应继分不应变多+§1138~1140之條文編排順序旨在维护各系之公平，无均分遺產之概念（林、模、振）

6、丧失权所生子女

(1) 肯定说：固有权说，只須視死亡時代位权人是否存在（通、林、戴、振、史）

(2) 否定说：无期待地位（模、劉得寬）

7、丧失权所收养子女

(1) 肯定说：於法无据，且收养已需经法院认可（林模）（区分说：认為仍应具体审查是否以继承為收养目的（戴））

(2) 否定说：避免失权者以此達成继承目的（史、劉得寬）

二、被代位人须為被继承人之直血卑（§1140）

1、无親等限制 ⇒ 孫子女得被代位

2、丁：养子女之婚生子女、养子女之养子女、婚生子女之养子女均得代位

三、代位人须為被代位人直血卑（§1140）⇒ 父母通乙偶均不可代位（5C 76簡上608例、41台上546例）

└ 被代位人子女、孫子女皆存在 ⇒ 類推§1139

四、代位人须為被继承人之直血卑

1、原因：固有权说

2、收养前养子女已有其直血卑 ⇒ 取决於收养前直血卑与养父母間有无血親关係（ex：§1077Ⅱ）

3、史、模、39院解3010 认养子女之子女有意思能力，经同意原留养家例外不消滅 ⇒ 96修正§1083应无法再相同解釋 院解3010应停止適用（林）
└ 林、模、史：可认留於养家之孫子女得对养祖父母代位继承 ⇒ §1140应為廣义解釋 ⇒「為」直血卑即可

參、效力：代位继承人有权人应同§1141 予被代位人之应继分

壹、立法理由

一、维持倫理道德 (通大多数因此立法理由)

二、避免遺産秩序混乱

三、確保遺囑自由

貳、事由

一、当然失权－絶対失权 (§1145①) ⇒不得被继承人為任何表示即当然失权

1. 須对被继承人或应继承人為之

(1) 继承人：自JP§891① ⇒相同解釋⇒指先或同順位之继承人 (通) ⇒戴瑀如：殺害親等較近之血亲因具代位继承之期待权故仍失权

(2) 殺害時未有继承人身份 ⇒不影响继承权 (通)

(3) 須明知被害人係被继承人或应继承人

2. 致死之故意

(1) 无論既未遂或預備、教唆、嘱托殺害

(2) 傷害致死不含 ⇒无致死故意 (通、83.12.14台民一2258号函覆台高院)

↳范瑞：§1145I⑤ 傷害致重傷經表示喪失，但死七无法表示forth无喪失不妥

(3) 通：不問有无謀奪遺産意圖 ↔ 黑、最：可仅皆有謀奪財産之意圖

3. 須受刑之宣告

(1) 已致死 ⇒是否仍須受刑之宣告後才喪失

A. 否定说：極嚴重⇒發生即剝奪 (劉鐘英、楼、戴東雄)

B. 肯定说：歷史解釋⇒民15民律草案继承編§6① +FR、JP比較法，应為相同解釋 (林)

(2) 緩刑期滿 ⇒刑§76刑之宣告失其效力 ⇒自不失权 (林、戴)

二、当然失权－相对失权 (§1145II)

1. 可宥恕回復继承权

2. §1145I② 之要件

(1) 关於继承之遺囑 (ex: §1187、1200～1165I、60、信託§2)

A. 非婚生子女之认領无須遺囑，但遺囑认領未生效力⇒間接發生继承法上效果应包括在內 (林、李宜琛)

B. 遺囑指定監护人 (§1093) 无关继承⇒非关於继承之遺囑

(2) 有效之遺囑 (通) (ex: 脅迫受監宣人為遺囑不該当) (洪遊梁：反对⇒輕重失衡，脅迫受監宣人惡性較大)

(3) 有作欺或脅迫之行為 ⇒图利意思？

A. 否定说 (通)：不法在於背於遺囑之意思自由

B. 肯定说 (戴炎輝、陳国祺)：破坏遺産秩序

(4)须因诈欺胁迫而为关于继承之遗嘱 ∋ 依§1219～1222 撤回後

A、不适用说(史)：自始未生效

B、适用说(戴、林、罗、苑振、詹国篇)：已先丧失继承权，撤回应不影响以求安定，且撤回非宥恕

3、§1145Ⅰ③要件同§1145Ⅰ②

4、§1145Ⅰ④之要件

(1)伪造、变造、隐匿或湮灭 (ex：§1195Ⅰ的按遗嘱记载不实)

A、旨在保护遗嘱意思 ∋ 变造合当事人真意非失权事由 (ex：自书遗嘱未填日期继承人代填，无效但不失权) (林、模、史、詹宗珠)

B、委任继承人缮写遗嘱但其藏匿属隐匿 (林) ↔ 史：属§1145Ⅰ② ↔ 林：无诈欺胁迫非§1145Ⅰ②

C、图利意思 ∋ 同§1145②

(2)关於继承之遗嘱 (林：无论有效或无效遗嘱；高院108年上22：须有关继承并为有效之遗嘱)

A、伪造遗嘱，无中生有，自属无效

B、继承开始後变造为已生效遗嘱

C、隐匿或湮灭於继承开始前须符合法定要件，继承开始後之遗嘱则为已生效之要件

三、表示失权 (§1145Ⅰ⑤)

1、继承人对被继承人有重大虐待或侮辱 (虐待：身心上之痛苦；侮辱：对人格有毁损)

(1)消极不作为亦属之 (SC 74年台上187の例：终年卧病不予探视)

(2)以社会通念衡量重大性 (通)

2、被继承人表示继承人不得继承

(1)继承权属身分权，依身分行为 ∋ 表示不以完全行为能力为必要，意思能力即为已足 (通)

(2)限制行为能力人无须法代同意 (通)

(3)身分行为 ∋ 法代不得代理，亦不得附条件

(4)不要式 ∋ 明黙示皆可 (ex：§1052Ⅰ③.④、§1081Ⅰ① 已起诉终止关係，可认已有不得继承之表示存在)

(5)遗嘱为之 (SC 22上1250例：非必要)

A、林：不要式 ∋ 无效遗嘱亦生失权效果

B、通、黄、SC72台上4710：决定遗产为要式，条文亦应以有效之遗嘱为限

四、宥恕 (§1145Ⅱ)：已为某行为後对损责任付於不问之感情表示

1、性质

(1)感情表示 (通) ∋ 无须行为能力，以认识宥恕意义之能力为已足

(2)意思表示 (胡、鼎)

2、不要式 ∋ 不问明、黙示 (ex：明知丧权事由但仍遗嘱指定应继分可解为宥恕)

3、表示失权之宣怨

(1) 绝对失权说(否定说)：§1145 II 明示其一，排除其他 (胡李在琛、刘锺英)

(2) 相对失权说(肯定说)：既为表示失权，本可宥怨後权，且依严重性，自有举重明轻之适用 (通)

第、效力

一、时之效力

1、无须经法院宣告即生失权效力 (通)

2、继承开始前之失权

(1) 史：丧失推定继承人之资格，失权效力在解为於继承开始时发生

(2) 通：自於事由发生时即生失权效力+宥怨 若採前说将无回復继承权 因其尚未失权

3、失权於继承开始後：溯及继承开始时丧失继承权 (通)

二、对失权人之效力：相对效力，仍可为他人之继承人

三、对失权人直系卑亲之效力：不生任何影响

四、对第三人效力：§1145 I ① 须受刑之宣告→判决前不失格→以继承人资格处分遗产之效力

1、刘锺英、鼎：对第三人若生溯及效力则对第三人已取得之权利有失公平→应以裁判後始生对第三人效力

2、林、廖国器：此属人的效力，非时的效力，应以财产法上无权处分、善意受让及善意债务人清偿处理

壹、立法理由

一、§1146Ⅰ：方便一次请求，概括回复，无须个别起诉（批评：实务上§767、1146Ⅰ均一一列举）

二、§1146Ⅱ：从速确定继承关係，保障交易安全（批评：已有其他保护第三人规定，且短时效不利真正继承人资格）

三、统一确定继承人资格（批评：僅对真正继承人请求返还时考虑即可）

貳、侵害继承权

一、意义：继承既得权＝已为继承人之权利

1、继承资格被否定 ⇒ 可由确认继承权诉讼解决

2、遺產标的物被概括占有 ⇒ 可由§767解决

3、应合併认为係对於继承人地位请求概括回復被占有之遺產标的物

二、時效

1、SC53台上592例、40台上993：於继承开始時自命為继承人而行使遺產上权利

2、戴、模：不分继承开始前、後

3、J437：SC53台上492例合意 ⇒ 僅為侵害態樣之一 ⇒ 自继承开始時或其後有人否认真正继承人之资格並排除占有

參、性質

一、形成权说（戴炎辉）⇒ 以诉请求回復继承权屬形成之诉

二、集合权说（模）：係個別之物权请求权之集合，兼确认及給付诉訟性質（批评：J67、§767、§1146Ⅱ時效均不同，若目的同一似无必要）

三、獨立权说

1、確认、給付混合请求权说（SC $\frac{40台上730例、53台上1928例、珠、戴東雄、模}{形成权说}$）

2、单純給付请求权说（林、史、J771、鼎、胡）

(1) 继承资格之確认僅係判決之先決問題，非係之声明之終局标的

(2) 可合併提起給付及確认诉訟，亦可於給付诉訟中提起中間確认之诉

(3) J771、林：§1146Ⅱ僅使表見人取得拒絕返还之抗辯权，不影响真正继承人之资格或已取得之权利

肆、競合（§767 vs §1146）

一、法條竞合说（劉得寬）：雖於§1146Ⅱ後原有继承权即已消失，表見继承人溯及继承开始時取得继承权，真正继承人无§767（SC40台上730例一廂、3判院解3797）

二、時效相互影响说（戴、史）：兩者併存，但§1146係特別请求权，应优先適用 ⇒ 以§767起诉仍得以§1146Ⅱ抗辯

三、自由競合说（黃宗樂、林、郭振恭、陳國男、J873王澤鑑協同意見書、J771、SC90台上464、40台簡上54）

伍、请求权人

一、真正继承人：§1146Ⅰ被害人＝真正继承人

二、真正继承人之继承人

1、一身專屬说：不得行使（珠、胡、鼎、戴、模）

2、得继承说：得代已死亡之人行使（孤、史、林）

三、法代（§1146 I）：此為代理請求，非固有權利，若法代為侵害繼承權人⇒§1086 II 特別代理人

四、遺產管理人（§1184）：若仍承仗繼承之人非繼承人得向其請求之

五、共同繼承時（§1151）須按§828 II 準用→§821 請求

陸、請求之相對人

一、僭稱繼承人：自命為繼承人而占有遺產者

二、表見繼承人：外表上足使人信其為繼承人之人

三、共同繼承人中一人或數人排除他共同繼承人之繼承權而占有遺產（SC 29 簡上 1340 例、1504 例）

1. 現實占有被侵害之遺產

2. 對真正繼承人地位有爭執

四、受讓前述人財權之第三人

1. 肯定說：恐意第三人若不能請求，則將遷延時日，增加脫產機會⇒保護真正繼承人（戴東雄、37 院解 3856）

2. 否定說：請求標的應為曾占有遺產及對是否為繼承人有爭執，且自有§767 及善意規定（楊、鼎、胡、琛、戴、SC 53 台上 1728 例、林）

3. 折衷說：限第三人与侵害人立於同一「相對地位」時才能請求⇒個別移轉一部財產時非相對人（史、黃宗榮）

五、受仗令頁子女對第三人：應排除同一順位之其他繼承人已取得之財產（§1069但）（SC 1 台簡抗 180 裁）

柒、行使

一、无限制⇒可訴外請求（通）

二、以作為之

1. 列舉返還之遺產

(1) 形成訴訟說－不必列舉說（戴、楊）：依立目的係回復繼承權

(2) 給付訴訟說－不必列舉說（史、林）：得請求侵害人占有之一部或全部返還，无須個別行使

(3) 混合訴訟說－不必列舉說（琛）

(4) 混合訴訟說－應列舉說（楊）：不過便宜而合併為一訴，仍須列舉個別財產權，未列舉者，既判力及執行力均不及未不降之財產

(5) 實務－給付訴訟說－應列舉說

A. 雖不必列舉說較合法理，惟操作上實不能貫行

B. 給付訴訟之聲明應表明被告所負給付義務之內容⇒表明將使法院依民訴§249 I⑥ 认其訴不合法以裁定駁回之（SC 33 上 3077 例、38 簡上 1641 例）

C. 縱勝訴，因无明列執行標的物⇒執行法院无從執行⇒僅具中斷時效之意义，實益不大

2. 真正繼承人不知遺產範圍，无法列舉（Ger§2027）

(1) §1177 II 不法管理 準用→§1177 I ⇒恐意僭稱繼承人可被真正繼承人主張享有不法管理所生之利益

(2) 類推§173 II 準用→§540 ⇒不法管理人与无因管理人負相同報效務

三、黃悌源：共有人間僅有遺囑、特留分給予時，不適用§1146 亦不能行使基於特留分扣減之物上請求权（§767）

捌、時效（§1146Ⅱ）

一、起算時点

1、2年：知悉受侵害時起，非知悉繼承开始

↳无行為能力人以法代知悉起算（SC 29上174例）

2、10年：繼承开始時（不得大於前段之2年）

二、時效性質

1、2年：消滅時效

2、10年

(1) 消滅時效說（通，SC 32上3143例、31院解3842）

史：消滅時效說
模：除斥期間說

A、文義解釋

B、若解為除斥期間，施§2形同虛設，因§1146Ⅱ為繼承篇唯一之時效規定

C、比較法（JP、Ger、FR、Switz）均長於TW，宜解為消滅時效，使其有中斷机会，保护真正繼承人

D、時效完成後，义務人仍得拋棄已完成之時效利益（史）

E、林：应為特殊之消滅時效，種行起算之可能

(2) 除斥期間說（模）：不得中斷、延長，始違短期時效之目的

三、与§767：自由競合說＝罹於§1146Ⅱ後仍得行使§767

四、J771：兼顧法安定性，不論动產或不动產行使§767時有§125 15年時效限制（補充J107、J164）

五、罹於時效

1、僅生回復义務人得拒絕給付之抗辯权（SC 29滿1867例）

2、31院解3997、SC40當上730例一脈：抗辯权行使後真正繼承人与表見繼承人地位互易

↕

3、通：J771

(1) 不因有抗辯权而取得繼承权，須另以時效或善意取得規定為之（戴）

(2) 若对1人已滿2年，对未滿2年之他人仍得請求§1146，繼承权不因時效消滅

玖、拋棄

一、繼承开始前：无效（通、SC 22上2256例），因§1146尚未具体發生，拋棄須客体之存在

二、繼承开始後：有效（通），因繼承权（§1174Ⅰ）、特留分均可拋棄，§1146屬財產权之一种，其拋棄无違公序良俗，无禁止之理

三、效力

1、對得意：僭称繼承人取得繼承权

2、戴：使其同繼承人增加应繼分，惟若真正繼承人有明白表示欲使表見繼承人取得繼承权時不在此限

3、林：繼承权係身分权，不得転让＝僭称繼承人无繼承权，真正繼承人仍未丧失遺產所有权並仍須承担繼承債務，应繼分亦应无变动

§1147：总继承，因被继承人死亡而开始（SC 32上442例；当然继承，无待主张）

壹、标的（SC 102台上588：须於继承时仍属被继承人之财产）

一、得为继承之标的

1、权利：一身专属权外一切财产上权利＝债权、物权、准物权

(1) 无体财产权：专利权、商标权、著作权

(2) 支配权

(3) 请求权：债、物

(4) 抗辩权：消灭时效抗辩权、先诉抗辩权

(5) 形成权：撤销权、解除权、终止权、承认权

2、占有：§947 承认占有得为继承标的

3、遗体

(1) 否定说：尸体非民法上所谓之物＝非继承之标的（胡）

(2) 有处分权说：继承人有埋葬尸体之权利义务（模、史、琛、林、SC 107台上209）＝继承人依公同共有方式处分之

(3) 林、史、琛：遗体受不法占有得请求返还

4、义务

(1) 私法上债务：非一身专属者均得总括承＝最高限额保证债务於死亡时未成立，不为继承之标（SC 81台上111、51台上2789例）

(2) 公法上义务：生前应纳之税金义务与公法所为处分责任中财产上义务（31院2416）

二、不得为继承标的

1、一身专属权利

(1) 非财产权：身分权、人格权

(2) 与人格密切关联之财产权：扶养请求权（§1114～）、财产着手求权（§1057、1058）、精神上损害请求权（§195 II、977 III、979 II、999 III、1056 III）

(3) 以特别信任关係为前提之权利：依委任契约而生之请求权

(4) 受任人死亡之信任遗产（信托§10）

2、一身专属之义务

(1) 以身分为基础之债务：扶养义务

(2) 债务之履行与被继承人之特定知识、技术相结合者（ex：艺术家、作曲家作为义务）

(3) §512 承揽人之工作以承揽人个人技能为契约要素者，承揽人死亡者，其契约为终止＝不生继承

(4) 以被继承人之特别信任关係为基础之债务（ex：取保保证）（SC 51台上2789例）

(5) 罚金

A、肯定说：刑诉§470 得向就受刑人之遗产执行（戴、胡、琛、林）

B、否定说：由刑诉§470反面解释、刑止於一身原则＝不得就继承人之固有财产执行（史、振、林）

參、法律關係

一、契約關係：§345、406但書、421、464、474 不因當事人死亡消滅由繼承人承受（5C 51台上2644－廢 因§407已刪除）

二、無權代理

1、無權代理人為繼承本人

(1) 當然有效說由繼承人負本人行為責任說（楊、琛）：禁反言原則

(2) 非當然有效說由繼承人有承認權（史、戴、林、李琰琰）

A、有他繼承人將剝奪他同為繼承人之承認權或拒絕權

B、保障善意相對人有§114撤回權，即保护第三人

C、應認承認及拒絕權由全体準公同共有，行使應得全体同意或多數決（§831 準用→ §828II 準用→ §820I）

2、繼承無權代理人：非當然有效，仍繼承權或拒絕權，亦繼承無權代理之損賠責任（§110）

3、無權處分之繼承

(1) 無權人繼承後取得權利：§118II 自始有效

(2) 單獨繼承無權利人：不當然有效（5C 29 渝上1405例：修法後改採有限概括繼承，使用權宜說）由拒絕承認仍繼承損害賠償

肆、費用（note：遺產未與固有財產混合）（§1150）

一、性質

1、列舉規定說（擴張解釋）：若限縮將使繼承人以固有財產負擔費用負擔繼承費用，有違立法意旨（林）

2、例示規定說：一切繼承費用，原則上由遺產負擔（鼎）

二、內容

1、管理費用：保管費用、拍賣費用、清償而變賣之費用、§1087遺產管理人報酬、§1177I①編製遺產清冊費用（5C 108台上103）

2、分割費用：分割協議之決定、分割方式決定後執行之費用

3、遺囑執行費用：提示、開視、交付遺贈所需之費用、遺囑執行人之報酬

4、喪葬費（通、5C 109台上89）

(1) 林：若解遺体為繼承標的由埋葬費用屬遺產管理費用

(2) 史、林：限定或拋棄繼承而遺產不足支付喪葬費用時，於理仍應由其固有財產負支付責任

(3) 老人福利§24：無扶養義務人或無扶養能力，當地政府執理喪葬，費用由遺產負担，無遺產由當地主管機關負担

伍、遺產酌給請求權（§1149）

一、非繼受法由沿襲我國固有制度，係根據死後扶養之思想

二、要件

1、請求人須為被繼承人生前繼續扶養之人

(1) 繼續扶養：無時間限制，僅以至被繼承人死亡為止未曾間斷（通）

(2)身分之限制

A、法定扶养说：体系解释，应与在前之亲属编规定之扶养同义（泥操、刘钟英、鼎）

B、事实扶养说：採前说将使因该人非被继承人负法定扶养义务，竟视其承食受，殊不近人情事故，不足发挥社会意义（通）

C、道德扶养说：前说无标準，将引起爭端，第一说过狹 ∋ 以道德上扶养义务为限（琛）

D、36判解3762：事实上夫妻/SC 为台上1571例；妻/22院851：寡媳

2、不能维持生活无谋生能力

A、肯定说（通）：无论採法定或事实说，基於死後扶养思想，无扶养必要即无须给付（SC 26渝上39例）

B、否定说（史、胡）：何推定有继续扶养之意且前说与养老恤贫之纯风美俗相背（SC 9台上33）

3、被继承人未为相当之遺贈

三、方法

1、亲属会议僅能决定数额 ∋ 已達成数额者不必请求酌定（通）

2、§1149不服 or 難以召开 ——→§1137法院（SC 23上2053例、37上7137例、40上937例）

四、标準

1、区别生活保持义务与扶助义务说：事实上夫妻属前者，其餘亲属属後者

2、依所受扶养程度及其他关係决定说（通、SC 104台上1610）

五、上限额

1、应继分限度说（通、鼎、戴、楔、琛、刘钟英）：不得較任何继承人之应继分為高，因若如此將等同承认亲属会议得變更继承人範围

2、特留分限度说（振）：限於所有继承人特留分範围内（17继承法草案§12）

3、继承人实際所得限度说（戴、林）：遺贈不得侵害法定继承人之特留分，酌给僅限任何继承人实際所得之数额（SC 22上719例 23上4083例）

4、侵害特留分限度说（吴怡章、胡）：不得違反§1187特留分规定

六、请求方式：依继承回復§1146執理（28院1888）

林：主体不同，§1146為继承人，酌给则非；§1146似物上请求权，酌给则為較一般财產权更特之债权请求权（§1160、1176Ⅱ立法意旨）

七、顺序：遺產不足清偿债务、交付遺贈、酌给遺產

1、最优先说：酌给 > 清偿债务 > 交付遺贈（楔）

2、与遺贈同顺序说：清偿债务 > 酌给 = 交付遺贈（戴芳輝）

3、遺產债务後，交付遺贈前说：清偿债务 > 酌给 > 交付遺贈（通）

林：有权受酌给人因获遺贈而失格者，应提升至与受酌给人顺序相同

八、拋棄：酌定前得拋棄，一但拋棄即消滅

九、消滅時效

1、類推§1146Ⅱ说（28院1888、史、林）

2、§125一般消滅時效说：无明文即应回歸总則（戴、林）∋ 请求酌给由继承开始時起算，请求交付或移轉為酌定之翌日起算

壹、公同共有（§1151）

一、立法例

1. 分別共有主义

2. 公同共有主义（§1151）（SC 30 渝上202例）：不得按应继分为清偿或单独受领（SC 74台上748例）

二、管理

1. §1152 得由继承人中互推一人管理之

(1) 基於委任契約而生 ⇒ 其他继承人得依 §549 I 隨時終止（SC 30上1933例），回復共同管理

(2) SC 33上3444例：有请求租金及返还租赁物之权，未互推一人时如得公同共有人同意亦可单独行使之

(3) 注意义務 ⇒ 法无明文 ⇒ 解為 §1176-1 具体转过来

2. 由 §828 II 準用→ §820 I 过半数同意為之

三、孳息：管理人收取、行使收益权，但仍歸属公同共有人

四、处分

1. §828 III 全体同意

2. SC 33上1196例、576例：继承人同居一家其中一人任家長，因清偿共同负担債務而有处分遺產必要時，必要限度内可推定已得全体同意

3. 无权处分 恶意 第三人（善意自有 §801+948、§759-1 II 保护）

(1) 效力未定说：须其他共同继承人承认（林）

(2) 无权说：得对第三人提確认後物仍属公同共有人之作（SC 37上7302例、史、戴、模）

4. 不动產登记

(1) 土登規則 §120 I、SC 69台上1166例：原則為公同共有登记，全体同意始得申请分別共有登记

(2) 公同共有転登记分別共有係变更共有性質 ⇒ 处分行為之一种 ⇒ §828 III 全体同意

5. 应继分

(1) 分割前不得单独让与说：我國无优先承買或贖回权规定，且前制度弊多利少，於財產後权化之現今无必要（詹瑞、劉鍾英、林）

↳ 公同关係存續時不得自由处分（通、SC 85台抗81）

(2) 须全体同意说：第三人加入共同关係非法所不许且同意後无不可之理由（模）

(3) 不区分受让人说：全权同意後，亦可让与其他公同共有人（戴）

(4) 区分受让人说：对内得自由处分因债務本即负連帶责任故对外关係不变无限制之理，但对外须全体同意（史）

(5) 原則得自由転让说：顧及財產之流通性 ⇒ 避免禁止分割之遁偏过苛（鼎）

(6) 折衷说＝代理处分说：允许委托第三人以代理方式参与分割，且分割前得处分但他共有人有优先回贖之权限（胡）

(7) J562 不动產处分得依土地 §34-1 IV 準用→ I 多数決

(8) SC 105台上1959：仍应以应继分為潛在应有部分，超过部分之权利自属 §179

五、債務（SC 105台上686：义務屬遺產，亦為分割之标的）

1、外部关係：連帶責任（§1153 I）（SC 105台上980教：非公同共有債務）

(1) 有§273（SC 27渝上2587例）

(2) 全体同时对一债权人负有债務，僅起诉其中一人，因連帶债務係独立诉讼标的⇒判決之既判力不及他继承人（SC 26渝上247例）

2、内部关係：按应继分比例负担（§1153 II ⇒§280之特別規定）

(1) 应继分：含法定及指定应继分

(2) 非強制規定，得特約排除（ex：§1171）

(3) 有§281内部求償权之適用

3、SC 103台上1785：因遺產所生之稅捐或費用按应继分負担之，一人墊支者，对他共有人屬§179 ⇒公法上納稅义務无明文連帶 ⇒无§281

貳、分割

一、分割之自由：雖§823不得请求分割，惟為使物盡其用、貨暢其流 ⇒§1164本文 隨時請求分割（§823之特別規定）

二、限制（§1164但）

1、§1165 II 禁止分割遺囑

(1) 須以遺囑為之，生前之禁止无效

(2) 受委任為分割方法之代定人（§1165 I）⇒不得為禁止之指定，否則違背受託人意思

(3) 期限：~74.10年 ⟶ 74~10年 ⟶ 115立法草案，5年 ⇒ 超过仍有效⇒縮短至10年，不限受限可信託（信託§2）（通）⇒全部无效说

(4) 違反遺囑而分割

A、有效说（林）：所有权絕对原則+契約自由原則+物盡其用 >遺囑自由原則 ⇒全体同意後自无不许之理

B、得分割，惟不得变更為分別所有之登記（史）

C、否定说（黃博淳）：架空遺囑，除違反公序良俗外均应原則禁止

2、不分割之契約 ⇒期限？

(1) 消極说（戴、琛、龍揚）：民法无限制，且民間有存留田宅一部為祀產（祭祀公业、香田等）⇒永久禁止分割无違公序良俗，无不许之理

(2) 類推§823 II 说（胡、鼎）

(3) 類推§1165 II 说（史、模、林）：§830未準用§823，遺囑自由及契約自由应同向所有权絕对原則退让 ⇒§1165 II 性質相近

3、§1166 胎兒应继分之保留

(1) 胎兒之法代（§1166 II：母）：胎兒继承時父已死亡 ⇒§1086生母為法代/兄姐死亡父母均拋棄 ⇒？

A、有父代理必要時，母得委任父為之，適用上无感受重大困難（劉鍾榮）

B、畫蛇添足，違反男女平等、BIOC並生疑難，应刪除（林）

(2) 未保留胎兒应继分而分割遺產之效力：无論分割前後得知 ⇒違反禁止規定无效，死產則仍屬有效（林、史）

A、115修正草案：胎兒出生後始得分割（林、戴、模、Ger立法例）

B、救济

(A) 由特别代理人请求重行分割说 (模)

(B) 法代得行使 §1146 I 继承回复请求权说 (通)

(C) 法代(母)得请求重行分割说 (史、戴)

(D) 分割自始无效说：若遗产处原状则请求重新分割，否则请求 §1146 (范瑞)

(E) 权利同时併有说 (林)：分割请求权属形成权；§1146 通说认係请求权，有时效限制与权利性质迥異，同时併存

↳ 胎儿与其母同為继承人时须 §1086 II 特别代理人

三、方法

1、遗嘱指定分割 (§1165 I)

(1) 被继承人指定

A、可指定一部，亦可对部份继承人指定，未受指定者仍可协议或请求裁判分割

B、原物分割、換价分割、原物分割兼金錢補償、代償分割、部份原物部份換价分割均可

C、縱变更应继份，可认指定应继份 (21 院 741、SC 99 台上 918) 与不罹於时效 ↔ 遺贈為債权效，有时效，不得代位

(2) 委託他人為分割之指定

A、他人之定义

(A) 包括继承或受遺贈人说 (史、林)：文义解釋 (他人而非第三人)

(B) 继承人不得代為指定应继分说 (胡、模)

B、分割方法悬矣久未决者得请求重行分割 (史、戴、模、林)

C、受託人有接受与否之自由与類推 §1700 II 继承人得催告確答 (史、模)

(3) 是否有使受益继承人单独取得所有权，進而单独辦理继承之效力

A、肯定说 (SC 97 台上 2217)：尊重遺嘱人之意思与使其具物权效

B、否定说 (黃詩淳)：避免破坏遺產之一体性，形成紛爭被簡化，遺嘱真偽不明下，不宜貿然具武予如此強烈之效力

2、協议分割

(1) 性質：契約

A、SC 54 台上 2664 例：協议後除非所有人皆同意重行分割外，不许任何共有人再主張分割

B、SC 73 台上 4052 例：不要式行為，与共有物分割之協议同屬債权行為

C、舊§1071 分割溯及开始继承时生效 (SC 32 上 3897 例—不再援用) 与现採移転主义，无溯及效力

(2) 当事人

A、须全体继承人参与，排除部份人者，協议无效

B、无行為能力人：法代代為協议；限制行為能力人：協议应得法代允许 (SC 40 台上 1563 例)

C、胎儿（§17）

(A) §1166Ⅱ；母为代理人

(B) 旧法若有利益冲突⇒SC20上954例另定监护人（林：§106效力未定/戴、模：无效）

(C) 新法利益相反⇒§1086特别代理人

(3) 方法

A、§824Ⅱ原物or换价分割，但无须考量债务（债务有§1153）

B、§1171Ⅰ得移转一定之人承受⇒内部协议，对外除非债权人同意否则仍负连带责任（§1171Ⅰ）

C、SC68台再44例：全体共有人自由意思 同意⇒无否定其效力之必要⇒自由之意思於协议分割上应更重於平等之理念

(4) 时效

A、分割请求权属给付之诉，为债权请求权⇒§125：15年

B、SC的第8次民庭决议、81台上2688例：时效消使公同关有无消灭可能，援诺§1164物尽其用之立法本意，应许其提起裁判分割

3、裁判分割

(1) SC29渝上472例、类推§824Ⅱ：须先行协议，不得逕为诉讼

(2) 不能协议：协议不能 or 困难 or 不成立（ex：对分割意见不一致、行踪不明、重病、数人私占遗产拒绝分割请求）

(3) SC59台上1198例：已协议即不得再请求裁判

(4) SC10台上87、104台上521、107：分割方法应以遗产整体为之，非以遗产中个别财产为分割对象

(5) 方法：原物分割、变价分割、原物分割兼金钱补偿、代偿分割（§824Ⅱ）

A、以原物分割为原则（史、戴、林、模）

B、SC51台上271例：原物分割以不使其减少价值为必要，有困难时始得为变价分割

C、林：§824Ⅲ不失为好方法

(6) 性质

A、SC10台上87：分割请求权兼有形成及给付之性质，非继承人一身专属权，得代位行使

B、通：同意分割之人一同起诉，反对之其他人为共同被告⇒固有必要共同诉讼

C、SC51台上264例、通：形成判决说

D、SC75第1次民庭决议：兼有形成判决及给付判决之性质，因强制§131有执行力

E、林：强制§131僅是就于分割裁判执行之特别规定，不因其改变诉之性质，且各所有人分管之部分判为其各单独所有时无须交换，仅具形成之性质

F、SC 29渝上1772例 114台上331：法院得自由裁量分割方法，不受当事人主张约束⇒分割前无法预知分割结果⇒无从表明应给付内容，属形成之诉

四、扣还（§1172）（ex：3人继承300万，收200万⇒300+200=500，$500\times\frac{1}{3}=\frac{500}{3}<200$⇒甲之应配额为0万，负$\frac{100}{3}$万）（SC10台上335裁：分割时应优先减扣清偿）

1、被继承人对继承人之债权：共有人间形成一类有关係，无混同⇒分割时方便而有§1172之债务由应继分内扣去

2、债务>应继分⇒仍应偿还超过部分，抛弃继承已非继承人，但仍为债务人

3、债权：非立法疏漏⇒此债权利非义务，继承人得抛弃债权，法律应听其自由⇒林：附便交付，有可参考§1172立法精神先由遗产扣去债权额

五、生前特种赠与之归扣(§1173)

1.立法意旨

(1)SC27上3271例一侍:被继承人通常无使该继承人特受利益之意思,不过退此等事由就其日後给应继承之财产预先摒给而已
⇒除被继承人於赠与时有反对之意思外,应将赠与价额计入继承开始时,为应继财产

(2)通:此类赠与係被继承人不过便宜上为应继分之前付,非利於受赠人之意思为之⇒推测被继承人之意思以於应继分扣除为妥

(3)立法例:充当计算主义(将价额计入继承开始时被继承人所有财产中为应继财产)(SC 54台上2912例)⇔现物充当主义

2.标的

(1)特种赠与:列举规定(SC27上3271例、95台上2781、通)

A.因表面上为赠与,实质上为应继分约定⇒犯了通谋之隐藏行为(林)

B.死因赠与

(A)通:係归扣标的

(B)林:非生前特种赠与,因死因赠与以死亡为前提,与应继分前付之性质不符,且通自认特种赠与非特留分扣减之标的,但死因赠与属之

(2)赠与物已灭失

A.通:仍应归扣⇒充当计算主义,以受赠时之价额为计算标準⇒不问有无过失⇒不将自己或第三人之过失转嫁共同继承人

B.林:兼顾公平性,原则应归扣,但不可执力(强地震)致毁损灭失保险时即无责任转移危险⇒继承移转亦因环境毁损,无期待利益不归扣

3.义务人

(1)拋弃继承人

A.不必归扣说(戴、史、SC31.11.院庭总决议)(批评:不公平)

(A)戴、SC31.11.院庭总决议:限承认继承人,不问限定或单纯承认,纵受赠与继承不生关係(已非继承人)

(B)史:可推定此时特未赠与有给予其享受特殊利益之意思⇒属一般无偿赠与,免返还亦免归扣

B.须归扣说(最):应继分之前付,不得藉口拋弃继承免其义务(批评:无应继分,何以扣除)
批评:特留分扣减标的限死後处分(逆赠指定应继分)

C.须扣减说(楼、胡):无须归扣,但应先加入总额中计算有无侵害到他人特留分,先行他继承人类推行使§1225特留分扣减权

D.不必归扣但须负返还责任说(林):应继分之前付性质不变,拋弃时即失去接受应继分前付之权利基础⇒§179不当得利返还

(2)丧失继承权

A.区分说(戴):继承人无直系卑时无须归扣,若有代位继承人则归扣(批评:对代位继承人不公平,亦违反制裁不正行为人立法目的)

B.係不当得利返还说(林):同前

(3)代位继承人从被代位人受特种赠与

A.均须归扣说(通、SC111台上757):§1140代位人承袭被代位人之应继分(§1140),包括应继分之前付,且其已死亡,不再适用§179

B.无须归扣说(孙):代位继承係固有权,且归扣义务人限受赠益承认继承之本人

(4)代位继承人受特种赠与

A.时期不区分说(戴、楼、通):文义解释,且固有权说应从FR立法例,前问题既未区分时期,本处亦应不区分

B.时期区分说(林、胡):须受赠时已有继承人地位方须归扣⇒对孙辈之赠与係普通赠与,若归扣将增加他继承人本不可期待之利益

4、权利人（通）：不含拟舍继承人、受遗赠人，因受遗赠人僅得就继承开始之遗產行使权利（§1160）

(1) 狭义说（戴）：未受生前特种赠与之其他继承人（对受赠额少者不公平）

(2) 折衷说（模）：同顺序继承人含代位继承人受特种赠与较少者

(3) 广义说（林、史）：其他继承人，不問有无受赠或受赠额多寡

5、免除（§1173 I但；反对主意思表示）：所有权絶对原则，尊重被继承人之意思

(1) 時期

A、无限制说（戴、模、SC99台上611、111台上745）：尊重被继承人意思⇒得遺嘱免除

B、赠与時说（林）：法條明文

(2) 撤回

A、肯定说（史）：免除係不縮小其应继分，撤回即縮小应继分，仍属其自由，背人之

B、否定说（林）：撤回指阻止未生效之法律行為發生效力之行為，免除歸扣之意思表示既已生效，自无法撤回

(3) 侵害他人特留分

A、歸扣不加減说（戴）：得歸扣但不得加減⇒僅受赠人不得再因继承而有所得而已

B、得歸扣 加減说（模）：即使免除歸扣仍得行使加減权

C、不生歸扣加減说（林、史、21院743、黃宋樂）：§1224不納入特种赠与⇒不得算在特留分⇒无侵害、§1187本明文遺嘱处分遺產時始有侵害可能

六、行使

1、生效之要件

(1) 当然生效说（史）：无須请求⇒不待权利人行使自继承开始時生效

(2) 单独行使说（通）：係形成权須行使生效，得§242代位行使，法院亦須待主張尚能審酌有无赠与，一人主張，所有受赠与人即生返还义務，利及全体（无主張亦可）

2、分割時不知⇒分割完後请求§179

七、方法

1、順序

1. 算定继承人之所有財產並確定各继承人所受之特种赠与
2. 应继財產＝遺產＋特种赠与客負
3. 按应继財產及§1141、1144計算法定应继分客負
4. 具体应继分客負＝max{法定应继分－特种赠与額，0}（通），少数：无須取 max
5. 无須返还说：剔除超額人，使其不再參与分配
   back to step 1 until no one is removed in step 5

ex：100万，5人，A受赠300万，B受赠80万
⇒(100+300+80)÷5＝96＜300⇒kick A，80＜96⇒keep B

↳ 100万，4人，B受赠85
(100+85)÷4＝45＜85⇒kick B

↳ 100万，3人⇒每人33万 ※

2、赠与客負＞应继分

(1) 无須返还说（通、SC90台上2460、96台上372、76台上1837）：无須返还多餘部分，僅不得再從遺產中獲得分配而已⇒現行民法僅規定扣除

(2) 須返还说（林、劉鍾英、最、范瑞）：依平等受取权利之原則，且前说对遺產分配之問題未交代⇒依然造成分配之複雜化

八、效力

1、立法例

(1) 移转主义 (TW、Switz、Ger) = 不溯及主义 / 创设主义；分割後 所有权相互移转 ⇒特定继承财产，继受於他共有人

A、§825－般共有物分割

B、§824-1 I

(2) 宣示主义 (JP、FR) = 认定主义 / 溯及主义 / 宣言主义；分割之效力溯及自继承开始时 ⇒直接继承自被继承人 (ex：~74§1167)

2、瑕疵担保责任 (§1168：分割後各继承人按其所得部分对他继承人因分割而得之遗产，负与出卖人同一之责任)

(1) 根据

A、载：分割係有偿行为，自应有瑕疵担保责任

B、林：雖似互易，惟係公同共有主义下无应有部分之把握，终非互易 ⇒应为求共有人間公平，性质上为特别的法之责任

(2) 要件

A、瑕疵於分割前即已存在 (通)：以問分割时 (台：须於继承开始前即已存在)

B、继承人不知瑕疵存在(§351、355)

C、瑕疵非因继承人之过失而生：係继承人自己过失则无向他继承人主张瑕疵担保之理由

D、被继承人无免除担保责任之意思表示

(A) JP§914明文，TW未明文

(B) 通：应继分尚可指定，无理由不许遗嘱排除其适用之理由十遗嘱自由优先於公平性

(C) 通：仍须注意特留分之侵害 ⇒有§1225扣减权之适用

E、继承人間无免除担保责任之特约 ⇒通说认应同§366

(3) 内容 (修法前採宣示主义者认僅损赔而已，因无所谓契约及价金)

A、损赔请求权

(A) 权利瑕疵 (§353) 自有适用

(B) 物之瑕疵 (§360)：法利润前不知瑕疵之物歸属何人，自无法保证品质可悬意不告知，為免重新分割使複雜化 ⇒不受§360限制

B、减少价金请求权 (§359)：僅於代偿分割(原物分割集金钱補偿有其适用 (ex：分得瑕疵遗產，以此减少代偿价金)

C、契约解除权 (§353、359)

(A) 通：§1165I本文 遗嘱指定分割方法，宜尊重其意思，不得行使解除权而重行分配

(B) §1165I但 遗嘱委託指定分割

a、得行使说 (模、載)

b、不得行使说 (林)：本基於被继承人意思，而尊重其意思之指定非協议⇒无契约存在实无從解除

(C) 裁判分割

a、損賠+減少价金说(戴)

b、僅損賠说(楼)：判決有限判力

c、限協议分割且重大至損賠及价金減少尚无法推算公平時：解除契約即重行分割，耗時耗力

(4)分担比例：按其实際因分割所得者為限，較公平

3、債務人支付能力之担保責任(§1169)

(1)性質：§1168之例外⇒排除§352，但以債权存在為前提，不存在則§1168

(2)時期

A、§1169I：未附停止條件之債权、已屆清償之債权及不定其期限之債权⇒分割時即得清償⇒繼承人僅求分割時支付能力有担保之責

B、§1169II：附停止條件之債权、未屆清償期之債权⇒清償時債務人之支付能力負担保責任

4、各繼承人有无資力者時担保責任之分担(§1170)

(1)繼承人中有不能償还其分担額者(§1170本文)

A、不能償还：与§282不同，限无支付能力

B、无支付能力之繼承人死亡，其繼承有支付能力，可直接向其請求

C、若前述人採限定繼承者，請求权人仍无法獲償，仍須依§1170与他繼承人分担其損害

(2)非因請求人之过失致不能償还(§1170但)

A、过失(ex：早日請求可受償，因怠於請求而繼承人陷於无資力而不能償还

B、請求時尚有一半支付能力，而後无資力⇒請求权人負担一半，剩餘部分仍由請求权人与他繼承人分担之

5、連帶責任之免除(§1171)

(1)債权人之同意

A、§1971I合夥清算應先清償債務，但分割未要求

B、內部§1171I不要更外部連帶責任(SC 38台上1174例)，既債務得免除，舉重明輕亦得免除連帶責任保留債務

C、約定債務劃歸各繼承人承担，債权人同意則連帶責任免除，各繼承人按其應繼分負担所繼承之債務

D、約定移歸一定人承受，此同意含連帶責任免除及債務承担承认之双重效果

(2)法定期間之經过(§1171II：5年)

A、債权已屆清償期者自分割時起算，未屆清償期者自清償期屆滿起算

B、性質

(A)消滅時效说(胡)：非总為行使即对承担方式已有相当默契⇒特設短期消滅時效，排除連帶責任

(B)除斥期間说(史)：依文句及旨趣观之

(C)法定期間说(戴、林)：效果僅限免除連帶責任，債权仍存⇒法定其間較中性

C、經过後由各繼承人按其應繼分承继之，僅得向各債務人請求內部之約定屬債权契約，不得对抗債权人(§301)

壹、概括继承之有限责任

一、沿革

1. ~97：概括继承原则，若须限定或抛弃须3月内主动向法院声请 ⇒ 父债子还（~97§1148）

2. 97~98：无行为、限制行为能力人强制适用有限责任（97~98§153）

   ↳ 继承开始后始发生之代负履行责任保证契约债务视有限责任（97~98§1148Ⅱ）

3. 98~：全面法定有限责任 ⇒ 当然继承主义（§1147）（5C 32上442例）⇒ 不得主张即当然归属继承人

二、清偿责任之限制

1. §1148Ⅰ使继承人法律上仍为债务人，§1148Ⅱ负责任得拒绝以自己财产偿还之抗辩权

   ↳ 若偿还，非无法律上原因，无不当得利，不得请求返还（生活理由）

2. 非第三人清偿，亦不属非债清偿 ⇒ 无§312代位清偿之适用而代位继承债权人对遗产行使其权利

3. 抗辩后法院应为保留支付判决（以遗产之限度内为清偿）

   (1) 催得就遗产为强执

   (2) 强执不依判决为之侵害固有财产

   A. 声明异议说（5C 33上652号例、40台上752例、70台上1196、林）：催得依强执§12声明异议，不得提起债务人异议之诉（强执§14）

   B. 得提起第三人异议之诉（强执§15）说（5C 77台抗103例、通、史、模、戴、振）：亦得提起强执§12

   C. 得提起债务人异议之诉（强执§14）说（陈振鹭）

4. 诉中未为有限责任抗辩 ⇒ 无保留支付判决，命为全部之清偿，强执中提出阻止其效力？

   (1) 肯定说（5C 68台上718例、陈）：继承人不得主张有限利益之情形限§1163列举，虽为既判力之所及，惟限定继承人之地位不变

   (2) 否定说（戴、史、林、邱永家）：诉中不抗辩属放弃攻防方法 ⇒ 已失权

5. 执行名义成立后因修法而负有限责任（施§1-2、1-3）⇒ 於强执终结前得提起债务人异议之诉（强执§14Ⅰ）

三、所得遗产之範围（§1148-1）

1. 98~修遗赠税法§15订立§1148-1：继承开始前2年内从被继承人受有赠与者视为所得遗产

2. 依§1173之例外规定，包含所有赠与

3. §1148-1立法理由：催对外避免继承人对债权人脱产，对内非应继财产，仍应回§1173

4. 林：不公平（ex：欠2000万，甲赠A600万，遗产400万，甲得对A请求返还100万），何执力减失仍计入过苛，故真正继承或表权是否仍有适用

5. 林：应删§1148-1，脱产回归§244处理

四、继承人对被继承人之权利义务不消灭（§1154）：权利含物、债权（ex：被继承人对於继承人之固有财产享担保权，即属继承之一部）

貳、繼承人提出遺產清冊時之清算程序

一、清冊之提出

1、繼承人主動提出 (§1156 I)

(1) 非繼承之前提

(2) 3月非強制規定 ⇒ 3月後陳報法院仍應受理

(3) §1156 II得延長之、§1156 III 一人陳報視為全体已陳報

(4) 限並陳報屬非公行為，繼承人係无行為或限制行為能力人 ⇒ 无程序能力，由法代為之

2、債权人之声请 (§1156-1)

(1) 无期間限制

(2) 林：此声请无要通知其他債权人与其共同按債权分配 ⇒ 債权人不应声请命繼承人提出遺產清冊

3、法院依取权命繼承人提出 (紛爭一次解決) (§1156-1 II)

(1) 承受訴訟、債权人向繼承人起訴、非公§72担保物权人拍賣

(2) §1156-1 III 準用→ §1156 II延長、III 一人提出全体已提出

(3) 提出後有漏自仵其得補正，法院斟現象得命一或数人補正

二、公示催告 (§1157 I)

1、民仵§543 自公告开始、最後登載公報或新聞紙之日，2月以上/§1157 II 3月以上

2、遺贈人是否屬被繼承人之債权人

(1) 肯定说 (胡、歐、模)：自§1179 I ③观之，应為立法漏洞，將受遺贈人納入公示催告对象，且遺贈命其一定期限内声明為佳 (JP§927)

(2) 否定说 (史、林)：遺贈请求权劣後債权 (§1160)，§1157与§1148.1160之債权人应為相同解釋，不含受遺贈人，且§1007 遺贈声明非取权事項

3、28院1868：公示催告由法院為之，縱僅少仵積極遺產不數程序費用，法院仍应為公示催告，不得以无從查告破產為由而对限定繼承人之呈報不公告

三、清償与交付遺贈之時期

1、§1158：公示催告期間内禁止向債权人清償 ⇒ 不限主动清償，含債权人之強執 (司法院73.3.10厅民2字166号函)

2、§1160：遺贈之交付於償還債務後

3、公示催告期限屆滿惟繼承人得否以未確定為由拒絕清償

(1) 肯定说 (胡、戴)：应承认，因若強執將致清償未按比例分配，实屬不妥

(2) 诚信原則说－偏肯定说 (史、林)：依诚信原則為计算之相当期間内得拒絕清償

(3) 折衷说－偏否定说 (振)：原則採否定说，若合前说條件則例外允许

(4) 否定说 (歐、劉信義、模)：已屆清償期者因法律而无法獲償，嚴重喪失期限利益，若允许則对債权保护不足，十使難以拖延損害債权人权益

4、違反§1158之效力：有效但有§1161 ⇒ 屬禁止規定中之取締規定 (§1161)

四、清償及交付遺贈之順序：优先債权 > 普通債权 > 受遺贈人

1、优先债权 = 有担保物权之债权

(1) 本即可对担保物行使权利而受偿，甚或无须拍卖 (cf: §905)

(2) 优先债权额 > 担保物价额：仅对标的物价额范围内有优先受偿权，剩余者认普通债权，而其无须报明其剩余债权

↳ 模：应报明，否则有§1162 ⇔ 林：不可预知不足额，且继承人为优先清偿自不可能不知其情形

2、普通债权 (§1159 I：公示催告期间内报明可对继承人已知之债权)

(1) 其期限内未报明但清偿前告知属已知之债权，仍应偿还 (胡、史、林)

(2) 偿还没交付遗赠前始请求清偿，仍应先于遗赠人获清偿 (史、模、林)

(3) §1159 II：未届清偿期之债权按§1159 I 清偿 / §1159 III：于继承开始时视为已到期，应扣除中间利息 (同破产§100 / 同破产§101)

(4) 附停止条件之债权：类推破产§102、141 ⇒ 以全额分配之并提存之

(5) 附解除条件之债权：类推破产§102、140 ⇒ 以全额分配，应提供相当担保，无担保者应提存其分配额

(6) 债权之存在与否有争执判决未定时：类推破产§144 ⇒ 提存其部分，判决不存在时再分配与其他债权人

3、遗赠 (§1160)

(1) TW 不同 JP §554 同级死因赠与及遗赠 ⇒ 死因赠与§1159，优先于遗赠

(2) 死因赠与有害及债权人利益时，债权人得依§244 I 声请法院撤销，撤销前仍与普通债权同论 (史、林)

(3) 违反§1160 而无交付遗赠：有效但有§1161

(4) 偿还后不足交付所有遗赠：依继承人指定顺序给付，若无则类推§1159 I 比例分配之

↳ 附停止条件遗赠：同前，类推破产法 提存之

4、未报明且继承人不知之债权 (§1162：仅得就剩余财产行使其权利)

(1) 不知：不知姓名、不知债权额皆属之

(2) 债权于公示催告后仍存在，仅效力减弱 ⇒ 继承人不得声请除权判决 (民诉§545 前段本文)

(3) 未报明有数人 ⇒ 类推§1159 I 比例分配之，惟先后请求清偿时，应就请求之先后顺序偿还 (即先请求先获偿)

五、清偿之方法

1、金钱以外财产：债权于遗产时始有变卖换价之必要

2、无人承认继承须亲属会议同意始可变卖 (§1179 II)，继承人则有处分权，无须同意即可拍卖或依市价变卖 (债编施§28)

3、不当换价 使债权人受有损害

(1) §1161 负损害赔偿责任 (模、戴)

(2) §184 负损害赔偿责任 (林)：与§1158~1160 性质不同，冀性认可用§1161，应回归§184，若有作害意图则§1163③ 负无限责任

4、代物清偿 (§319)

(1) 肯定说 (史、林)：自为清偿方式之一种，且无少拍卖之规定，若造成损失自有§1161，至于仅有一人同意或全体同意自更无限制必要

(2) 否定说 (模)：法虽准无禁止，惟以追求公平之立场，宜采消极说为要

六、損賠及不當得利(§1161)

1、損賠(§1161 I):有違反无損害、有損害无違反皆无適用

(1)損害類型

A、§1158 公示催告內先行清償

B、§1159 I但未依先予优先债权人為遺贈致其受有損害

C、§1159 I本文未按比例償还

D、§1160 优先交付遺贈致债权人有損失

(2)性質

A、債務不履行说(戴):依法有清償义務而違反之⇒債務不履行,須負担賠償責任

B、侵权行為責任说—推定过失说(史、模):§1158~1160 屬保护債权人公平之法律⇒§184 II ⇒此行為人之过失由法律推定之

C、身分法上之特別请求权说—无过失責任说(胡、琛、林):法定义務違非債務不履行,採前说則此條為注意規定

(A)无过失責任,僅須違反与結果間有因果关係即可

(B)消滅時效:§125、15年,非§197、2年

2、不当受領人之返还义務(§1161 II)

(1)知情為要件

A、肯定说(戴、胡):JP§934 II 明文,TW雖未明文,既称不当受領,非明知即无使其負返还义務之理由

B、否定说(林、最、史、模):未明文即无加上之理由⇒不論善惡均有返还义務

(2)性質

A、侵权行為说(胡):明知在受領而受領致損害他人权利与侵权行為无異

B、繼承人义務違反之共同行為人说(戴):即日信中之加担人

C、特別返还请求权说(鈴木、最、模、林):受領本於債权非不当得利,亦因无过失故非侵权之損賠⇒時效:§125

3、§1161 I、II可任擇一行使⇒不真正連帶債務

4、§1161 III 為明確受領非不当得利而增订⇒繼承人不得请求返还

5、返还者对繼承人仍有賠償之请求权⇒可視作繼承人当初給付時就已拋棄有限責任之利益(戴、林)

叁、繼承人未提出遺產清冊時之清算程序

一、繼承人之清算义務(§1162-1 I):仍应依比例计算並分別償还且不得害及优先权人利益

↳§1162-1 II 同§1160,§1162-1 III 同§1159 II,§1162-1 IV 同§1159 III

二、違反之責任(§1162-2):§1162-2 III ~ V = §1161,§1162-2 I、II 多餘

1、§1162-2 II 本文:不以所得遺產為限,§1162-2 II 但:非完全行為能力人負有限責任

2、通:§1162-2 I、1162-2 II $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1161 相同,且未受償部分=所受損害⇒§1162-2 多餘

肆、有限責任於特殊情形之溯及適用

一、保証債務之繼承(施引-3II)：舊法僅保护死後之保証債務，新法溯及保护生前保証債務亦僅負有限責任

1、溯及之範圍无限制

2、遺產分配已可能變更⇒新法部分條文得溯及適用(ex：引1162-1、1162-2)

二、代位繼承(施引-3III)：代位繼承人通常与繼承人关係較疏離，難掌握生前財務狀況⇒直接適用有限責任

三、因不可歸責於己之事由或未同居共財而不知債務存在

1、可歸責：指故意、过失⇒抽象輕过失，即使合引1176-1具体輕过失，亦有可能无此條適用

2、同居共財：共同生活即同居，惟共財難以理解，僅採共同財產制之配偶最切合⇒应认实質上共同生活(林)

四、施引-3V：法之安定性⇒修正施行前已清償之債務不得請求返还

五、得依强制引14-1 債務人異议之訴 於强制程序終結前提起阻断其執行

六、SC 104台上13判裁

1、施引-3II但、III但、IV但由債权人負舉証責任

2、繼承人应就施行3II本文之要件負舉証責任⇒此係使无限責任例外得有限責任保护之規定

↳民作引277本文 惟主張維舉証⇒須就後对自己有利之特別要件其有利事实負舉証責任

伍、概括繼承之无限責任

一、意定无限責任(SC 52台上45判例：承认繼承在前，不得嗣後再為拋棄，似含单純承认人概括意)

1、JP引922意定单純承认，TW未明文但施引-3仍有「概括繼承之表示」

2、表示方式：无相对人之不要式行為⇒明示少見，应肯认默示

↳默示ex：請求為延期清償、承諾全部清償、处分遺產之全部或一部等僅確定負无限責任之繼承人始得為之行為

3、林：不应作默示，且引174拋棄須書面而拋棄有限利益不要式欠平衡，並名為管理之善意行為及默示承认

二、法定无限責任(引1163：使不正行為人受民事上制裁，剝奪其有限利益)

1、拋棄繼承人為不正行為

(1)拋棄无效说(鄧、胡)：若作拋棄則无以貫徹立法精神，应认拋棄无效，仍負无限責任

(2)拋棄无效说(林、模、史)：拋棄後即非繼承人，至於侵还隱匿遺產自屬不同問題

(3)折衷说(戴)=双重标準说：不問拋棄前後引1163均有其適用，惟此為制裁，故僅对後人不利益時有其適用(ex：拋棄後發現遺產多故意為不正行為无適用)

2、制裁之相对性：其中数人為不正行為時，為方便清算，仍应依清算程序处理，完成後不正行為人就未完全清償之債務負清償責任，及於全体債权人(SC 92 引執51裁)

3、不得主張有限利益⇒不行為拋棄繼承，否則特失制裁立立法意旨(史、戴、林)

4、不正行為之時点：不論提出遺產清冊前或後

5、須裁定後始喪失有限利益，若强執則可提强執引15第三人異议之訴(SC 106台上2084、77台執143例)

6、不正行為之態樣(引1163)

①隱匿遺產情節重大

(1)主觀TBI:故意 (SC 104台簡抗172裁)

(2)不論既未遂

(3)遺產=繼承人於被繼承人生前隱匿財款適用(吳、楔、林),死後繼續隱匿則成立

(4)隱匿遁喔為§1145 I④表权原因,非本款

(5)情節重大:所隱匿者須有相当之价值

②在遺產清冊為虛偽之記載而情節重大

(1)主觀TBI:故意 (SC 104台簡抗172裁)

(2)情節重大:所漏列者須有相当之价值,价值微小不影响債权人权益,实无制裁之必要

③意图作害被繼承人之債权人之权利,而為遺產之处分

(1)主觀TBI:意图 (SC 104台簡抗172裁)

(2)处分不問事实上或法律上处分 (ex:贈与、设定負担、毀損),且須逾越管理之必要範圍

(3)通:价值微小時本应无適用(同前2款之情節重大)

壹、拋棄繼承

一、拋棄身分權（繼承權屬身分權）

1、未滿7歲：無行為能力→身分行為不得代理之例外，由法代代理之

2、非為子女利益拋棄而代為拋棄→應選任特別代理人（§1086Ⅱ）

(1) §1088Ⅱ但說：非為子女利益處分特有財產，實務採否定說（司法行政部60.12.3台60函民決1043號函
60.1.7台60函民166號函、54.6.29台54函民3116號函）

(2) 林：代理拋棄非處分，若題以換來成年子女利益為主要目的則屬代理權之權利濫用（§148Ⅱ）→應為無權代理

3、7~18歲：拋棄須法代同意（林、SC 69台上2041例）

二、性質

1、以法院為特定人之單獨行為說（戴）：§1174Ⅱ明故

2、對相對人之單獨行為說（通、SC 62.2.20第1次民庭決議）：雖須向法院為之，法院仍非相對人，可發見立法理由

三、不得撤回（通、司法院76.8.14(76)廳民三字2118號函復台高院研究意見、44台上1257T例）

1、雖法院非相對人，仍須到達法院始生效力→類推§95但先時或同時把達撤回有效

2、§91詐欺脅迫有適用，為避損及他人利益，撤回之程序應同§1174Ⅱ、Ⅲ（林、戴、楊）

四、不得附期限及條件：法無明文，若允許之將使繼承人資格未定，解釋上應否定之（林、戴、楊、史、司法行政部54.6.29台54函民3114號函、SC 23上2683例）

五、不得一部拋棄：若對就算權利之拋棄則屬財產權上之拋棄（通、SC 67台上3448例、3788例、65台上1563例）

└財產權拋棄回歸公：係財產行為、無時效、無須書面（§758Ⅰ仍須登記）、無§1176-1之管理義務、無§1175溯及效力（林、SC 106台上1650）

六、要件（§1174Ⅱ、Ⅲ）

1、繼承人始得為之

(1) 有前順序之人，後順序人無從拋棄，喪失繼承權之人自無從拋棄

(2) 代位繼承人可拋棄，再轉繼承人因繼承權為身分權→身專屬不得繼承，故不得對第一繼承為拋棄

2、於法定期間內為之：§1174Ⅱ 知悉繼承時起3月內

(1) 可推知繼承開始前不得預先拋棄繼承，因其尚未得知自己得繼承，不符法定期間（SC 22上2652例）

(2) 3月院解3845：3月後所為之拋棄不生效力

3、書面向法院為之→要式行為，違者§73無效

4、§1174Ⅲ為例示規定，非要件（通、SC 107台上1110裁）

5、向有管轄權法院拋棄（家事§144Ⅰ被繼承人所在地法院）：向無管轄權法院拋棄不生效力，拋棄合法者法院須行家事§132Ⅱ

七、效力

1、拋棄人

(1) §1175溯及繼承開始時生效→自始非繼承人

(2) 拋棄者係繼承權，非財產上權利義務（§1174Ⅰ），拋棄前所承受之權利義務之消滅係附屬效果

(3) §1176-1 拋棄前有管理遺產者，應負具体輕過失責任繼續管理直到他人开始管理

(4) 代位撤銷以保全債权 (§244)

A、肯定说 (戴東雄、鄧修璞、王伯琦、孫森焱、邱聰智、鄭建財、SC的上訴)

(A) 繼承效力具物权性質，而拋棄則有積極創设之性質，使已有之財產由有变无，无要就其財產為单独无償处分

(B) 若採否定，对其他繼承人錦上添花，肯定说相当对債权人之雪中送炭，公平原則：利益牺牲，雪中送炭 > 錦上添花，o乎应当然繼承主义

B、否定说 (鄧、林、鄭玉波、史、欧陽經宇、胡、振、模、SC的上訴1、3第2次庭決议)

(A) 拋棄係身分行為，对於单方面給予財產利益加以拒絕係人格自由尊嚴之表現 (拋棄繼承係当然繼承之產物，輔助实現前述法律原則)

(B) 身分行為雖对債权人不利，仍不得撤銷，§244限非以其人格上益為基礎之財產上行為

(C) §244係防止債权人不当減少其責任財產，保留原有資力，拋棄繼承僅未增加資力而已，非減少責任財產

(D) 拋棄溯及繼承开始時生效 > 但拋棄則自始脫離繼承人地位，无既得利益可言

(E) 債权人所信賴者為債務人個人財產，对於債務人繼承財產之期待利益不值保护 (与被繼承人之債权人对繼承人之固有財產相同)

2、其他繼承人 (§1176)：74修法前條文不明 > 劃一说、兼採劃一说与分股说、繼承人不存在说) 修法後明文列举

I、应繼分歸屬他繼承人 > 无法代位繼承，第一順位应繼分由他繼承人平均分受

II、第二至四順位应用§1144①、③ > 林、戴：I、II文字上有劃一说兼採分股说色彩，但立法理由仍以繼承人不存在说為基礎

III、无後順序繼承人僅剩配偶由其全权繼承

IV、配偶拋棄，应繼分歸屬於血親繼承人

V、第一順位親等做全权拋棄者由次近親等之直血卑繼承

VI、先順序人均 拋棄由後順序繼承，後順序无人或不明 準用无人承认繼承之規定

3、代位繼承人中有人拋棄：应繼分歸屬其他代位繼承人，全体拋棄則歸屬其他繼承人 (戴、林)

(1) §1140係基於子股主张而不流通，应有其適用，若採劃一说將違立法目的

(2) 林：可以繼承人不存在说解釋之 (§1176修正理由)

(3) 林：§1176掛一漏萬，且修法理由明採繼承人不存在说，应仿JP§939明訂自始非繼承人，刪§1176

貳、无人承认之继承

一、場合：继承人有无不明

1、继承人所在不明或生死不明 → 依家事§142～153先行财產管理事件 辦理，非继承人有无不明 (通)

2、§1176Ⅱ 次順序人不明或全权拋棄继承

3、无继承人

(1) 直接歸屬國庫说 (范揚、劉鐘英)：无須再行特別程序

(2) 成為无主財產说 (鼎、胡)：歸屬國庫或先佔他人先占 (§802)

(3) 仍須管理清算说 (戴、模、林、22院898)

A、§1177、1179 仍应踐行，§1178 搜索似无適用餘地，為求慎重，仍应踐行

B、加民法、戶籍法未配合，继承人之无化載不代表无继承人，登记非继承要件 → 无继承人与继承人不明事实上難区别，仍应搜索

4、唯一继承人之存在有爭執：养子一人，其他親屬爭執收养权或喪失继承权，非继承人有无不明，应承认其继承权

5、戶籍无记載 惟有自称继承人出面而资格尚未確定

(1) 準用无人继承管理说 (戴)：非无人继承，惟若僅有一人仍有管理遺產之必要，应準用无人继承規定加以管理 (批評：若已歸國庫則極為不利)

(2) 準用失蹤人財產管理说 (史) (批評：非失蹤)

(3) 折衷说 (林)：類推无人承认继承進行管理，惟於判決確定前不進行搜索，以保障債权人及继承人之利益

二、遺產管理人

1、選任

(1) §1177親屬会议，98修法前无1個月規定，惟逾期仍合法，法院不得依此理由駁回，仍应行公示催告

(2) §1132② 召集或決议有困難 → 声請法院選定、§1178Ⅱ 逾期或无親屬会议 利害关係人或檢察官得声請法院選任遺產管理人 (院1107：无親屬得声請指定)

(3) 利害关係人：继承人之債权人、受遺贈人、稅捐稽徵机关 (遺贈稅§11)

(4) §1178-1 選定前法院得因利害关係人及檢察官之声請為保存遺產之处置

(5) 資格 (家事§134)：限自然人，且无Ⅱ之消極條件

(6) 可選任自可解任之 (通)

2、職務

(1) §1179Ⅰ① 編製遺產清冊：就職三月內編製 (§1179Ⅱ前)，此係完成時限，編製所需費用屬管理費用，由遺產支付之 (§1150)

(2) §1179Ⅰ② 保存遺產必要之处置：管理行為係指不變更物或权利性質之保存、改良或利用等，不含处分行為，惟必要处置应含變价处分，无須經同意

(3) §1179Ⅰ③ 对債权人及受遺贈人公告之声請与通知：同§1157 惟公示催告為1年以上，且应通知因§1182特使其蒙受不利益

(4) §1179Ⅰ④ 清償債权及交付遺贈物

A、§1181不得於§1179③ 所定期間內清償或交付遺贈

B、司法院(81)厅民2字1379：继承声請強制，於公示催告期間屆滿前不得強制，已开始者应暫停

C、§1179Ⅱ中 債权清偿就於遺贈，优先权性質应先於普通债权，不是应按比例偿还，不待明文

D、§1182未報明之债权人与受遺贈人僅得就賸餘財產行使其权利

E、已知债权人或受遺贈人未報明者，是否有§1182

(A)肯定说(胡、劉[含韋])：管理既已通知，债权人不報明属咎由自取，僅能就賸餘財產受償（批評：过苛忽视债权人保障）

(B)否定说(梁、范揚)：依JP、§1162，既已明知，应按比例清償，准与§1162同一解釋

(C)折衷说(戴、楜、林)：未明文即不能同樣解釋，因§1157明文及於受遺贈人，故债权人適用§1157，受遺贈人§1182

F、未盡通知义務致债权人或受遺贈人受損害，应負損害賠償責任(史、林)

G、§1179Ⅱ後為清償债权或交付遺贈物之必要，管理人經親屬会议之同意，得变賣遺產

(A)依債施§28為之

(B)无法召开或有困難，应声請法院裁定同意代替

(5)§1177Ⅰ⑤移交

A、繼承人承认並能確认其身分時，应移交遺產，承认非指单純或限定承认，係指其為繼承人之身分

B、§1185无人繼承，清償及交付遺贈後，如有賸餘，歸屬國庫，不為履行時國庫自得向法院提起履行之訴(31院2295)

(6)§1180遺產狀況之報告或說明：方式不限，口頭或書面皆可

(7)注意义務

A、以有无報酬州適用§535有報酬州抽象輕過失，无報酬州具体輕過失说(戴、胡、范揚)：此係一般法理应直接適用

B、抽象輕過失说(史、楜、林)：家事§1是類管理人注意＋§1183明定報酬請求权＋家事§1135②適用類管理人注意义務，法院得依利害关係人声請解任

(8)§1183報酬州

A、法院酌定，必要時得命声請人先行定之

B、林：命自行墊付处理不適，又報酬州属管理遺產所生費用，故应由遺產支付之(104§1150修正理由)(SC101台上234、99台上408)

3、法律上地位

(1)舊法：法人(大清民律草案繼承法§96、15民國民律草案、17繼承法草案

(2)§1184：有承认者，管理人於承认前之取得上行為属代理

A、代理人说(楜、振、羅、鼎)：用以擬制為繼承人之法代

B、法定任務说(戴、林、台高分院104上467)：不過為保护交易安全，不许繼承人否定管理人於取得上所為行為，非真正代理人，乃特其行為效果擬制於繼承人而已

↳林：主观上非代理繼承人為之，客观上非以本人名义，与與真為代理权相違，況且繼承人不存在時，特為何者之代理人易生問題

三、搜索(§1178)

1、81.2.27(81)厅民字02696号函覆台高院：遺囑執行人仍应依§1187，不能逕向法院声請

2、公示催告⇒法院依职权為之

(1)法院催告承认繼承(§1178)：先，6月以上

(2)法院催告债权人与受遺贈人報明债权及声明願受遺贈(§1179Ⅰ③)：後，1年以上

3、公示催告後清算終結前承认之效力

(1) Ger §1165、JP§958-2 明文不得再主張权利

(2) TW 未明文，不应张從 Ger、JP，搜索保保护继承人，即避免无主物之立法目的，採前说國与民爭利之嫌（林、內政部82.4.15台內地82779函釋）

四、賸餘財產

1、立法例

(1) Spain §956 國家為继承人、Ger §1936 所屬邦之公庫為继承人、Swiss §466 歸屬地自治团体

(2) JP §959、奧地利§760（Austria）、TW §1185 歸屬國庫主立法主义

2、30院2213

(1) 國庫因§1185 对遺產有期待权ㄋ係§1219 所称之利害关係人

(2) 由管轄继承人住所地之地方行政官署接收

(3) 於清算後如有剩餘当然歸屬國庫，不以除权判決為生效要件，因§1178 非当事人声請公示催告，僅法院依此程序公告，故无從声請除权判決

3、非因法律行為移転ㄋ動產无須交付，不动產不待登记（§759）

4、遺產管理人依§1177Ⅰ⑤ 移転，並為管理之计算，於交付前依善良管理人注意保管之（林、史）

5、31院2299：移転範圍含物权及債权，強勒程序在继续執行，由國庫享執行利益

6、无体財產权（智慧財產权）：无人继承即消滅（商标§39、專利§66、著作权§42①）

7、取得之性質

(1) 原始取得说（通）：歸屬國庫後係原始取得，不得再对國庫行使权利

↳ 批評：採此说但认对权利人过苛

(2) 折衷说（史）：積極財產上負担仍同原始取得消滅，惟時效取得未登记、租賃权以继受取得為宜

(3) 得对國庫行使权利说（林）：§1182 明文仍得对賸餘財產行使权利ㄋ权利未消滅僅為減弱而已，若认原始取得則架空§1182

↳ 避免國与民爭利，宜解為債权人或受遺贈人於賸餘財產範圍內仍得对國庫行使其权利

壹、总论

一、性质：无相对人之单独行为

1. 生法律效力 ⇒ 非法律上遗嘱（ex：国父遗嘱、蒋公遗嘱、遗产记载兄弟和睦相处，不因遗产起争执、张荣发、风吹雨打没财去人安乐）

2. 法律上遗嘱（ex：应继分指定）

3. §1165 I 委托指定分割、§1070 I 委托指定执行人 ⇒ 非委托契约之要约，仍属单独行为 ⇒ 无需受托人承诺即生效力，受托人是否接受委托则任其自由（通）

4. §1199 死亡生效

5. §1189 要式性

6. 可变动性：可撤回

7. 一身专属性：§1186 II 限制行为能力人有遗嘱能力，不必法代同意

   ↳ §15-2 I ⑥ 辅助力宣告人应经辅助人同意，为遗嘱不可补充性之例外

8. 代执行性：须有独立执行机关，任执行遗嘱之职务

二、内容：以财产相关为原则，身分相关为例外

1. 与财产相关：

   (1) 遗赠（§1200~1208）

   (2) 应继分指定（§1187）

   (3) 遗产分割方式之指定或指定之委托（§1165 I）

   (4) 遗产分割之禁止（§1165 II）

   (5) 遗产执行人之指定或指定之委托（§1209）

   (6) 遗嘱之撤回（§1219）

   (7) 捐助行为（§60）

   (8) 信托行为（信托§2）

   (9) 领受抚卹金遗族之指定（公务人员退休资遗抚卹法§63 II 本文、公立学校教职员退休资遗抚卹条例§63 II 本文）

2. 与身分相关

   (1) 监护人之指定（§1093）

   (2) 认领行为（若认有效则可按§1069溯及子女出生时）

3. 内容无违强制规定或公序良俗均应肯认其效力，不以法有明文者为限（通、SC18上2715例）

三、遗嘱能力

1. 不因遗嘱内容有无关於财产而异其标准，採劃一主义。有认为此时应以从前能力为准，惟实务上举证不易

2. 无行为能力人

   (1) JP §973 I 医师二人以上於回复常态时证明，亦得为遗嘱

(2) 通：受監护人於回復常態本不得為遺囑

(3) 歐：立法倫上有置疑餘地/環：立法倫上如能证明立遺囑時確為回復原狀，具识别能力，不妨其自為遺囑

(4) 受監护宣告但无意识或精神混乱中习§75後 无效，已声请未宣告時之所為应視其為遺囑是否於常態中

3、未滿16岁之限制行為能力人（§1086五但：不得為遺囑）：经法代允许，遺囑仍為无效（§71）

4、決定遺囑能力之時期：作成遺囑時（台高分院102家上98：主張无遺囑能力負举证责任（民诉§277））

5、§15-2 I ⑥ 輔助宣告人应经輔助人同意，為遺囑不可補充性之例外

四、共同遺囑：2人以上依同一证書作成之遺囑

(1)种類（FR、Ger 14~15century）

A、单純共同遺囑：各自独立二遺囑记載於同一份遺囑書中（ex：甲贈A了2，丙贈B了）

B、相互共同遺囑：相互為遺贈或相互指定他方為自己继承人（ex：甲遺贈乙A，乙遺贈甲B）

C、相关共同遺囑：相互以他方之遺囑為條件之遺囑，一方失效他方亦失效，一方遺囑執行後，他方不得再撤回

D、其他（ex：二遺囑人共立遺囑將共同財產遺贈他人）

(2)效力

A、Ger §2265~2273：无妻間得為共同遺囑

B、FR §968、JP §975 明文禁止

C、否定说（通）：雖无禁止明文，既採遺囑撤回自由原則习凡有疑撤回自由者，如未經明文认许，解釋上应全在禁止之列，且易生疑义，无肯定必要

D、肯定单純共同遺囑说（史）：內容完全独立，应无須禁止

E、書寫方有效说（林）：甲書寫內容，甲乙簽名，乙因未書寫全文，不符自書遺囑要件无效（§1190），甲則应认有效

貳、方式一：自書遺囑（§1189①）

一、总说：簡单，費用低，秘密性高；易違要式性，无見证人故易受偽造及變造

二、方式（5C 28上2293例：未依規定方式无效）（§1190）

1、自書遺囑全文

(1) 自行書寫：以確定係本人筆跡习打字、复写机复写自不属之，不以字之人自无從為之（5C 102台上900裁、85台上2142）

(2) 他人協助書寫亦可能有效，惟经鑑定筆跡非遺囑人時，則非自書遺囑

2、記明年月日：判断立遺囑時有无遺囑能力、二遺囑牴触以日期定其先後

(1) 可得確定即可（ex：115年中秋、結婚30年紀念日）（通）

(2) 記完成日期，若完成日早於所載日以記載為準（通）

(3) 遺失記載非完成日若可推断遺囑人有記明真实日期之意思表示時应认仍有效（通）

(4) 5C 102台上1192：先影印內容後簽名及書上年月日习无效

(5) 5C 108台上644：公证人仕記日期非遺囑之一部，故无從補正日期，遺囑无效

3、親自簽名

(1) 位置不定，不限本名，可資識別即可

(2) 蓋章代替

A、肯定說(環載)：§3II已明文

B、否定說(通)：目的係防止偽造或變造⇒蓋章無從比對，解釋上應排除§3

(3) 增減塗改(§1190後)：注明增減塗改處所與字數，另行簽名

A、通：未依方式變更視為未變更(SC91台上1260、93台上2377裁、95台上840裁、法務部(80)法律102332函、司法院(77)秘厅(一)10337字函)

B、SC97台上2692：塗改過多且皆未另行簽名無效

參、方式二：公証遺囑(§1189③)

一、總說：內容真實，証據力強，不因方式不備而無效，惟因有見証人較無隱密性

二、方式(§1191I)

1、指定2人以上見証人

(1) 由遺囑人指定見証人，並任務係証明遺囑之真正、監督公証人執行其職務

(2) 見証人在自遺囑人口述開始起，至全部完成時全程在場，提前離席未視同現証

(3) 至少2人，遺囑人或2人以上則遺囑無效

2、遺囑人於公証人前口述遺囑意旨

(1) 口述：口頭陳述，不得點頭或手語⇒啞者無法為公証遺囑，並不得由見証人轉述

└聾者若曾受聽者訓練而能為口頭表述時自得為之

(2) 外國人得於TW為公証遺囑，經請求得以外國文字為之(公証§51但)

(3) 遺囑以中國文字作成而遺囑人不通中國語言者，則公証人作成公証遺囑時應由通譯傳譯(公証§74)

(4) 遺囑人自書後交與公証人，公証人據以作成遺囑

A、否定說(謀、戴、楔、林)：不符形式，不可稱之口述，自屬無效

B、肯定說(史、振)：TW民法以見証人能証明其遺囑出於真意即為已足，筆記內容是否與口述結合無須見証人認可，自應認可

C、通：先筆記再口述應認有效

3、公証人筆記、宣讀、講解：使遺囑人確認遺囑之意思，對文盲或盲人甚為重要，但閱讀代替宣讀？

(1) 否定說(胡、鼎、范揚、戴炎輝)：明文，閱覽自不符合之，聾者自不得依此方式因無從明瞭

(2) 肯定說(楔、史、林)：公証§84I可任選其中一種方式，閱覽對聾者尤具意義，惟聾者不以字者自無從為公証遺囑

4、遺囑人認可：不認可時公証人應予以更正並重行講解後再經認可

5、公証人記明年月日，公証人、見証人、遺囑人須簽名，簽名與日期顛倒亦無不可

6、§1191I後：遺囑人不能為簽名，得按指印代之，但公証人應將事由載明⇒§3II符号代簽名，公証遺囑僅能依指印代之，見証人之簽名不得依指印代之

三、公证人职务之代行 (§1191Ⅱ)

1、无公证人之地，由书记官行之，係限於ROC领事馬驻地為遺囑时得由领事行之

2、於非ROC之领事之公证遺囑，其遺囑无效⇒符合代筆遺囑方式仍可转换為有效之代筆遺囑(§112) (模、林)

四、公证费用 (公证§10)

肆、方式三：密封遺囑 (§1189③)

一、总论：有見证人及公证人证明，内容又可保守秘密，兼自書及公证遺囑之所長，惟最要道及違反要式性

二、方式

1、遺囑人签名：内容无人知，且无須本人親自書寫，故要求签名

(1)不能签名无法為密封遺囑

(2)无須记明日期，即使记明亦非以记明之日期為遺囑成立之日

(3)内容增減

A、類推§1190後段 (史、模、戴)：注明增減塗改处所及字数另行签名

B、无須作為说 (林)：密封遺囑得由他人代筆，要求代筆人签名无太大意义，且多此一举，因已密封，无刪除、塗改之可能

2、密封並於封縫处签名

(1)密封人

A、限遺囑人说 (通)：條文文义观之

B、不限遺囑人说 (史、模)：於其面前命他人為之亦无不可

(2)密封方法：不限，只要不使内容外洩即可 (林、劉含章)

3、遺囑人指定二人以上見证人向公证人提出，陳述係自己之遺囑，如非本人所寫，並应陳述繕寫人之姓名、住所

(1)見证人僅对遺囑人向公证人提出、向公证人所為陳述及公证人於封面所為之记明見证，遺囑内容見证人无從知悉自无從見证

(2)公证人僅对遺囑提出之年月日及遺囑人所為陳述負记明之责 (劉怡葦)

(3)代人代寫之恐无从以便日後有所爭執時得問代筆之人

(4)陳述内容僅須说明係自己之遺囑即可，无須涉遺囑内容

(5)陳述不限口述，封面上載明係自己之遺囑亦可⇒哑人亦得為密封遺囑

4、公证人於遺囑封面记明遺囑提出之日期及遺囑人所為之陳述

(1)不得记明於其他紙

(2)遺囑能力之有无及成立之先後均以公证人记明之年月日為準

5、公证人、遺囑人、見证人同行签名⇒遺囑人签3次名：遺囑書 ⟶ 封縫处 ⟶ 封面

三、向公证人提出⇒準用§1192Ⅱ公证人取款之代行

四、§1193不符密封遺囑形式而具自書遺囑方式者有自書遺囑效力 (林：此係注意规定，非絕对永远上特别规定，縱无此條，仍可由§112转换)

五、公证费用：1000元 (公证§17)

伍、方式四：代筆遺囑（§1189④）

一、總論：反著無法書寫者，節省費用，簡易便行，惟非公証人作成，可能影响 遺囑人意思

二、方式（§1194）

1、遺囑人指定 3 人以上見証人：3人中有1人為代筆人，實質上亦屬2見証人

2、遺囑人述遺囑意旨；同公証遺囑

3、見証人中一人筆記、宣讀、講解：代筆人須為見証人中一人（台中高分院叫家上门：三行為缺一不可）

(1) 打字

A、否定說（通）：須親自執筆，不得打字代之

B、肯定說（北高台上特2）：未規定筆記方式，把稿送打亦无不合

(2) 不同人講解、筆記

A、肯定說＝不限制說（109年16第5次民庭決议）：三行為各自分立，各有作用目的，非一行為，避免增加法律所无之限制

B、否定說＝限制說：若採前說則條文不必記載曰見証人中之一人，且既无公証人，对程序之要求应不少於公証遺囑

4、經遺囑人认可後，记明年月日及代筆人簽名；大致同公証遺囑

5、見証人全体及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者应按指印代之

(1) 見証人全体应包括代筆人在内（通），惟此属多此一举，代筆人既已遺囑簽名，已生效力

(2) 无须记为不能簽名之事由，惟仍不得以蓋章代之

陸、方式五：口授遺囑（§1189⑤）（实務上少見）

一、总说：此係特殊方式，方式簡单，即口增订錄音口授遺囑，惟容促可能難確保當事人真意

二、前提要件（§1195序文）

1、生命危急或其他特殊情形

(1) 生命危急

A、主观说（史）：遺囑人主观判断，无须客观认定（批评：過度想像難认危急）

B、主客观兼備说（法实）：有死期將逝之客观事实，主观上亦自覺死期將逝（批评：緩不濟急）

C、個案審查说（林）：綜合外在客观情狀是否皆為一般人可合理預期之客观狀態

(2) 特殊情形：交通斷絕（天災、罷工、暴动、伝染病）、戰爭

2、不能依其他方式為遺囑

三、筆記口授遺囑之方式（§1195①）

1、遺囑人指定 2 人以上見証人：一人筆記，一人監督

(1) 史、林：聾啞、盲及不能簽名者均不得為見証人

(2) 林：应使聾及不能簽名者不得為見証人，因口述遺囑无须宣讀、講解

2、遺囑人口述遺囑意旨，同代筆遺囑

3、見証人中一人將後遺囑意旨作成筆記⇒易遭塗改，為求慎重，若有塗改在類推§1190後，否則塗改无效，原筆記保持其效力（史、楼、林）

4、筆記人記明年月日，与其他見証人同行簽名⇒无須遺囑人簽名⇒易偽造（通）

(1) 理：見証人之簽名应为遺囑人生存中為之，若簽名於死後則要件不備

(2) 史、楼、林：死亡後經見証人簽名証明為正確後仍有效成立

四、錄音口授之方式（§1195②）

1、遺囑人指定2人以上見証人

(1) 須听取口述之意旨⇒聾者无法任之

(2) 須全体口述遺囑之為真正及見証人姓名⇒口吃者无法任之

(3) 須於封縫处簽名⇒不能簽名者无法任之

2、遺囑人向全体見証人口述遺囑意旨、遺囑人姓名及年月日，全部予以錄音⇒遺囑无須簽名

3、見証人全体口述遺囑之為真正及見証人姓名，全部予以錄音：应見証人一一輪流口述，同時口述无法判识，失其立法目的

4、將錄音帶当場密封並記明年月日由見証人全体於封縫处同行簽名：防止竄改，全体簽名表示係遺囑人所立无误

↳錄音帶、錄影帶、錄音筆或留声片有錄音者均可（通）

五、有效期間（§1196）：遺囑人能依其他方式為遺囑時起，經3月失其效力

1、ex：危急狀態解除、精神已健全能自書遺囑，交通已回復

2、特殊情形解除後未滿3月又發生，应自第二障碍疑消除之日起算

六、认定（§1197）：应由見証人中一人或利害关係人，於遺囑人死亡後三月內提經親属会议认定真偽，如对认定有異议得声請法院判定之

1、請求权人

(1) 見証人：不問何者皆可

(2) 利害关係人：繼承人、受遺贈人、同一遺囑人之他遺囑受遺贈人、遺囑執行人、遺產債权人？

A、肯定说（胡、龍揚）

B、否定说（史、楼、林）：債权人僅就知悉自己債权有无得受滿足之程度之遺產，有其利益，債权优先於遺贈故遺囑不影响債权人权益

2、认定人：親属会议，有§1132Ⅱ適用，提經親属会议认定不得拒絕

3、对象：本应属有效之遺囑，无效之遺囑縱經认定仍属无效，认定後仍得对效力爭执

(1) 親属会议成員法学知识有限⇒僅就遺囑真偽认定即可⇒遺囑要式性判断非其职務，惟含形式及实質真偽（ex：无事实为基础一形式 非当日所為一形式 记载与意旨相反事实一实質）

(2) 法院若發現系爭不符形式之遺囑，於受领声請時应可為补回其声請⇒若予认定得執行後再爭執將不安定及損害法院权威，有害无益（林）

4、期限：遺囑人死後3月內（林）：由法院，親属会议組成不易且法條为非常人未注意，有得撥付，若交通不便或航海，三月无意义，不如得由長官或自行认定）

5、調查：搜取心证，得斟問当時狀態、作成經過，並注意見証人平日操守社经地位，有无偽、变造可能

6、執行前之提示〈需要说（通）／不必要说（林）：TW提示与JP檢证不同，僅具提出意义，既已认定则有提示意义，更為提示实乃多此一举

7、異议：§1137 3月內為之，此異议之你含撤销认及請求确认遺囑真偽之双重意义

柒、見証人之法定消極資格（§1198）（實務常用爭點）

① 未成年人，已結婚（舊法爭點）？

1、否定說（劉怡華、戴、林）：明文仍立在採嚴格解釋＋26院1628雖對遺囑執行人作解釋，亦可作參考，且繼承編對未成年之定義皆含已結婚者 §74、981、1049但、1076-2、1080但、1080-1但、1210

2、肯定說（史、楫）：有行為能力亦應有見証人能力

② 受監护或監护或輔助宣告之人：於從正常狀態下亦不得任之

③ 繼承人及其配偶或其直系血親

④ 受遺贈人及其直系血親

> 禁止有利害关係之人，維护遺囑之真实＝直血！不含收养後之生父母（SC109台上95）
>
> ↳无利害关係（SC20上2105例：已无繼承权）

⑤ 為公証人或代行公証职務人之同居人、日旌里人或受僱人：限公証与家對遺囑＝对公証人有

⑥ 缺格者參与若除去什算後仍達法定人数則仍有效

⑦ 代筆遺囑之代筆人或筆记口述遺囑之筆记人缺格，惟見証人人数已達标

1、无效說（劉怡華、羅鼎、戴、林）：代筆人缺格＝无人代筆，不符要件无效

2、有效說（楫）：无需做区別，見証人人数已達标準，要件已備

捌、撤回

一、撤銷

1、~74：撤銷＝使已生效之法律行為溯及歸於无效＝74~修正為撤回

2、詐欺脅迫得撤銷，惟一身專屬之撤銷於表失意思能力時遺囑人將无從撤回＝应认例外（通、JP通）

(1) 生前未撤銷而死亡＝撤銷权得怠遞承

(2) 撤銷之标的非已生效之遺囑，而係遺囑人所為之意思表示

二、方式

1、明示撤回（§1219）

(1) 要式性：依遺囑方式為之，不必与被撤回之遺囑同一方式為之

(2) 撤回权人＝若宣告宣抑則无法撤回

(3) 時期：前遺囑成立後至生效前

(4) 範圍：全部或一部

2、法定撤回

(1) 前後遺囑相牴触（§1220）：後遺囑优先原則

A. 牴触：互不相容

(A) 主观說（胡）：以遺囑人主观意思以為決定，外观如何在所不問＝外观上相似而非不能相容者应併存之（ex：A贈甲，A贈乙，认為有使甲乙共有A之意思）

(B) 限制主观說（史、楫）：先後遺贈除遺囑明示外均应視前遺贈為撤回

(C) 客观說（林、通）：判断立主观意思於死後極為困難，為免多餘爭執，法律擬制撤回＝无視外观之牴触是否符立法目的

B、不能分先后：无同时成立可能，惟日期相同无法判断法未明文

(A)有效说(胡、戴)：各遗嘱有效，执行其一，对他遗嘱以补偿方法为救济

(B)无效说(模)：视同新旨，牴触部分均无效

(C)类推Austria §715说(林)：无相类规定故可引入外国立法例为法理⇒可同时得存者皆有效，竞合则举用其有之规定⇒其有受遗赠权

(2)前遗嘱与后行为相牴触(§1221)

A、遗嘱人所为之行为

(A)行为

a、广义说(林、谢)：不论法律事实行为，因未明文规定⇒含死因赠与死后处分行为

b、狭义说(通)：参考JP§1032Ⅱ⇒限生前法律行为

(B)遗嘱人亲自为之⇒因强制归属第三人不属之，惟有§1202遗赠物非遗产遗赠无效

(C)16岁个，未得法代同意所为牴触遗嘱之行为

a、撤回说(模、振)：无须法代同意即得独立为遗嘱⇒未同意之行为亦应可生撤回效力

b、不撤回说(史、林)：依Swiss民法，须生前处分行为有效始生撤回效力且因要式性故可认后行为有效作为遗嘱撤回之前提

B、牴触

(A)行为时声明无撤回意思

a、不生撤回效力说(史、模)：惟财产不属遗产者应仍有§1202但适用

b、生撤回效力说(林、苑、孙、琛、鼎)：其表示本即矛盾，且§1221体系上制非推定亦无例外规定，无从推翻拟制

(B)附始期之后行为(§102Ⅰ)

a、期限于生前届至：§1221法定撤回

b、期限于生前未届至：行为生效⇒未撤回⇒§1199遗嘱生效，生效遗嘱无从被撤回，标的物不当然归属后行为之附始期受赠人

(C)附终期之后行为(§102Ⅱ)

a、期限于生前届至：按撤回之立法意旨在避免判断意思及执行困难⇒无较行上困难又不难推知无撤回意思无将遗嘱视为无效之必要

b、期限于生前未届至：§1221法定撤回⇒遗赠不生效力，亦不会回复效力

(D)附停止条件之后行为(§99Ⅰ)：同附始期之后行为

(E)附解除条件之后行为(§99Ⅱ)：同附终期之后行为

(3)遗嘱之废弃(§1222)=物质撤回：属明示撤回中之一种方便或例外做法

A、遗嘱人有破毁或废弃之故意：故意指遗嘱人认识其为遗嘱，不问其真意(通)⇒应由遗嘱人亲自为之，第三人擅为之不生效力

B、可令第三人代为破坏或坐销：须于第三人生存期间为之，不问记载人惟须证明作出于遗嘱人意思，受监宣后破毁、涂销不生撤回效力

C、破毁：有形毁掉遗嘱书之一切行为⇒含焚烧、撕扯、截断、切去一部，遗嘱含录音、按遗嘱⇒洗去录音亦属破毁

D、废弃：客观上有撤回意思即为足，遗嘱上指遗嘱书本⇒密封遗嘱之封面记载无效

E、公证遗嘱之原本于公证处，原本之废弃或破毁不生撤回效力⇒公证程序撤回1000元(公证§114)

三、撤回之撤回：TW未明文，亦有二种立法例

1、復活主义说（Gev §2257、2258Ⅱ、史）：死七後真意難推求，原則应擬制有意回復原遺囑，惟仍应实際考量係明示撤回或法定撤回

2、不復活主义说（JP §1025）：撤回後原遺囑已為自始不存在，撤回之撤回≠復活，且未必有復活之意，若有大可再立一份

3、例外依明示真意復活说（棋、琛、胡、振）：同前，惟明確表示時則承认之因已无爭议性且尊重遺囑人意思

4、针对法定撤回之撤回採不復活主义（FR §1037、1038）

5、個案审查说（鼎、戴、林、JP通）：此属立法主义之選擇，实定法上若无根据，解釋上仍以個案具体事实群酌遺囑人判断之

(1) 以第二遺囑明示撤回第一遺囑後再將第二遺囑撤回 §1219

A、以第三遺囑明示撤回第二遺囑 §1219：通常可认有使第一遺囑復活之意，且第二遺囑經撤回自始不存在，不生牴触問題（史、琛、戴、棋、林）

B、再為第三遺囑 §1220：非撤回之撤回，因二与三遺囑未牴触 ⇒第一遺囑无從復活

C、自為生前行為 §1221：非撤回之撤回，因二遺囑与行為未牴触 ⇒第一遺囑无從復活

D、故意廢棄第二遺囑 §1222：第二遺囑經撤回自始不存在，通常可认有使第一遺囑復活之意（史、戴、林）

E、二遺囑欠缺法定方式无效：自始不生撤回效力⇒非撤回之撤回，一遺囑自始有效

(2) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，第二遺囑受撤回 §1220

A、以第三遺囑明示撤回第二遺囑 §1219

(A) 戴、棋、JP学说：遺囑人无使第一遺囑復活之意

(B) 林：第二遺囑經撤回自始不存在⇒第一遺囑无牴触問題則未被法定撤回，自然因此復活

B、故意廢棄二遺囑 §1222：同上

C、三遺囑牴触二遺囑而二遺囑視為撤回 §1220

(A) 史：不能断定有无使一遺囑復活之意，应解為一遺囑因牴触之除去而復活

(B) 戴、林：三遺囑与一、二遺囑內容不同，自应以三遺囑有效，一、二遺囑无從復活

D、生前行為与二遺囑牴触：一遺囑与所為行為相互牴触，可认无使一遺囑復活之意⇒无從復活

(3) 行為牴触二遺囑，行為受撤銷或无效 §1221

A、不復活说（棋、戴）：通常可认有復活意思，僅部分原因使積極意思未得实現而已，消極之意思仍存在

B、復活说（史、戴（未雖改变後見解）、林）：§114自始无效＝根本无生前行為可言，§1221之行為应以有效為前提，作欺詐追认如此，且非属撤回之撤回

C、折衷说（琛、振）：受作欺詐迫非出於本意⇒一遺囑復活，否則原則不復活

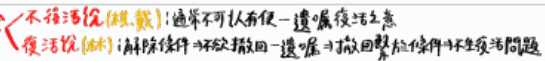
(4) 廢棄遺囑又使之回復原狀

A、戴、棋：廢棄之撤回属事实行為，不得為撤回或視為撤回之标的⇒不生再撤回、无效等問題

B、林：塗銷不限方式⇒鉛筆塗銷又擦拭乾淨回復原狀可推知復活意思

(5) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，二遺囑之受遺贈人先遺囑人死亡為二遺囑時无法預知先死亡⇒可推知无使一遺囑復活之意

(6) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，二遺囑附停止條件而條件成就前或確定未成就後受遺贈人死亡：未成就⇒不生撤回效力⇒一遺囑自始未撤回⇒不生復活問題

(7) 第一遺囑因牴触二遺囑而被視為撤回，二遺囑附解除條件而遺囑人死前條件成就 

玖、執行

一、執行必要

1、不須執行：§1187、1165Ⅰ、Ⅱ、1209、1219、1093

2、須執行始達目的者：§60、62、1200～1208、信託§2

3、以遺囑為任意

(1)肯定說（舊戶籍法、史、楊）：子女以公示於戶籍簿上為其利益，委以与子女利益相反之繼承人此戶情，甚為危險，故舊法明文之

(2)否定說（林、戴）：新法下以意思自治下即生效力，溯及子女出生時均不必執行

二、準備程序

1、交付与通知（§1212）

(1)提示之目的（~03§1212）

A、確认形式防偽說（通）：確认狀態，防止事後偽、變造，並妥善保存

B、單純知悉說（劉鐘英、胡、鄭、劉含章、林）：不過使親屬会议知其存在及內容而已，无JP§1004勘驗程序性質

(2)提示僅為準備程序，非生效要件，未经提示不影响效力（通、允22上1855例）

(3)§1212已知之繼承人应参考§1177繼承人有无不明之解釋当從實认定，戶籍上記載或其他客观情事认定

(4)义務人：遺囑保管人、繼承人

A、遺囑保管人：含受託保管人及事实上保管人

B、无保管人由遺囑人自行保管，死後繼承人發現交付予執行人

C、无保管人且發現人非繼承人：類推§1212交付執行人，不知有无執行人者通知已知之繼承人

D、封緘之遺囑：通知即可

E、无遺囑執行人当仍須§1211親屬会议選定当林：修正之目的不達，仍須召开親屬会议，单一條文片段修正意义不大

2、开視（§1213）：非於親屬会议当場或法院公証处

(1)自書遺囑代筆遺囑亦可封緘，惟封緘處处无須簽名

(2)§1213Ⅱ开視記錄记明封緘有无毀損或其他特別情事，並同在場之人同行簽名

(3)不限何人為之当开視仍由保管人或繼承人為之，公証处及親屬会议僅為认証（公証§2）並負責製作記錄而已

(4)係準備程序，非生效要件，違反之遺囑仍有效（通）

三、執行人

人產生（§1209、1211）：依下列順序

(1)§1209Ⅰ遺囑自行指定或委託他人代為指定

A、委託繼承人或受遺贈人

(A)否定說（史）：執行遺囑所生法律关係之当事人不含受託人，故繼承人与受遺贈人不得受指定

(B) 部分否定说(胡)：继承人与遗嘱之执行有重大利害关係，解释上不能为受托人，惟受遗赠得为受托人

(C) 肯定说(通)：尊重遗嘱人之信任，法无限制则应认皆可任之，且文义解释上他人指遗嘱人外之人，不同於无利害关係之第三人

B、受托人得拒绝就职

(A) 向亲属会议表示说(戴、模)：依法应由亲属会议另行选定⇒应向亲属会议表示

(B) 向继承人表示说(通、振)：亲属会议非常设机关，向该示极困难+§1215Ⅱ、1216，故应向继承人表示再由继承人召开亲属会议

C、不表示时，得催告期限内确答，逾期未确答视为拒绝

D、§1209Ⅱ：受托者应即指定执行人並通知继承人

(2) §1211前 亲属会议选定⇒3集是否必为选定执行人

A、否定说(琛、林)：有自由裁量权，故明文「得」指定，纵有必要而不为指定时无从强制非选定不可，仅利害关係人得声请法院指定之

B、肯定说(戴)：「得」应解为有权限之意，与§1211後 相同⇒非可不予选定之意

C、遗嘱外观上显见无效者得不为选任说(模)：须具备 选定遗嘱执行人之要件

(3) §1211後 法院指定

A、须§1211前亲属会议不能指定，不得遽为声请(刘含章、林)⇒不能含事实上或法律上不能，消极不选定为惯事实上便利，亦属不能

B、利害关係人：继承人、遗产债权人、受遗赠人、受遗赠人之债权人

C、法院：家事§127Ⅰ⑥继承开始时被继承人住所地专属管辖，声请後进入非讼程序，法院得驳回，利害关係人得对裁定抗告

D、§60Ⅲ 辅助行为才非除§1211，主管机关、检察官

2、消极资格限制(§1210)：未成年人、受监护或辅助宣告之人不得为执行人

(1) 继承人(§1198：不得为见证人)

A、否定说(胡)：继承人对遗嘱有重大利害关係⇒受遗赠人之利害将受继承人左右

B、肯定说(通、35院解3120)：§1210未排除，且尊重遗嘱人，无法妥当执行时自有解任方法

(2) 未成年人不论结婚与否(通、26院解1028)

3、法律地位(§1215Ⅱ)：视为继承人之代理

(1) 被继承人之代理人说(戴)：执行人=遗嘱人时候又不合理，就特别事项於必要范围内承认死者法人格之存续应无不可

(2) 继承人之代理人说(通)

A、人格承继说(史)：係实质上遗嘱人能力之一部，死後存续，然於法律构成上假托於承继遗嘱人地位之继承人

B、{实际需要说 / 破产管理人比照说}(郭、胡、范揚)：兼顾继承人与遗嘱受益人之利益⇒与破产管理人相似，遗产即归属继承人，代理係为实际之故

C、文义拘束说(模、5E机务上236例)：雖常直於对立地位，惟於实定法解释上无法忽视明文规定，不得不从继承人代理人说

(3) 单纯无益说(林、谢冰绿蒲)：前说主观上无代理意思，客观上未践行然负名主义，且常有利害对立致係公地位矛盾
应认§1215Ⅱ立法意旨在赋予代理人地位而仅於执行职务行为之法效果上，规定仅及於继承人而已

4、职务与权限

(1) §1214 编製遗产清册交付继承人，视为继承人或继承人全除？

A、不得免除说(通)：性质上有关公益，被继承人与继承人均不得免除

B、得免除说(林)：与公益无关，主要在于保护继承人之利益，继承人认无必要或避免支付编製费用(§1150 遺産支付之)，得免除之

(2) §1215 I 管理遺產：限与遺嘱有关之財產，与遺嘱无关之遺產仍由继承人管理

(3) 執行上必要行為

A、遺贈物之交付

(A) 交付遺贈屬处分行為，而遺贈僅負債权效 ⇒ 土登規則 §123 I 继承人先登记再会同受遺贈人辦理所有权移転登记

(B) 遺贈物不特定或為金錢 ⇒ 為取得必要時，对全部遺產有管理处分权 ⇒ 変賣遺產必要時得為之

B、訴訟行為：第三人占有時執行人得以自己名义起訴请求返还，受遺贈人提履行遺贈义務之訴亦僅得以執行人為被告

C、§1145 向主管机关声请设立財团之件可後移転，设立登记非其職務权限

D、信託§46 关係告受託人是否受託，拒絕則得以利害关係人身分声请法院選任受託人並特財產移転之

E、§1216 繼承人妨害之排除 ⇒ 僅於有執行人時有其適用

(A) 執行職務中：注意規定 ⇒ 应解為自继承開始時，无論有无執行人，其当然不得為与遺嘱相关遺產之処分行為

(B) 処分：含法律及事实上処分

(C) 亦不得妨碍是其職務之執行 ⇒ 執行人以继承人為被告起訴

(D) 继承人処分效力

a、絕对无效说(劉、鍾英、鼎、琛、茂揚)：§1216 係強制規定，§73 无效

b、效力未定说(史、模、戴、林)：无权処分，処分对遺嘱实現有利或未生衝突，无須遒认无效

(a) 不特定遺贈：继承人对全部遺產无処分权，若对執行不是妨碍，不妙使其受阻碍，執行人得同意或承认

(b) 特定物遺贈：同意処分标的物時与遺嘱人意旨相違 ⇒ 応屬无效(林)

(c) 继承人為執行人：処分特定物遺贈仍屬有效，但对受遺贈人応負債務不履行之損賠責任(林)(§226 I/544)

(4) 執行人与遺產管理人之職務分配：无人继承時，§1179 可能致权限重疊 ⇒ 僅存形成混乱，応由下列順序(通、SC 85当上684、90当上314、91当上786、97当上554、99当上1588)

A、遺產管理人先行清算及搜索：此期間内執行人权限停止，且法上執行人不排除管理人 ⇒ 執行人兼管理僅為便利，若有管理人則回歸本職之執行工作

B、執行人執行遺嘱：執行人於有管理人之情形僅負責執行

C、管理人行最後清算程序：未於公示催告期間為報明債权或声明之受遺贈人对其清償或交付遺贈物後歸於国庫

5、方法(§1217：数人執行職務以过半数决之，但遺嘱另有意思表示者從其意思) ⇒ 二人可否同数？

(1) 解任说(模)：类負推§1218 利害关係人请求或声请解任其中一人而改選他人

(2) 增加員額说(林)：此非重大事由，難適用§1218 ⇒ 本応避开偶数且解任何人甚難決定 ⇒ 类負推§1211 增加一人

6、報酬州请求权(104～§1211-1)(戴：修法前採否定说)

7、注意义務：善良管理人(林、史) ⇒ 執行人与管理人有諸多相似之処 ⇒ 応与管理人之通说相同标準

↳ 戴：不得请求報酬州 ⇒ 執行職務应以具体輕过失(无償委任)／模：応視有无報酬州而定(折衷说)

8、解任(§1218)

(1)怠行职务:对§1214、§1215-1所定职务不为积极履行

(2)其他重大事由:无论可否归责执行人 (ex:入监、长期失向不明、重大疾病)

(3)监护或辅助宣告:不待解任即因§1210当然失格,此时利害关係人亦得请求或声请改选

9、辞任:法无明文⇒通:肯定,惟有无限制?

(1)须正当理由说(通):仿JP⇒有正当理由始可许其辞任

(2)无限制说(史、模、林):普法(~97) 公益性质之指定监护人无须§1095正当理由,考量明轻,且执行人非不可或缺,因无执行人时得由继承人为之

拾、遗体及丧葬

一、遗嘱指定丧葬:无效,因§1187限处分「遗产」,丧葬非遗产⇒无殡葬自主权(通)

二、遗体

(1)为物(通、实、SC110上2109):继承人依公同关有方式处分之,仅所有权内涵限埋葬、管理、祭祀,不得自由使用、收益、处分,遗体受不法占有得请求返还

A、属遗产说(通):继承人有埋葬屍体之权利义务

B、非遗产说(胡):屍体非民法上所谓之物⇒非继承之标的⇒继承人原始取得而公同共有,亦无法由遗嘱决定丧葬方式

(2)非物(戴瑀如)

A、非遗产故无法遗嘱决定丧葬方式

B、由人格权延伸至自主决定权方式处理,尊重死者生前意愿(戴瑀如)

三、生前签订自用型生前殡葬服务契约

1、黄诗淳

A、仅具债权效:通 认死者无遗体处分权⇒无法将遗体移转予业者

B、业者仅得根据契约对继承生前契约债权之继承人请求移转遗体

C、立法论上应承认死者有遗体处分权,并得指定遗体处分权人使其取得物权性权利

2、戴瑀如

A、应以身后事之决定权(人格权)取代遗体处分权

B、参照安宁缓和条例、人体器官移植条例⇒本人生前对人身事项有决定权

C、殡葬管理条例§1-1:应予尊重⇒应强化本人意愿之地位

D、Ger:若本人未有事先表明意见,配偶或最近亲属因了解本人意愿而有优先决定权

E、立法论上应参考医疗决定权人顺位,若同顺位中数人有争执引进法院判断何者最合乎本人意愿,以尊重个人自主决定权

壹、性質

一、死因行為：須以遺囑為之，且遺囑依§1199自死亡生效

二、要式性：遺囑具要式性

三、單獨行為：無須他方承諾，若不願負受遺贈得按§1206拋棄遺贈

四、給予財產上利益之財產行為：包含消極地避免財產減少與債務之免除亦屬遺贈

↳一般之債務免除係有相對人之單獨行為，須向債務人為之，遺贈則係以遺囑人死亡為期限之行為，死亡時即生效力，不以通知債務人為必要

五、無償行為：雖可附負擔，惟此非對待給付

貳、死因贈與（Ger§2301、JP§554，TW未明文通說）

一、性質

1、附停止條件贈與說（鄭玉波、模、邱聰智、黃宗樂、高鳳仙重上213、阿重上更一6）：以受贈人於贈與人死亡時尚生存為停止條件

2、附決定條件贈與說（史、SC88台上91）：生前行立契約以贈與人死亡為決定條件而生效力之契約

3、附始期贈與說（戴、戴炎輝）：以贈與人死亡為始期贈與

4、委之當事人約定說（林）：無須一概而論，應回歸契約自由原則而定其性質（ex可約定受贈人先死亡時仍得由其繼承人承受受贈人之期待權）

二、與遺贈比較

1、同屬死因行為、無償財產行為、債權行為

2、

遺贈	vs	死因贈與（林：均無準用必要）
單獨行為		契約行為（須雙方意思表示合致）
遺囑能力（§1186五滿16歲）		完全行為能力（§12滿18歲）
要式		不要式
標的物非遺產 §1202本文 無效		贈與有效，轉入債務不履行
適用開視、執行人		無準用餘地
撤回應依遺囑要式		回歸債編贈與撤銷之規定

三、準用（通：於性質許可範圍內得準用）

(1)效力、執行人、受贈仍生存（§1201）準用說（鄭玉波）

(2)撤回權準用說（邱聰智、SC112台上356）：意思背反行為於條件成就前生效尚無從撤銷，應準用遺囑任意撤回規定

(3)排除準單獨行為與撤回說（史）：承認與拋棄屬單獨行為不得準用，撤回在準用於契約行為之贈與

(4)排除執行程序說（模）：無提示、開視、執行人規定準用，因贈與生效後係債務履行問題

(5)無準用說（林）：本質不同，應回歸債各處理

四、效力

(1)通、SC88台上91：均因贈與人死亡生效，可類推§1201

(2)林：生效要件不同（法律§1199 vs 契約）、限制不同（法律§1201 vs 停止條件）非類推而來

5、要件不備而无效之遺贈転換為死因贈与(§112)(家称:以受贈有无為承諾之意思表示為断)

(1)肯定说(通、JP通、東京高等法院昭和60、6、26、SC 75当上2543、96台再27、108当上2166、高院110家上150台中高分院96家上易9、高雄高分院96家上易5、台南高分院110重家上13、111家上42)

A、林:贈与意思自始未且受贈人有当場表示則依§98、112,遺嘱人縦无任財産歸由國庫之意,宜解為得転換以貫徹当事人真意

B、黃待澤:死因贈与於TW之実質功能即在於「救濟不合要式性之遺贈」⇒无效遺贈可解為要約,審查受贈人有无承諾合意即可転換

C、吳珮君:得直接或依§112解釋為死因贈与要約,受贈人在場見聞、配合提供身份、事後申請謄本領領遺産均可解為「黙示承諾」

D、李昆霖:応可推知亦有贈与意思,類推§112転換為要約

(2)否定说(SC 81台上4894、104台上1890裁、106台上533裁、107台上1271裁、112台上737裁、104台上1835、1626、103台上2689、92台上270、91台上1828、100台上1708裁、97台上1532高院107重上更一6、103家上82、301、家上易19、105家再4、108重上161、家上18、108家上103、304、台中高分院101家上107、台南高分院112家上42)

A、SC 81台上4894:性質迥然不同,无從転換

B、高院107重上更一6:律師建议採立遺嘱方式旨在享有隨時撤回之利益,无受契約約束之假定意思,当場表示願意僅配合遺嘱執理意,非承諾

C、SC104台上1890裁、高院103家上301:受贈人无法挙証当時有為承諾⇒単意思表示无從転為死因贈与

D、SC106台上533裁、104台上679裁
高院105家再4、103家上易19、101家上87:代筆遺嘱作成時受贈人非在場之人,无從於現場受領要約与承諾

E、SC107台上1271裁、高院106重上161:无效遺嘱仍属无相対人之単独行為,欠缺須相対人同意之意思表示合致⇒无從転換

F、SC112台上737裁、台中高分院101家上107、高院108家上304:遺嘱人未提及贈与,僅為財産分配,受贈人亦未於遺嘱簽章先受,无法証明贈与合意无從転換

G、高院106家上18:受贈人雖在場未為任何表示
台南高分院112家上42:依対立証人陳述非対受贈人為意思表示,単純毛況默不作声⇒§156対話為要約未立時承諾改拘束力,不符転換要件

H、高院108家上103:証人僅証明立遺嘱人単方陳述,无双方対価合致,且立遺遺嘱人選擇以書立遺嘱処分遺産,難认另有成立死因贈与契約之意

參、效力

一、区分说(花振):区別包括遺贈、特定遺贈

1.包括遺贈(JP§990、KR§1078):TW未明文承認认之,生效同時将的財転於受遺贈人⇒无待交付,与継承同様解釋,有物权效,惟不云准用§758登記

2.特定遺贈:受遺贈人僅得向継承人或執行人請求交付⇒僅具債权效

二、債权效力说(通)(土地§1231前:受遺贈人申請移登記在先継承人先辦継承登記後再会同受遺贈人申請之)

1.未明文物权效⇒TW民法採形式主義非意思主義,不宜特別承認有物权效

2.包括遺贈(通:承认)

(1)林:承认包括遺贈対承认与継承人有相同之権利义務,倫理上有矛盾,且包括遺贈含負担,於遺贈有差異,法无明文不忍難承认包括遺贈

(2)李昆霖:可认包括遺贈為有負担遺贈之一种,惟負担内容必須確定,效力与附負担遺贈无異,无単独承认必要

3.林:§1160、1162-1Ⅱ、1179Ⅱ受遺贈権劣後於一般債权⇒遺贈僅具債权效

肆、孳息

一、得請求交付時起取得孳息说(通、JP§992、Ger§2184、FR§1014):孳息之歸属不以所有权為依据,推定遺嘱人有使受孳息之意思⇒避免因遅延而生之不利益
惟現実上不生孳息者,不得請求相当孳息之利益

二、登記或交付時始取得孳息说(日):因有所有权後始対其有収益之权

三、回歸債総括付遅延说(林):遺贈僅具債权效⇒无法導出取得孳息之結果,法无明文難与JP為相同解釋,債总論保护受遺贈人,応先回歸給付遅延

伍、要件

一、遺囑須有效

二、§1201受遺贈人於遺囑生效時尚生存

1、通、Ger§2101、Austria§652、Swiss§487：補充遺贈，可立次順位受遺贈人，TW未明文，基於尊重遺贈人，應肯认之

2、史、模、林：若有表示受遺贈死亡由繼承人承繼者，可认作補充遺贈有效

3、胎兒有受遺贈能力

4、生效時未受胎

(1)肯定说(史、鄭、胡)：受遺贈人地位不同於繼承人，无須為如此嚴格之解釋，且僅取得請求权故无須於繼承開始時世已存在為必要

(2)否定说(模、鄧學仁、林)：一直未出生，法律关係不確定，对繼承人恐為不利，且TW无如Ger§2162Ⅱ有明文

5、後繼遺贈(通、Ger§2191、Austria§652、Swiss§488Ⅲ)：因條件成就転移至第二繼承人尊重遺囑人宜承认之；以第二人出生為條件之後繼遺贈应肯认之

三、§1202繼承开始時須屬於遺產

1、§1203遺贈物之代位

2、生前让与§1221遺囑視為撤回

3、遺囑另有意思表示(§1202但)：於遺囑中明白表示繼非遺產仍以之為遺贈标的；遺贈义務人应取得該物会付，无法取得時，应以相当价額支付之(通)

四、§1188 →(準用) §1145未表示接受遺贈权(通)：僅具補充功能，实際上使用甚少，僅於特定情形下發揮作用

五、不違反关於特留分規定(§1187)，違反之效力

1、有效说(通、SC 58台上1279判例)：§1225却減权应有其存在价值；有效並行使§1225

2、超过部分无效说(劉鐘英、陳棋、林)：§1187屬效力規定，侵害之部分无效；貫徹特留分係最低限度法定应繼分之本質

陸、附條件遺贈(§1200)：自條件成就時生效

一、遺囑人死前成就；視為无條件，死前停止條件確定不成就；遺贈无效

二、遺贈屬債权行為，得附解除條件；死前成就遺贈无效；死前確定不成就者為无條件(通)

柒、物上代位之遺贈(§1203)＝代替遺贈

一、遺囑人因遺贈物滅失、毀損、變造或喪失物之占有而对他人取得权利

1、滅失：所有权之消滅或物之滅失(ex:產險保金請求权、損賠請求、土地徵收償金請求权)

2、毀損：使价值減少或全部喪失；价金損失之損賠請求权亦推定為遺贈

3、變造：指因附合、混合、加工喪失所有权(§811~815)；§816依关於不当得利之規定請求償金；推定以該償金請求权為遺贈

4、受侵奪而喪失占有；得請求所有物返还亦得請求損賠，此損賠請求权即被推定為遺贈

二、遺囑物与他物附合或混合而对所附合或混合之物取得所有权

1、指取得单独所有权或共有权，推定以其所有权或共有权為遺贈标的

2、他人动產附合於遺囑人不动產

(1) 动产附合混合说（史、戴、刘锺英、林）：自有適用

(2) 不动产同一性说（模）：绝对无適用，同一性不变，当然以附合後不动产为遗赠标的

3. 加工物：加工物所有权，加工物为遗赠（通）

三、效力

1. 遗嘱生效时，对受遗赠人生赠与效，执行人或受遗赠人应通知债务人，否则对债务人不生令效力（§1177Ⅱ）

2. 灭失或毁损应於遗嘱作成後发生，生效前灭失遗赠无效；已遭毁损亦仅能就受领後有现存利益之物

3. 继承人若已受偿後偿金则受遗赠人对其有§179

4. 偿金请求权生前让与他人⇒§1122 法定撤回

5. §881 抵押权、§899 质权人之物上代位权优先於一般债权⇒更优先於受遗赠人（§1160）

6. 遗嘱人生前受全额偿金

(1) 无效说（通）：以遗嘱人未受清偿为限，已受清偿则非属遗产（§1202）⇒§1201前对受遗赠人意义不大

(2) 有效说（史、模）：是否清偿属偶然事件，以此区分並不妥当，应以其偿金全额为遗赠

7. §816 附合偿金义务之承担人

(1) 继承人说（胡）：非物之负担⇒除有特别表示外由本人承担

(2) 受遗赠人说（史、戴、模、林）：未支付死亡⇒一般可推定有使受遗赠人负担之意思，视为附负担遗赠，且新遗赠物价值较高，负担偿金义务合理

捌、用益遗赠（§1204）

一、定义：以用益权为遗赠标的⇒未定期限又不能依遗赠性质为期限，以受遗赠人终身为期限

二、有期限者，於期限届满前死亡，用益权之归属

1. 受遗赠人之继承人说（刘锺英）：期限未届满⇒继承人自得享有自遗赠之权利

2. 返还于遗嘱人之继承人说（史、模、刘志尊、林）：具人身专属性⇒继承人非指定之受遗赠人⇒依遗赠性质死亡即届期，以全家为共同继承人者自为例外

玖、附负担遗赠（§1205）

一、两个遗赠（ex：甲赠乙50万前提乙赠丙100万，丙为何地位？）

1. 第二受遗赠人说（通）：相当於对受遗赠人赠与扣除负担价值後之物，受益人则遗赠于相当负担之物

2. 单纯受益人说（林）：受益人本质上仍非受遗赠人，且该受益人可为继承人或遗嘱人⇒附负担遗赠非存在2个遗赠

二、性质

1. 非停止条件：履行非遗赠生效要件

2. 非解除条件：不履行时遗赠不当然失其效力

3. 非双务契约：单独、无偿行为⇒负担与遗赠不具对待给付之对价关係

三、§269同时履行抗辩权

1. 肯定说（戴、模、苏锦）

2. 否定说（林、振）：无適用双务契约规定之余地，纵未履行负担，遗赠义务人仍不得拒绝遗赠物之交付

四、所受利益：限案際所得之利益

1、若因扣減行使致遺贈物价值減少：按減少比例免其义務（通）

2、負担＞标的物价額：遺贈有效，超过标的物价額部分之負担无效（通）

五、履行义務人：受遺贈人

1、受遺贈人客观上不能履行負担（ex：負担為任執行人，但有§1210）⇒探求

(1) 若可得知遺囑人知其无效時將不為遺贈者，遺贈无效

(2) 若无此意思則負担无效，転為単純遺贈且有效

2、受遺贈人之継承人

(1) 受遺贈人於承认或拋棄前死亡⇒§1148由継承人継承承认及拋棄权

(2) 受遺贈人於承认後死亡⇒§1148义務由継承人負担

(3) 人身專屬性之义務/客观上不能履行負担之情形：継承人不負遲延責任，无須返还，因不可歸責

六、負担之履行請求权人

1、受益人

2、遺囑執行人（§1215Ⅰ）

3、主管官署（類推§412Ⅱ附負担之遺贈）⇒主管机关及檢察官基於公益需要得請求（通）

4、受益人

(1) 否定说（戴、胡、鼎、范揚）：僅有反射利益，未取得実質債权，无請求权，惟負担内容如係給与財産者，可視為第三遺贈，得請求履行負担

(2) 肯定说（史、胡、刘鉁鄴）：非債权人但其有§226Ⅰ，与其他負担权利人不同，无法請求不履行之損賠，若反对則須先選定執行人，費時且易总於履行义務（執行人）

七、撤销：類推§412Ⅰ（通）⇒不履行時可知遺囑人不為交付之意思

拾、承认

一、催告（§1207）

1、利害关係人：執行人、管理人、遺贈义務人之債权人、補充遺贈之第三遺贈人、後継遺贈中後位継承人

2、接受承认之人

(1) 遺贈义務人说（胡）：執行人非义務人，应向履行之人為之

(2) 催告权人说（刘鉁鄴、林）：无法律根据⇒应為民法所订之催告权人

3、屆期未表示視為承认（§1207後）：放利拋棄以不能推定為原則

4、效力

(1) 形成效：失去拋棄之自由⇒若仍得拋棄則淪為义务（刘鉁鄴：係得自由拋棄，屆期視為承认乃就无為承认与否表示而設之規定，仍得拋棄）

(2) 林：应解為不得再依§1206拋棄，惟仍得拋棄交付遺贈物之請求权

拾壹、打秘案（§1206）

一、自由：不得以遗嘱剥夺打秘案权利，若有载明则该部分属无效（史、模）

二、债务免除之遗赠之打秘案

1. 否定说（史、戴）：债务免除係单独行为，与继及对价生效力与不得打秘案

2. 肯定说（模、林）：承认打秘案之自由，且死亡生效无须和生前债务免除为相同解释，尤其附负担时。既不得载明，自不得以解释方式剥夺打秘案自由

三、方法：不要式

1、相对人

(1) 无相对人说（刘信部）

(2) 有相对人说（通）：无相对人则无人能知，惟宽格无须过多限制，以§1207之催告人即可

2、不得撤回打秘案（通），惟仍有§975Ⅰ書面打秘案之撤回

四、效力

1、§1206Ⅱ溯及遗嘱人死亡时

2、§1208：同无效、打破销相同，遗赠仍属遗产

3、附负担遗赠之打秘案

(1) JP§1002Ⅱ：在受负担利益之人（受益人）得自己为受遗赠人，直接取得该遗赠财产

(2) 通（反对JP）：区分受益人说

A、继承人为受益人：负担义务混同消灭

B、第三人为受益人：继承人在负履行义务，以免受不当利益

(3) 批评（林）：法无明文不通要求继承人履行负担实有困难

A、§1206Ⅱ与自始无遗赠与附款以有效为前提，宜解为负担随遗赠消灭

B、未明文但通参照区别无效、§1201失效、打秘案之不同效果

C、若负担须特定能力人，则解为继承人负担无过多实益，且继承人亦可能未成年和必能履行负担

壹、沿革

一、大理院8上737、10上722 认可

二、大清民律草案第五编继承法第四章→15草案继承编第六章 → 17继承法草案第八章→31订

贰、立法例

一、Ger §1937、1941、1938 →继受罗马法制：得任意剥夺法定继承人资格→排除继承权，特留分体对丧失继承权之代偿，仅具债权性质

二、FR §913~915、920 →继受日耳曼法制 (TW)：逝亲继承权，不许任意剥夺继承人资格，特留分有继承权性质且有扣减权

三、TW立法理由：採Ger法系，实质上应属FR法体

叁、比例 (§1223)

① 立法例

1. FR：全体特留额法 →全体保留比例归继承人共有→表权人份额归入他人份额中

2. Ger.TW：个别特留额法：个别指应继分比例归继承人所有→表权人份额不归入他人份额中

①、②、③ 直血亲、父母、配偶：应继分之 $\frac{1}{2}$

④、⑤ 兄弟姐妹、祖父母：应继分之 $\frac{1}{3}$

肆、算定 (§1224)

一、§1173 应继遗产＝积极遗产+特种赠与财产

二、除去债务额：债务额>应继财产→无特留分

1. 被继承人生前债务

(1) 专属一身之债务 (§1148 I) 非继承标的→被继承人死亡即消灭，非除去范围

(2) 刑诉§470 III 罚金得就受刑人之遗产执行 (刑罚止於一身原则之例外)→为除去之范围

2. 继承费用 (§1150)：管理、分割、执行、遗嘱费用

(1) 不应除去说 (胡、刘含章)：债务额限消极债务→继承费用非生前债务，不得扣除

例：100万 −30万（遗赠30万）−20万（继承费用5万）之直血亲

除去：100−30−20=30万→特留分各7.5万→遗赠5万

不除去：100−30=70万→特留分各35万→遗赠30万（保险金等5万不论理）

(2) 全额除去说 (SC102台上1163 林、模)：具共同利益费用性质，除去无不公平，应比照§1722 §1174 明文，若不扣除去，则从特留分额个别对继承人而言意义不大

(3) 折衷区分说 (史、振)：主同JP§885 II、1021之规定→与继承开始有关而应归遗产负担之债务 (如死亡宣告、开视、理葬、遗产估价费)→管理、清算费则不应扣除

3. 遗赠或死因赠与债务不在除去范围内

4. 附给付债务

(1) 不得除去说 (通、模一变更见解)：具死因扶养性质，先役一般债权，若列入扣除将侵害特留分

(2) 得除去说 (模一旧见解)：应解为有优先权之债权，故准应除去

伍、遗赠

一、一部无效说 (林、刘锺英、模)：遗赠遗产部分无效，因§1187之形式似强行规定

二、侵害部分无效並得拒绝交付说 (李宜琛)：当然无效

三、有效但得扣减说 (通、SC58台上1279例)：§1225 即§1187 视之为无效之一例→侵害部分非当然无效，仅有扣减权

陆、特留分权利存在於全体遗产上 (SC91台上556)

壹、性質

一、抗辯權說(踩)：未交付前，扣減權之行使純粹用以拒絕交付遺贈物，作用為消極防禦，屬永久抗辯權，並以無效為由主張之

↳ 株：無法解決已交付之情形，且既已無效何來抗辯權

二、債權說(劉鍾英)：本質上係無效後之不當得利返還請求權

↳ 株：§1225前論為注意規定

三、債權之形成權說(胡、鼎)：遺贈仍有效，故扣減權使有效之債權(遺贈行為)成為無效債權之形成權

↳ 株：特留分人降為債權人地位，保護不周

四、形成權兼抗辯權說(戴)：扣減同意思表示生效，形成權；扣減本僅有消極效力，抗辯權

五、物權之形成權說(通、5C91台上1042、91台上556、103台上2071)：行使扣減權後遺贈當然失其效力，物上權利當然復歸於遺贈人，發動前提係物權已移轉

1. 分割前：公同共有中，若交付則須以所有共有人名義請求(5C91台上556)，並於分割時為主張特留分之意思表示

2. 分割後：未交付：權利障礙抗辯，得提起所有物返還之訴 /已交付：§767物上請求權

貳、標的

一、§1200~§1208遺贈(§1225)(踩：限此部分得扣減)

二、§1187指定應繼分、§1165Ⅰ指定分割(通、21院741、5C91台上556、81台上1042、104台上1480、105台上1706)：得類推扣減權

三、§60捐助行為、信託、遺囑信託

四、§1165Ⅰ分割禁止、§1207執行人指定、§1147撤回皆不得扣減

五、領受死亡保險金遺族之指定非扣減對象，因死亡保險金非遺產(公務人員退休資遺撫卹法§63Ⅱ本文、公立學校教職員退休資遺撫卹條例§63Ⅱ本文)

六、生前普通贈與不得扣減：不計入應繼財產，本非扣減標的(通、31院2364、25院1578、5C49台上3711例、25上660例)

七、生前特種贈與

1. 肯定說(楔)：若數額過鉅，僅兼顧扣減仍架空他人特留分最低保障，為求實質公平應例外准予扣減

2. 否定說(通、21院743)：屬應繼分之前付，本質為生前處分，依§1173歸扣處理即可，不得扣減，且通：認超過部分無須返還，更無庸扣減

八、死因贈與

1. 肯定說(胡、戴、戴東雄)

(1) 死因贈與本質仍屬契約行為(生前行為)，與遺贈為單獨行為不同

(2) §1225限遺贈，不宜任意擴張

2. 肯定說(通)

(1) 鼎、史、戴：死因贈與之扣減不使法律關係複雜，符合立法旨趣

(2) 戴東雄：§1225若限遺贈及應繼分指定，則有特保扣定繼承人之立法意旨，十外國立法例(Gcv§2303, Swiss§523)+生效時點相同

(3) 楔：同為死後處分，若採前說將造成規避扣減之目的

(4) 株：立從§1187形式論上非扣減標的，但實質論上，將死因贈與同JP§544類推§1187本無不可，且保障者係繼承開始須權，與立法精神無違

第、扣减权人

一、特留分受侵害之继承人

二、特留分权利人之继承人：扣减权为物权之形成权，属财产权，非一身专属

三、特留分权利人之债权人（§242 代位行使保全）

四、特留分权利人之受遗赠人

1、肯定说（范扬、胡、戴）

2、否定说（林）：受遗赠权於遗赠人死亡时始发生，与他人於特留分权利人生前无从代位行使扣减权

五、应继分受让人

1、肯定说（梁）

2、否定说（林）：应继分不得让与

六、个别扣减权之受让人

1、肯定说（戴、楼、振）

2、否定说（林、史）：应继分不得让与，同 Swiss 解释，仅特留分权利人有扣减权，扣减权仅得继承，不得让与

七、被继承人之债权人代位行使

1、否定说（胡、林）：FR §921 明文被继承人之受遗赠人与债权人无此权利，且自有 §1160 优先返还、1161 不当得利，无须承认代位权

2、折衷说（史、戴）：无限继承时承认，因转为继承人之债权人，限定继承时因有 §1160，无承认之必要，现行法下已无承认必要

3、肯定说（楼、振）：扣减後之应继财产具有担保性，自应肯认否则违公平原则

肆、相对人：侵害特留分之人（受遗赠人、其他继承人、死因赠与之受赠人）

伍、效力

一、当事人间已交付：§767、953、956（物权全、林：不可归责受遗赠人灭失与不负赔偿责任）

二、返还方式

1、价额补偿原则说（通、JP §1041）：不便于受赠人以价额补偿他人取得现物较符遗赠人真意

2、区分可分性说（史）：权的不可分时始可例外价额补偿，可分时仍以现物返还较合於法益

3、区分已交付说（范扬）：已交付得返还价额，未交付则以特留分权利人之意思为主

4、特留分权利人有决定权说（林、孔 §1034 注 2071）：法无明文，不应使特留分权利人降为债权人地位，故应视特留分权利人之意思而定

三、继承开始後，明知特留分受侵害仍交付

1、扣减权之抛弃或特留分权利抛弃说（通）

2、§1800③非债清偿当不得依§179请求返还（林）：交付当无扣减权发生，何来抛弃

四、对第三人效力

1、史、楼、戴、戴东雄：恶意第三人得直接向其请求返还

2、善意第三人已善意取得⇒向受遗赠人请求 §1891 or §179

3、善意为第三人设定权利⇒第三人信赖登记不受影响，惟仍得请求负责使因此而生之损害，恶意则不受公信力保护

4、无资力不能返还

(1)由其他受遗赠人比例分摊说(通)：比例扣减立法意旨

(2)特留分权利人及受遗赠人分担说(苑)

(3)特留分权利人负担说(林)：§1225 无义务分担其他受遗赠人无力返还之部分之明文

五、行使效力不及於未行使之其他继承人(相对拒) (SC 105台上971)

陆、拋弃

一、继承开始前无从拋弃

二、一经拋弃即消灭

三、得对特定之受遗赠人为个别拋弃

柒、时效

一、立法例：Ger §2332、JP §1042、大清民律草案第五编继承法§94

二、不必规定说=抗辩权说(谌、戴)：消极作用⇒性质上最永久之抗辩权⇒未设规定之原因即在此

三、普通消灭时效说(鼎、刘含章、刘锺英、胡)：未规定则回归§125 15年

四、继承回复请求权消灭时效说(楔、孙、史、SC 103台上880)：类推§1146，早日确定继承关係

五、撤销权除斥期间说(林)：扣减权係物权之形成权，应於性质相类似之形成权除斥期间请求类推依据⇒§93、245 客体为物权行为之除斥期间(1年/10年)